



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



BULLETIN DES DECISIONS ET AVIS RENDUS

**PAR LE COMITE DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS (CRD) DE L'AUTORITE DE
REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)**

PERIODE DE 2008 A 2013



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



BULLETIN DES DECISIONS ET AVIS RENDUS

**PAR LE COMITE DE REGLEMENT DES
DIFFERENDS (CRD) DE L'AUTORITE DE
REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)**

PERIODE DE 2008 A 2013

PREFACE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

A la faveur de la réforme du dispositif national de passation et d'exécution des marchés publics, deux (02) structures ont été mises en place: la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), chargée entre autres du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, et l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), chargée notamment du contrôle a posteriori desdites procédures et du règlement des différends.

L'ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et la Direction Générale.

Le Comité de Règlement des Différends est chargé de :

- recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes ;

- recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur exécution.

Le Comité de Règlement des Différends siège soit en commission-litiges soit en formation disciplinaire.

Les décisions du CRD sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont définitives, sauf en cas de recours devant une juridiction administrative ou judiciaire, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif ; le Président du Conseil de Régulation peut également saisir le CRD à l'effet de statuer sur toute irrégularité de procédure dont l'ARMP aurait été saisie.

De 2008 à 2013, il a été noté un renforcement de l'expertise des autorités contractantes ainsi qu'une meilleure connaissance par les acteurs du secteur privé des procédures de passation des marchés tout comme de celles de saisine du CRD. Dans le même temps, les actions d'informations et de sensibilisation menées par l'ARMP ont permis de rassurer les différents acteurs sur l'opérationnalité des mécanismes de règlement des différends. Ce qui s'est traduit par le nombre sans cesse croissant des saisines et par voie de conséquence, des décisions du CRD. C'est ainsi qu'au fil du temps, il a été mise en place ce qu'on peut appeler une jurisprudence du CRD, composée de l'ensemble des décisions et avis rendus par cet organe.

Afin de mieux vulgariser la réglementation et son application par le CRD, il a été jugé nécessaires de mettre à la disposition du public ce présent recueil.

C'est le lieu pour nous, encore une fois, de remercier la Commission de l'Union européenne pour son accompagnement dans la réalisation des missions de l'ARMP en faveur de la bonne gouvernance.

Nous espérons que les universitaires, les praticiens et autres acteurs de la commande publique y trouveront un intérêt certain et nous ferons parvenir leurs observations qui permettront l'amélioration de la pratique du CRD.

Saer NIANG
Directeur général de l'ARMP

SOMMAIRE

N° D'ORDRE	INTITULES	PAGES
I.	DELAÏ DE CONTESTATION DES CLAUSES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (ARTICLE 86 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007)	6
II.	POUVOIR SOUVERAIN DE LA COMMISSION DES MARCHES POUR APPRECIER L'OFFRE ANORMALEMENT BASSE (ARTICLE 59-4 DU CODE DE 2007)	13
III.	CRITERES D'APPRECIATION DE L'OFFRE LA MOINS DISANTE (ARTICLE 59 DES CODES DE 2007, 2011 ET 2014)	20
IV.	CARACTERE SUBSTANTIEL DE LA MENTION DU MONTANT DE L'OFFRE SUR LA LETTRE DE SOUMISSION ET IMPORTANCE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT (ARTICLE 54 DE LA DIRECTIVE N° 04/2005/CM/UEMOA ET ARTICLE 11 DES CODES DES MARCHES PUBLICS DE 2007, 2011 ET 2014)	27
V.	REJET DES OFFRES NON CONFORMES PAR LA COMMISSION DES MARCHES (ARTICLES 68 ET 69 DES CODES DES MARCHES PUBLICS DE 2007, 2011 ET 2014)	36
VI.	OBLIGATION DE PRODUIRE LES PIECES EXIGEEES PAR LE CAHIER DES CHARGES	42
VII.	OBLIGATION DE RESPECTER LES PRINCIPES DE TRANSPARENCE DES PROCEDURES ET DE FORMALITES DE PUBLICITE (ARTICLE 59 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET ARTICLE 24 NOUVEAU DU CODE DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION (COA))	51
VIII.	OBLIGATION DE NE PAS INSERER DANS LES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES DES CLAUSES CONTRAIRES A LA LOI (ARTICLE 88 DU TRAITE INSTITUANT L'UEMOA – ARTICLE 3 DU REGLEMENT 02/2002/CM/UEMOA DU 23 MAI 2002 – ARTICLE 24-3 NOUVEAU DU COA)	58
IX.	- OBLIGATION DE RESPECTER LES CLAUSES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ; - OBLIGATION DE SAISIR PREALABLEMENT LE CRD AVANT DE SAISIR LA COUR SUPREME POUR CONTESTER UNE ATTRIBUTION PROVISOIRE (ARTICLES 88 ET 89 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2011 – ARTICLES 86 ET 87 DU CODE DE 2007 – ARTICLES 89 ET 90 DU CODE DE 2014)	66
X.	INCOMPETENCE DU CRD POUR LES MARCHES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE SA COMPETENCE (DEFINI PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA DIRECTIVE UEMOA N° 05/2005/CM/UEMOA – ARTICLE 31 NOUVEAU DU CODE DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - ARTICLE 2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – ARTICLES 20 A 24 DU DECRET N° 2007/546 DU 25 AVRIL 2007 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ARMP)	73

N° D'ORDRE	INTITULES	PAGES
XI.	IRRECEVABILITE DES RECOURS ADRESSES AU CRD AU-DELA DU DELAI DE TROIS (03) JOURS OUVRABLES FIXE PAR LE CODE DES MARCHES PUBLICS (ARTICLES 86 ET 87 DU CODE DE 2007 – ARTICLES 88 ET 89 DU CODE DE 2011 – ARTICLES 89 ET 90 DU CODE DE 2014)	80
XII.	IRRECEVABILITE DES OFFRES ARRIVEES A LA COMMISSION DES MARCHES APRES LES HEURES ET DATE LIMITEES DE DEPOT (ARTICLE 67-1 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007, 2011 ET 2014)	83
XIII.	INTERDICTION AUX CANDIDATS DONT LES PLIS SONT ARRIVES EN RETARD D'ASSISTER A L'OUVERTURE DES PLIS (ARTICLE 67-3 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)	90
XIV.	IRRECEVABILITE DU RECOURS CONTESTANT UNE INSCRIPTION AU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (ARTICLES 20 ET 21 DU DECRET N° 2007-546 DU 25 AVRIL 2007 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ARMP)	91
XV.	IRRECEVABILITE DU RECOURS DU CANDIDAT CONTESTANT UNE DECISION DE LA DCMP (ARTICLE 81-4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007 – ARTICLE 83-4 DU CODE DE 2011 – ARTICLE 84-4 DU CODE DE 2014)	95
XVI.	IRRECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DES RECOMMANDATIONS DE LA DCMP INTRODUIT HORS DELAI (ARTICLE 81.4 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007 – ARTICLE 83-4 DU CODE DE 2011 – ARTICLE 84-4 DU CODE DE 2014)	98
XVII.	PARTICIPATION DES ENTREPRISES ETRANGERES NON COMMUNAUTAIRES AUX MARCHES PUBLICS (ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – ARTICLES 24 NOUVEAU ET 28 NOUVEAU DU CODE DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION)	104
XVIII.	COMPUTATION DU DELAI DE CINQ (05) JOURS IMPARTI A LA DCMP (ARTICLES 138 ET 139 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007 – ARTICLES 140 ET 141 DU CODE DE 2011 – ARTICLE 141 ET 142 DU CODE DE 2014 – ARTICLE PREMIER DE LA DECISION N° 1/CRMP DU 16 MARS 2008, PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 138 ET 139 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007)	121
XIX.	PRESENCE OBLIGATOIRE DU MAGISTRAT AU MOMENT DE LA PRISE DES DECISIONS ET AVIS DU CRD (ARTICLE 18 DU DECRET N° 2007/546 DU 25 AVRIL 2007 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ARMP)	126

N° D'ORDRE	INTITULES	PAGES
XX.	- OBLIGATION DE TRANSMETTRE DES PIECES COMPLETES A LA DCMP ET D'ASSURER LA TRANSPARENTE ET L'EGALITE DES CANDIDATS (ARTICLES 79 ET SUIVANT ET 138 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007 – ARTICLE 24 NOUVEAU DU CODE DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION ; - REGULARITE DE LA DECISION DU CRD NON AFFECTEE PAR LA PRESENCE D'OBSERVATEURS EN SON SEIN ; - ABSENCE DE DESSAISISSEMENT DE LA DCMP TANT QUE TOUTES LES ETAPES DE LA PHASE DE CONTROLE NE SONT PAS TERMINEES.	127
XXI.	OBLIGATION POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE D'AVOIR LA PERSONNALITE MORALE ET DE SOUMETTRE LE MARCHÉ A LA FORMALITE DE LA REVUE PREALABLE (ARTICLE PREMIER DE LA DIRECTIVE N°04/2005/CM/UEMOA – ARTICLE 138 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2007 – ARRETE N° 11580 DU 28 DECEMBRE 2007)	135
XXII.	CONCLUSION D'UN AVENANT POSTERIEUREMENT A LA REALISATION DES PRESTATIONS ET APPLICATION DU CODE A TOUS LES MARCHES PUBLICS (ARTICLE 23.3 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – ARTICLE 1ER DU C.O.A ET 4.21 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2011	143
XXIII.	DENONCIATION D'IRREGULARITES COMMISES PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES (ARTICLE 20 DU DECRET N° 2007-546 DU 25 AVRIL 2007 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ARMP)	152
XXIV.	DENONCIATION DE LA PRODUCTION PAR LES CANDIDATS ET ATTRIBUTAIRES DE DOCUMENTS PRESUMES FAUX (ARTICLES 20 ET 23 DU DECRET N° 2007-546 DU 25 AVRIL 2007 – ARTICLES 147 ET 148 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2011 – ARTICLE 30 NOUVEAU DE COA	160
XXV.	DENONCIATION DE LA MAUVAISE EXECUTION DU MARCHÉ (ARTICLES 20 ET 23 DU DECRET N° 2007-546 DU 25 AVRIL 2007 – ARTICLES 147 ET 148 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2011 – ARTICLE 30 NOUVEAU DU COA)	169
XXVI.	PRESENCE DU CONTROLEUR FINANCIER DANS LES COMMISSIONS DE MARCHÉ NON CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES FONCTIONS DE REGULATION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (ARTICLES 37, PARAGRAPHE 3 DU CODE DES MARCHES PUBLICS – ARTICLES 3 ET 4 DE LA DIRECTIVE N° 05/2005/CM/UEMOA).	183

I. DELAI DE CONTESTATION DES CLAUSES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

En vertu de l'article 86 du code des marchés publics de 2007 (article 88 du code de 2011 et article 89 du code de 2014), les contestations relatives à la participation des candidats doivent être faites dans un délai de cinq (05) jours ouvrables, pour compter de la publication de l'avis d'appel d'offres ou de la communication du dossier d'appel d'offres.

Donc est mal fondé, l'argument du requérant présenté après la publication des résultats de la commission des marchés, et selon lequel les clauses du dossier d'appel d'offres sont imprécises.

**DECISION N° 013/11/ARMP/CRD DU 02 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DAKAR
MANAGEMENT AND TRADING (DMT) CONTESTANT L'ATTRIBUTION DU
MARCHE A LA SOCIETE EN.CO.SER POUR AVOIR SOUMIS UN PRIX JUGE
ANORMALEMENT BAS DANS LE CADRE DU MARCHE RELATIF A LA
SELECTION PAR LE COUD DES PRESTATAIRES CHARGES DE LA GESTION
ET L'EXPLOITATION DES RESTAURANTS DES ETABISSEMENTS
UNIVERSITAIRES.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de la société Dakar Management and Trading (DMT) en date du 5 janvier 2011 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saer NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 5 janvier 2011, enregistrée le 06 janvier 2011 sous le numéro 011/11 au Secrétariat du CRD, la société Dakar Management and Trading (DMT) a contesté la décision d'attribution du lot 2 du marché relatif à la sélection par le COUD des prestataires chargés de la gestion et l'exploitation des restaurants des Etablissements universitaires ASD, ESP DAKAR, ENSETP, CETAD DE POUT, ISFAR, ENSA, CMRT, UFR SANTE ET UNIVERSITE DE ZIGUINCHOR.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'au terme des articles 86 et 87 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié, tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d'un recours gracieux, soit le CRD ;

Considérant cependant qu'après avoir été informé par l'autorité contractante du rejet de son offre par lettre n°11/014/COUD/DIR en date du 6 janvier 2010, la société DMT a introduit un recours devant le CRD par lettre sur laquelle la date du 10 décembre 2011 a été malencontreusement inscrite en lieu et place du 10 janvier 2011 ; Que cette lettre a été enregistrée le 10 janvier 2011 par devant le Secrétariat du CRD ;

Considérant que ledit recours a été exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de notification du rejet de son offre, en référence aux dispositions combinées des articles 86 et 87 du Code des Marchés publics modifié ;

Qu'en conséquence, il doit être déclaré recevable.

LES FAITS

Le 22 novembre 2010, le COUD a fait publier dans le quotidien « Le Matin », un avis d'appel public à concurrence relatif à la sélection de prestataires pour la gestion et l'exploitation des restaurants universitaires (AAO N° 09/10).

Le 07 janvier 2011, le COUD publie un avis d'attribution provisoire du marché après avoir informé les candidats des résultats de la compétition ;

Le candidat DMT introduit un recours devant le CRD pour contester la décision d'attribution de la commission des marchés ;

Par décision n°006/11/ARMP/CRD du 17 janvier 2011, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché litigieux.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa demande, le candidat DMT déclare constater les manquements suivants sur le Dossier d'appel d'offres :

1. le dossier d'appel d'offres ne donne aucune indication sur la possibilité offerte aux candidats de soumissionner sur plusieurs lots et ne précise aucune modalité de soumission sur chaque lot ;
2. les Données particulières de l'Appel d'offres ne mentionnent pas les critères d'évaluation relativement à chaque lot du marché ;

Selon lui, ces manquements ne facilitent pas aux candidats la préparation d'offres conformes ;

D'autre part, DMT a prévu au niveau du lot 2 du marché, des moyens humains et matériels nécessaires et nettement plus importants que ceux exigés sur le lot 4 ;

Par conséquent, la commission des marchés avait toute latitude de lui demander des précisions supplémentaires affectées sur chaque lot, les moyens humains et matériels proposés ;

1. A la Section IV du Programme d'activités, il est mentionné que le candidat devra spécifier clairement le coût de chaque repas ; qu'à cet égard, le candidat EN.CO.SER a proposé une offre globale de 2020 F CFA composée comme suit : Petit déjeuner : 200 F CFA , Déjeuner : 910 F CFA, Diner : 910 F CFA ;

Selon le requérant, l'offre de son concurrent EN.CO.SER sur le Petit déjeuner fait ressortir un écart de 41% en dessous de la moyenne des prix offerts par les douze candidats, ce qui doit être considéré comme une offre douteuse exigeant la vérification par la commission des marchés ;

Les investigations qu'il a mené auprès des importateurs et usines de la place pour les produits exigés pour le petit déjeuner a permis d'aboutir à un coût total moyen de 247,7 F CFA en deçà duquel tout prix proposé demeure insuffisant au regard des coûts de production et par conséquent non-conforme à la vérité des prix et à la réalité des prestations ;

Or, les dispositions de l'article 80 alinéa 1 de la Directive n° 04/2005 de l'UEMOA repris par l'article 15.1 du Code des Marchés publics modifié prévoient que les prix sont réputés assurer au titulaire du marché, un bénéfice ;

En conclusion, le requérant demeure convaincu que le prix proposé par son concurrent au petit déjeuner traduit une volonté manifeste de l'écarter de la compétition, et réclame le rejet d'une telle offre.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Au motif du rejet de l'offre de la société DMT, la commission des marchés déclare que le dossier d'appel d'offres prévoit au niveau de la clause 5.2 des Données particulières, les critères de conformité et de qualification exigés sur chacun des six lots du marché :

1. Sur le lot 2 du marché, la mise à disposition de soixante dix huit (78) personnes en moyens humains, d'un véhicule d'approvisionnement de 5 à 10 tonnes, d'un camion frigorifique de 5 à 10 tonnes pour le transport des produits périssables, d'un véhicule de transport du personnel de 14 à 30 places, d'un conteneur frigorifique d'une capacité de 20 à 40 pieds ;
2. Sur le lot 4 du marché : la mise à disposition de trente neuf (39) personnes en moyens humains, d'un véhicule d'approvisionnement de 5 à 10 tonnes, d'un camion frigorifique de 5 à 10 tonnes pour le transport des produits périssables, d'un véhicule de transport du personnel de 14 à 30 places, d'un conteneur frigorifique d'une capacité de 20 à 40 pieds ;

Selon la commission des marchés, la société DMT a proposé les moyens matériels et humains suivants sans spécifier les lots du marché auxquels ils se rapportent, ni mentionner sur les contrats de location, le nom et le cachet du propriétaire des véhicules ;

- soixante dix huit (78) personnes en moyens humains,
- un conteneur frigorifique d'une capacité de 20 à 40 pieds,
- un camion benne de 8,1 tonne,
- un car de transport de marque TATA de 29 places,
- un camion frigorifique de 13 tonnes ;

C'est la raison pour laquelle la commission des marchés a jugé l'offre de DMP non conforme ;

Sur le deuxième moyen soulevé par le requérant, la commission des marchés soutient que le prix des repas est laissé à la libre appréciation des candidats.

Il s'y ajoute que le Programme d'activités prévoit que le niveau de prix proposé sera jugé en faisant une sommation des trois services quotidiens, notamment le Petit déjeuner, le Déjeuner et le Dîner.

Par ailleurs, le requérant déclare que le prix proposé par son concurrent EN.CO.SER au niveau du Petit déjeuner est manifestement sous évalué, alors qu'ils ont fait la même proposition financière de 2020 F CFA pour les trois repas quotidiens.

En outre, le COUD soutient que le dossier a reçu la non objection de la DCMP sur toutes les étapes de la procédure de passation du marché.

SUR L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le bien fondé des motifs de rejet des offres du requérant pour l'absence d'indications sur les modalités de soumission sur chaque lot du marché et sur le caractère jugé anormalement bas d'un sous détail du prix global de l'attributaire.

AU FOND

1. SUR LE CARACTERE IMPRECIS DES DISPOSITIONS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES :

Considérant que selon les dispositions de l'article 8 du Code des Marchés modifié, les travaux, fournitures et services peuvent être répartis en lots en donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises ;

Considérant qu'en référence à l'avis d'appel d'offres qui a été publié dans le quotidien « Le Matin » du 22 novembre 2010 et à la clause 5.2 des Données particulières des Instructions aux candidats, les soumissionnaires doivent remplir les conditions de qualification en terme de moyens humains, matériels et d'expérience acquise dans l'exploitation de restaurants universitaires ;

Qu'à cet égard, il est spécifié sur chacun des six lots du Dossier d'appel d'offres, les critères exigés pour l'accomplissement des prestations, notamment le personnel, les moyens matériels et financiers ;

Considérant que l'évaluation des offres a été menée par la commission des marchés conformément aux dispositions de la clause 31 et 32 des Instructions aux candidats, en procédant lot par lot, à l'examen préliminaire, à la conformité puis à la comparaison des offres ;

Considérant également que selon l'article 86 du Code des marchés publics modifié, en cas de contestation portant sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, un recours peut être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres ou de la communication du dossier d'appel d'offres ;

Considérant qu'à ce propos le requérant a attendu la publication des résultats de l'évaluation des offres par la commission des marchés pour remettre en cause les règles relatives à la participation des candidats alors qu'il avait la possibilité d'introduire un recours dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou la communication du dossier d'appel d'offres ;

Qu'il y a lieu de dire que l'imprécision des clauses du dossier d'appel d'offres dénoncée par le requérant n'est pas fondée ;

2. SUR LE CARACTERE JUGE ANORMALEMENT BAS DU PRIX DU PETIT DEJEUNER PROPOSE PAR LE CANDIDAT ENCOSER :

Considérant également qu'il ressort du Programme d'activités du Dossier d'appel d'Offres que le prix de cession des repas est laissé à la libre appréciation des candidats qui devront spécifier clairement le coût de chaque repas ; que, toutefois, le niveau de prix proposé sera jugé en faisant une addition des montants des trois services quotidiens à savoir le Petit déjeuner, le Déjeuner et le Dîner ;

Considérant qu'à cet égard, le requérant conteste le montant jugé anormalement bas de la proposition de son concurrent sur le Petit déjeuner et reproche à la commission des marchés de ne pas demander les justificatifs prouvant la réalité économique du prix soumis ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics, la commission des marchés a la faculté de rejeter par décision motivée une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix ; qu'en pareil cas, le candidat peut justifier son prix notamment du fait :

- a) de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
- b) des conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services
- c) de la nécessité d'utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives ;

Considérant que, selon l'article 59 du Code des Marchés sus visé, cette prérogative est une faculté laissée à l'appréciation de la commission des marchés qui lorsqu'elle le juge nécessaire, demande des informations et explications de nature à permettre de juger du caractère anormalement faible ou élevé de l'offre incriminée en tenant compte en particulier de la nature du marché et de l'état de la concurrence ;

Considérant que, d'autre part, le requérant a soumis la même offre financière globale de 2020 F CFA que le candidat ENCOSER, prix représentant la somme des trois services quotidiens et servant de référence pour déterminer l'attributaire du marché ;

Que si l'opportunité de demander des informations pour apprécier une offre jugée anormalement basse appartient à la commission des marchés, son appréciation doit également porter sur le montant global du marché et non sur un sous détail des prix ;

Que pour cette raison, et celles précédemment relevées, il convient de dire que la commission des marchés est seule habilitée à apprécier de l'opportunité d'exiger des informations complémentaires en cas de doute sur la caractère anormalement bas d'une offre ; qu'en conséquence, déclare mal fondé le motif d'annulation de l'attribution dudit marché ;

DECIDE :

- 1) Reçoit le candidat DMT en son recours ;
- 2) Constate que la clause 5.2 des Données particulières du dossier d'appel d'offres spécifie sur chacun des six lots du marché, le personnel, les moyens matériels et financiers exigés à l'accomplissement des prestations ;
- 3) Dit que les motifs d'annulation du marché pour imprécision des clauses du dossier d'appel d'offres ont été introduits tardivement, en référence à l'article 86 du Code des marchés publics modifié ; par conséquent,
- 4) Dit qu'ils ne sont pas fondés ;
- 5) Dit que la commission des marchés est seule juge de l'opportunité et de l'appréciation de la conformité d'une offre jugée anormalement basse ;
- 6) Dit que l'appréciation du caractère anormalement bas d'une offre doit porter sur le montant global proposé par le candidat et non sur un sous détail des prix ;
- 7) Constate que le requérant a soumis la même offre financière globale que le candidat EN.CO.SER ; en conséquence,
- 8) Confirme la décision de la commission des marchés ;
- 9) Ordonne la poursuite de la procédure ;
- 10) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Dakar Management and Trading, à la Direction du Centre des Œuvres Universitaire de Dakar ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée.

Le Président
Abdoulaye SYLLA

II. POUVOIR SOUVERAIN DE LA COMMISSION DES MARCHES POUR APPRECIER L'OFFRE ANORMALEMENT BASSE

Il résulte de l'article 59-4 du code des marchés publics de 2007 qu'il appartient à la commission des marchés de rejeter par décision motivée une offre qu'elle juge anormalement basse et il lui est laissé la prérogative, lorsqu'elle le juge nécessaire, de demander des informations et explications de nature à permettre de juger du caractère anormalement faible ou élevé de l'offre financière en tenant compte, en particulier, des sous détails des prix, de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés.

Donc, est impertinent le motif d'annulation du marché avancé par le candidat évincé, et fondé sur le montant qu'il juge anormalement bas de la proposition du candidat attributaire provisoire du marché.

Ainsi, même si une offre manifestement basse par rapport au prix fixé par l'autorité contractante pourrait être suspecte, parce que pouvant traduire la volonté d'un candidat de gagner à tout prix le marché, le pouvoir d'appréciation relève de la volonté de l'autorité contractante (voir décision sus-visée du CRD n° 13 du 2 février 2011 statuant en commission litiges sur la demande de la société Dakar Management and Trading contre le Centre des Œuvre Universitaires (COUD)).

DECISION N° 132/12/ARMP/CRD DU 30 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HUSSEIN AYAD & CIE CONTESTANT LA DECISION D'ATTRIBUTION DU LOT 6 (INCINERATEUR) DU MARCHE D'ACQUISITION ET D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUES POUR LES STRUCTURES DE SANTE AN 3 (APPEL D'OFFRES N° 03 A3/4R9), LANCE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 25 août 2012, de la société HUSSEIN AYAD & Cie ;

Après avoir entendu M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mamadou DEME, Président, assurant l'intérim de Abdoulaye SYLLA, de MM. Abd'El Kader NDIAYE, et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'enquêtes et d'Inspection sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs, Ely Manel FALL, Chef de Division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 25 août 2012, enregistrée le 29 août 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 759/12, la Société Hussein Ayad & Cie a saisi le CRD pour contester la décision d'attribution du lot 6 « Incinérateur » du marché d'acquisition et d'installation d'équipements médico techniques pour les structures de santé (An 3), lancé par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

LES FAITS

La Division de Lutte contre le SIDA et les IST du Ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé dans le journal « Le Soleil » du 27 avril 2012, un avis d'appel d'offres en six lots séparés relatif à l'acquisition et l'installation d'équipements médico-techniques pour les structures de santé - An 3.

A l'ouverture des plis du 13 juin 2012, la commission des marchés a reçu sur le lot 6, les offres suivantes :

AFRIMED: 21 266 742 F CFA;

SSM: 34 742 400 F CFA;

SWISS PHARM: 63 823 200 F CFA;

DRP: 107 275 000 F CFA;

ACD : 133 700 000 F CFA ;

MEDICAL PARTNER : 204 872 500 F CFA;

HUSSEIN AYAD & Cie : 246 832 949 F CFA;

FERMON LABO : 293 708 800 F CFA.

Après publication dans le journal « Le Soleil » des 25 et 26 août 2012, de l'avis d'attribution provisoire du lot 6, la société HUSSEIN AYAD & Cie a saisi directement le CRD d'un recours contentieux, par lettre en date du 25 août 2012, enregistrée le 29 août 2012.

Par décision n°96/12/ARMP/CRD du 04 septembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché concerné jusqu'au prononcé de la décision au fond par la Commission Litiges du CRD.

MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, le requérant dit avoir été informé de l'attribution provisoire du lot 6 du marché à AFRIMED, pour un montant total de 21 266 742 F CFA, représentant la quantité de sept incinérateurs de 20 kilogrammes à livrer et installer.

Selon lui, le prix proposé par l'attributaire est dérisoire, voire impossible pour un incinérateur destiné à un hôpital et répondant aux normes de sécurité internationales.

En effet, au vu des offres proposées par les soumissionnaires, les prix unitaires peuvent être considérés comme suit :

AFRIMED: 3 038 105 F CFA

SSM: 4 963 200 F CFA

SWISS PHARM: 9 117 600 F CFA

DRP: 15 325 000 F CFA

ACD: 19 100 000 F CFA

MEDICAL PARTNER: 29 267 500 F CFA

HUSSEIN AYAD & Cie : 35 261 849 F CFA

FERMON LABO : 41 958 400 F CFA.

Le requérant fait constater que les prix offerts par Médical Partner, Fermon Labo et Hussein Ayad & Cie sont plus ou moins équivalents et reflètent la réalité. La légère différence s'explique par les options du matériel, sa qualité ou sa provenance.

A titre de comparaison, il a joint les résultats d'un appel d'offres concernant l'hôpital de Diamniadio et la Division de la Lutte contre le SIDA et les IST :

AO N° 12-11 Equip. Hôpital Diamniadio/MSHPP/DEM/BUDGET ETAT 2011.1
Incinérateur :

SOUSSIONNAIRE	MONTANT OFFERT	MONTANT RETENU
Fermon Labo	57 677 200	57 677 200
Hussein Ayad & Cie	38 771 186	
ACD	18 603 488	
Afric Import	8 850 000	
SOFICA	18 300 384	

AO N° 02 A2/9/R9 Division de la Lutte contre le SIDA et les IST – 7 incinérateurs :

SOUSSIONNAIRE	MONTANT OFFERT	MONTANT RETENU	PRIX UNITAIRES
Hussein Ayad & Cie	237 691 903		33 955 986
AFRIMED	21 266 742	21 266 742	3 038 105
ACD	148 941 417		21 277 345
Carrefour Médical	206 833 081		29 547 583
SOFICA	14 066 721		2 009 531
DRP	133 000 000		19 000 000
FERMON LABO	246 633 450		35 533 350

En conclusion, le requérant soutient que pour le même appareil, la commission a appliqué deux différents prix unitaires:

AFRIMED: 3 038 105 F CFA

FERMON LABO: 57 677 200 F CFA.

Il poursuit qu'au prix de 3 038 105 F CFA, il est impossible de fournir un incinérateur médical professionnel d'un poids de 3 tonnes, destiné aux besoins d'un hôpital et remplissant toutes les exigences en matière de sécurité et d'hygiène.

En conclusion, il souhaite l'arbitrage du CRD.

MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas fourni d'informations complémentaires, en réponse aux allégations du requérant.

Toutefois, suivant les informations contenues dans le rapport d'évaluation des offres, il ressort que sur les 8 soumissionnaires ayant présenté une offre, 5 ont été déclarés non conformes à l'issue de l'examen préliminaire.

Il s'agit de SWISS PHARM et de MEDICAL PARTNER dont le matériel proposé n'est pas conforme aux spécifications techniques.

HUSSEIN AYAD & Cie n'a pas produit de garantie d'offres et Fermon labo a présenté une garantie de soumission émanant d'une banque non agréée.

Après évaluation des trois autres soumissions déclarées conformes, la commission des marchés a attribué le marché à AFRIMED qui a proposé l'offre la moins disante et qui respecte les critères de qualification.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs ci-dessus présentés que le litige porte sur le prix jugé anormalement bas de l'attributaire du marché.

AU FOND

Considérant, d'une part, que l'article 7 du Code des marchés publics dispose que « Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux qui doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. » ;

Considérant que selon les dispositions combinées des articles 68 et 70 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission compétente procède d'abord, à un examen préliminaire, avant de proposer l'attribution du marché au candidat qui a soumis l'offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnue réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant qu'en application de cette disposition, l'autorité contractante a requis pour le lot 6 (Incinérateurs), les spécifications techniques suivantes :

- Incinérateur à commande électrique, d'une construction simple avec un fût métallique en acier par commande électrique comprenant
 - une cage de réception des déchets bio médicaux,
 - une chambre de combustion avec cheminée disposant d'un fi permettant de retenir les cendres,
 - Un couvercle,
 - Une amenée d'air,
 - Une turbine permettant l'amenée de l'air,
 - Température de combustion : 1800 °C,
 - Conformité par rapport aux normes européennes,
 - Livrée avec tous les accessoires nécessaires ;

Considérant qu'AFRIMED a proposé dans son offre, un incinérateur de déchets hospitaliers de 20 kg/h transportable, avec à l'appui une documentation, ayant les caractéristiques ci après :

- Incinérateur à commande électrique :
- modèle 2000VI,
- marque : TURBO,
- fonctionne en utilisant peu d'électricité, mobile sur roue, appareil monobloc,
- construction simple avec un fût métallique en acier par commande électrique, sans émanation de fumée ou émission de gaz dans l'environnement,
- couvercle,
- amenée d'air
- turbine permettant l'amenée de l'air,
- température de combustion : 1500 à 2000°C,
- approuvé par WHO et UNICEF,
- capacité : 20 kgs/heure,
- poids : 85 kgs,
- dimensions : 75X901X127 cm
- livré avec tous les accessoires ;

L'incinérateur est composé d'une cage de réception des déchets biomédicaux, munie d'une chambre de combustion avec cheminée disposant d'un filtre permettant de retenir les cendres,

Considérant qu'à cet égard, la commission des marchés a valablement conclu que société AFRIMED a respecté les spécifications techniques définies dans le dossier d'appel d'offres ;

Considérant que par la suite, AFRIMED a proposé l'offre financière la moins élevée parmi les trois sociétés ayant soumis une offre conforme ;

Que c'est à bon droit que la commission des marchés a déclaré AFRIMED attributaire provisoire du lot 6 du marché litigieux ;

Considérant que par ailleurs, en référence à l'article 59.4 du Code des marchés publics, l'opportunité de décider qu'une offre est anormalement basse est du ressort de l'autorité contractante, lorsque cette dernière justifie que le montant de l'offre incriminée ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte ;

Considérant qu'il ressort des conclusions de la commission des marchés, que l'attributaire provisoire n'a pas soumis une offre anormalement basse,

Qu'il y a lieu de conclure que la décision d'attribution du lot 6 du marché est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

- 11) Constate que AFRIMED a soumis sur le lot 6 du marché, l'offre conforme évaluée la moins disante ;
- 12) Constate que la commission des marchés n'a pas jugé l'offre d'AFRIMED anormalement basse ; à cet égard,
- 13) Dit que la décision d'attribution provisoire du marché est fondée ;
- 14) Ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché litigieux ;
- 15) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Hussein Ayad & Cie, au Ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi qu'à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Pour le Président et par intérim

Mamadou DEME

Les membres du CRD

Abd'El Kader NDIAYE

Ndiacé DIOP

**Pour le Directeur Général et par ordre
Rapporteur**

Salimata Sall DEMBELE

CRITERES D'APPRECIATION DE L'OFFRE LA MOINS DISANTE

Il résulte de l'article 59 du code des marchés publics que l'autorité contractante a le choix, pour la détermination de l'offre la moins disante, entre le prix le plus bas ou le prix et d'autres critères auxquels le candidat doit nécessairement satisfaire.

Donc, si l'autorité contractante fixe dans le dossier d'appel d'offres d'autres critères tels que l'offre technique, la crédibilité du compte d'exploitation prévisionnelle pour une période de trois (03) ans avec trois (03) sous-critères, il ne suffit pas pour un candidat de proposer le prix le plus bas pour avoir l'offre la moins disante.

DECISION N° 029/11/ARMP/CRD DU 09 MARS 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE GANDIOL CONTESTANT L'ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L'APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE MAGASINS LANCE PAR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MATAM (PRODAM II)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l'article 30 du Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 11 février 2011 de la Société GANDIOL ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Oumar SARR, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, et de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Mamadou DEME, Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique et René

Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 11 février 2011, enregistrée le 14 février 2011 sous le numéro 118/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Société GANDIOL a saisi le CRD d'un recours en contestation du marché relatif à l'appel d'offres pour les travaux de réalisation de magasins lancé par le Projet de Développement agricole de Matam (PRODAM II)

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant que le présent recours, reçu à l'ARMP le 11 février 2011 et enregistré le 14 février 2011 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, est dirigé contre la décision d'attribution du marché relatif à l'appel d'offres pour les travaux de réalisation de magasins lancé par le Projet de Développement agricole de Matam (PRODAM II) publiée le 10 février 2011 dans le numéro 5319 du journal « *Sud Quotidien* » ;

Considérant qu'au terme de l'article 87 du Code des marchés, les recours formulés devant le CRD en contestation des décisions établies lors de la procédure de passation des marchés et délégations de service public sont de trois jours francs ;

Qu'en considération de cet élément et de ce que le soumissionnaire évincé a saisi l'ARMP le lendemain de la publication de l'avis d'attribution, soit le jour du point de départ du délai de recours, le présent recours doit être déclaré recevable ;

LES FAITS :

Dans le cadre d'un cofinancement BOAD/Etat du Sénégal, PRODAM II a, suite à l'avis général de passation n°007/AON/UGP/2010, lancé un appel public à la concurrence pour la réalisation d'infrastructures consistant en des magasins dans la région de Matam. Les travaux ont été répartis en trois lots.

A cet effet, l'autorité contractante a lancé un appel d'offres qui a été publié dans le journal Sud Quotidien du 02 octobre 2010.

A la date d'ouverture des offres, trois plis ont été reçus et ouverts au nom des soumissionnaires suivants : EBY, Le Gandiol et ESCI, chacun ayant soumissionné pour les trois lots.

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE			PRIX DE L'OFFRE (LU PUBLIQUEMENT)	
Nom des candidats ayant soumissionné	Adresses	N° Lots	Montant HT (FCFA)	Montant TTC (FCFA)
EBY	30, rue Mbaye Guèye- Dakar Tél : 33 864 35 31 Email : eby.sarl@yahoo.fr	I	82.524.942	97.379.432
		II	137.541.570	162.299.053
		III	110.033.256	129.839.242
GANDIOL	Avenue Malick Sy x Faidherbe en face Polyclinique - Dakar BP 5531 Dakar Fann	I		91.872.540
		II		160.776.941
		III		131.071.487
ESCI	1036, Liberté I - Avenue Bourguiba - Dakar	I	88.672.971	104.634.106
		II	147.788.285	174.390.176
		III	118.230.628	139.512.141

A l'issue de l'évaluation, le marché a été provisoirement attribué à l'Entreprise EBY pour le montant de 389 517 726 F CFA HTT et publié dans le journal Sud Quotidien du 10 février 2011

Gandioli, soumissionnaire évincé a saisi le CRD pour contester cette attribution.

LES MOYENS PRESENTES A L'APPUI DE SA SAISINE :

A l'appui de son recours, Gandiol a produit le tableau qui suit comme reflétant les offres financières des candidats à l'ouverture des plis.

N°	SOUMISSIONNAIRES	N° LOT	MONTANT HT (FCFA)	PRIX TOTAL TTC
1	ETS EBY	Lot 1	82.524.942	97.379.432
2	ETS EBY	Lot 2	137.541.570	162.299.053
3	ETS EBY	Lot 3	110.033.256	129.839.242

N°	SOUMISSIONNAIRES	N° LOT	MONTANT HT (FCFA)	PRIX TOTAL TTC
1	E.S.C.I	Lot 1	88.672.971	104.634.106
2		Lot 2	147.788.285	174.390.176
3		Lot 3	118.230.628	139.512.141

N°	SOUMISSIONNAIRES	N° LOT	MONTANT HT (FCFA)	PRIX TOTAL TTC
1	SOCIETE GANDIOL	Lot 1	77.858.085	91.872.540
2	SOCIETE GANDIOL	Lot 2	136.251.645	160.776.941
3	SOCIETE GANDIOL	Lot 3	111.077.532	131.071.487

Ensuite, Gandiol a soutenu qu'il a été moins disant :

- Pour le lot n°1 avec une offre financière de 91 872 540 TTC ;
- Pour le lot n°2 avec une offre financière de 160 776 941 FCFA TTC.

Etant moins disant sur les lots 1 et 2, il a contesté l'attribution du marché en ce qui concerne ces lots à EBY.

MOTIFS DONNES A LA DECISION PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre de transmission en date du 28 février 2011 des documents relatifs à l'appel d'offres, notamment le procès verbal d'ouverture des plis et le rapport d'évaluation, l'autorité contractante qui a admis qu'à l'ouverture des plis Gandiol était moins disant sur les lots 1 et 2, mais qu'il n'avait pas fourni les pièces suivantes requises par le DAO :

1. L'attestation de l'Inspection du travail ;
2. Le bordereau des prix unitaires ; et,
3. Les références de la société en matière de travaux similaires réalisés.

L'autorité contractante a, sur ces considérations, décidé le rejet des offres de Gandiol.

OBJET DU LITIGE

Considérant qu'il résulte des faits, moyens et motifs présentés par les parties, que le litige porte sur :

1. la détermination de l'offre la moins disante ;
2. la conformité des offres ;
3. la qualification des soumissionnaires en particulier de ceux qui n'ont pas fourni les renseignements demandés sur leur expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché.

AU FOND

1) SUR LA DETERMINATION DE L'OFFRE LA MOINS DISANTE :

Considérant qu'aux termes de l'article 59.1 du Code des marchés publics, la détermination de l'offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous forme de critères éliminatoires ;

Considérant que selon les stipulations de la clause 36.1 « l'Autorité contractante attribuera le marché au candidat dont l'offre aura été évaluée la moins disante et jugée conforme au dossier d'appel d'offres, à condition que le candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante » ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la détermination de l'offre la moins disante est effectuée sur la base du prix et d'autres critères auxquels le candidat doit nécessairement satisfaire ;

Qu'en conséquence, il ne suffit pas de proposer le prix le plus bas pour avoir l'offre la moins disante ;

Qu'à cet égard, la demande du requérant n'est pas opérante ;

2) SUR LA CONFORMITE DES OFFRES ;

Considérant qu'il est stipulé à la clause 30.1 « l'Autorité contractante examinera les offres pour s'assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont complets » ;

Que selon la clause 30.2 l'Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l'offre ; qu'au cas où l'un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l'offre sera rejetée :

- a) le formulaire de soumission de l'offre, conformément à la clause 12.1 des IC ;
- b) le bordereau des prix et le détail quantitatif, conformément à la clause 12.2 des IC ;
- c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat, conformément à la clause 21.2 des IC ; et,
- d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ».

Considérant qu'à l'issue de l'examen préliminaire des offres , il a été relevé que les offres de Gandiol ne comportaient pas les pièces suivantes requises à peine d'irrecevabilité de l'offre :

- a) l'attestation de l'inspection du travail ;
- b) le bordereau des prix unitaires ;

Considérant que relativement à ces manquements, si l'offre du candidat ne peut pas être écartée pour non présentation de l'attestation de l'Inspection du travail sans qu'il lui soit demandé, conformément à l'article 45 du Code des marchés publics, de fournir ladite pièce, il n'est pas de même pour le bordereau des prix unitaires, document relatif au prix du marché, déterminant les prix applicables à chacune des prestations prévues dans ledit marché, et qui a une valeur contractuelle ; que ce document ne doit pas être confondu avec le devis estimatif, qui lui est dépourvu de valeur contractuelle et dont l'objet est de permettre le versement des acomptes en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

Considérant qu'à cet égard, le candidat n'a pas satisfait aux conditions de conformité de l'offre ; qu'en conséquence, il est mal fondé à contester la décision rendue à cet effet par la Commission des marchés ;

3) SUR LA QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES EN PARTICULIER DE CEUX QUI N'ONT PAS FOURNI LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES SUR LEUR EXPERIENCE ACQUISE DANS LA REALISATION D'ACTIVITES ANALOGUES A CELLE FAISANT L'OBJET DU MARCHE :

Considérant que selon la clause 34.1 des IC, « l'Autorité contractante s'assurera que le candidat ayant soumis l'offre évaluée la moins disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Que la clause 34.3 stipule que l'attribution du marché est subordonnée à la vérification que le candidat satisfait aux critères de qualification ; que dans le cas contraire, l'offre sera rejetée et l'autorité contractante procédera à l'examen de la seconde offre évaluée la moins disante afin d'établir de la même manière si le candidat est qualifié pour exécuter le marché ;

Considérant qu'au regard des critères de qualification fixés, entre autres, le candidat, au titre des références doit fournir une attestation de travaux similaires sur les cinq (5) dernières années ;

Considérant que le candidat Gandiol n'a pas fourni de références relatives à la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché pour la période déterminée par le dossier d'appel d'offres ;

Que le candidat n'a donc pas réuni les critères de qualification requis pour exécuter le marché ; qu'en considération des dispositions des clauses 30.1 et 34.3, il convient de rejeter l'offre du candidat; en conséquence,

DECIDE :

- 16) Déclare recevable le recours de la Société Gandiol ;
 - 17) Constate que Gandiol bien qu'ayant présenté le prix le plus bas sur les lots 1 et 2 du marché n'a pas satisfait aux conditions de conformité de l'offre et aux critères de qualification ; en conséquence,
 - 18) Rejette son recours comme mal fondé ;
 - 19) Ordonne la continuation de la procédure de passation ;
- Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Gandiol, au PRODAM II ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Cette conception est également celle exprimée par la Cour Suprême dans son arrêt n° 11 du 31 mars 2011 : Société Générale de Surveillance (SGS) contre Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), ARMP et Etat du Sénégal.

Les arrêts du Conseil d'Etat Français vont aussi dans le même sens (C.E, 1^{er} avril 1994, SA, Etablissement J. Richard DUCROS – C.E., 6 avril 2007, Département de l'Isère, n° 298584 – C.E. 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse, Contrats et Marchés Publics, Juin 2006, n° 165).

III. CARACTERE SUBSTANTIEL DE LA MENTION DU MONTANT DE L'OFFRE SUR LA LETTRE DE SOUMISSION ET IMPORTANCE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Il résulte de l'article 54 de la directive n° 04/2005/CM/UEMOA et de l'article 11 du code des marchés publics que la soumission est un acte signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché.

Donc, la non indication par le soumissionnaire du montant de son offre sur la lettre de soumission est une omission substantielle entraînant le rejet de l'offre. C'est pourquoi, le CRD rejette le moyen du requérant selon lequel l'omission du montant de l'offre sur la lettre de soumission, suppléé par les autres documents de l'offre, en l'occurrence les offres financières y annexées, ne constitue pas une divergence substantielle au regard des dispositions relatives aux instructions aux soumissionnaires.

**DECISION N° 027/11/ARMP/CRD DU 23 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE COMPLEXE
INDUSTRIELLE THIARE GUEYE (CITG) CONTESTANT LE REJET DE SON
OFFRE PRODUITE DANS LE CADRE DES MARCHES RELATIFS A
L'EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSES ET BLOCS ADMINISTRATIFS DANS
LES DEPARTEMENTS DE KEBEMER, FATICK, FOUNDIOUGNE, LINGUERE ET
DIOURBEL LANCES PAR L'AGETIP.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 13 janvier 2011 de la société CITG ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, de Monsieur Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, René Pascal DIOUF, chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et les moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire du 13 janvier 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 041/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la société Complexe Industrielle Thiaré Guèye (CITG) a introduit un recours auprès du CRD pour contester le rejet de son offre portant sur les appels d'offres suivants lancés par AGETIP :

1. appel d'offres n°099/10 relatif à l'équipement de 130 salles de classes et 24 blocs administratifs dans le Département de Kébemer,
2. appel d'offres n°103/10 relatif à l'équipement de 213 salles de classes et 28 blocs administratifs dans les Départements de Fatick et Foundiougne,
3. appel d'offres n°100/10 relatif à l'équipement de 178 salles de classes et 22 blocs administratifs dans le Département de Linguère,
4. appel d'offres n°098/10 relatif à l'équipement de 126 salles de classes dans la Région de Diourbel.

SUR LA RECEVABILITE:

Considérant qu'aux termes des articles 86 et 87 du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié, tout candidat à une procédure d'attribution est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d'un recours gracieux, soit le CRD ;

Considérant que la société CITG a introduit, par lettre en date du 7 janvier 2011, un recours gracieux auprès de l'autorité contractante le jour de la parution de l'avis d'attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » ;

Considérant que non satisfait de la réponse à son recours gracieux notifiée par lettre datée du 12 janvier, le requérant a introduit une requête auprès du CRD par lettre en date du 13 janvier 2011, enregistrée le même jour sous le numéro 041/11 pour contester le rejet injustifié de son offre ;

Que le recours exercé dans les délais prescrits doit être déclaré recevable.

LES FAITS

L'AGETIP a lancé respectivement dans le journal « Le Soleil » des 17 et 18 août 2010, quatre (4) avis d'appel d'offres portant, d'une part, sur l'équipement de salles de classes et blocs administratifs dans les départements de Kébémér et Linguère et dans la région de Diourbel et, d'autre part, sur l'équipement de salles de classes et blocs administratifs dans les départements de Fatick et Foundiougne ;

L'ouverture des plis a eu lieu le jeudi 16 septembre 2010 pour les marchés des départements de Linguère, Kébémér et Diourbel et le 21 septembre 2010 pour le marché relatif aux départements de Fatick et Foundiougne ;

A la fin des opérations d'évaluation des offres, la commission des marchés a publié un avis d'attribution provisoire relativement à chaque marché ;

La société CITG a introduit un recours gracieux, puis a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester le rejet de ses offres fournies dans le cadre des quatre (4) marchés.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa requête, la société CITG soutient que la commission des marchés ne lui a remis que les procès verbaux de dépouillement des marchés de Foundiougne et Fatick, à l'exception de ceux de Diourbel, Linguère et Kébémér, alors que cette remise constitue une obligation édictée par le Code des marchés publics modifié ;

Il déclare également que MM Ibra Seck et Idrissa WADE dont les noms figurent sur le procès verbal d'ouverture des plis n'ont pas participé à ladite séance ;

Par ailleurs, la commission des marchés lui reproche à tort d'avoir violé les dispositions de la clause 12.1 des Instructions aux candidats suite à l'absence d'indication du montant de sa proposition financière sur ses lettres de soumission produite sur chaque marché ;

Selon lui, la décision de rejet de son offre par la commission des marchés n'est pas fondée puisqu'en référence à la clause 30 des Instructions aux candidats, l'Acheteur peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence substantielle par rapport aux conditions de l'appel d'offres ;

Dès lors, l'AGETIP devait solliciter dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité des offres fournies ;

Par ailleurs, le requérant se plaint de la rupture du principe d'équité du fait que l'entreprise ESEDIC a été déclarée attributaire du lot 3 du marché relatif à l'équipement de 213 salles de classe et 28 blocs administratifs dans les départements de Fatick et Foundiougne, alors que ce dernier n'a pas présenté de copies de son offre ;

SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Au motif du rejet de l'offre du requérant, l'AGETIP apporte les précisions suivantes :

1. lors de l'ouverture des plis, il a été constaté que la lettre de soumission du requérant n'a ni mentionné le montant de l'offre, ni porté le cachet permettant d'identifier le candidat ; en conséquence, la commission des marchés a déclaré non-conforme l'offre du requérant au motif que les dispositions de l'article 11.1.a des Instructions aux candidats ont été violées ;
2. sur le refus de la commission des marchés de délivrer les procès verbaux d'ouverture des plis, l'autorité contractante déclare qu'elle n'a été saisie à aucun moment d'une telle demande par le requérant ; il s'y ajoute que la copie manuscrite du tableau d'ouverture des plis concernant l'appel d'offres relatif à l'équipement de salles de classes et blocs administratifs dans les Départements de Fatick et Foundiougne lui a été communiquée le même jour;
3. pour ce qui concerne l'absence de certains membres de la commission des marchés, l'AGETIP affirme le contraire et renvoie le CRD à la feuille de présence jointe en annexe au procès verbal d'ouverture des plis ;

In fine, l'AGETIP déclare que la procédure de passation des quatre (4) marchés a reçu l'avis favorable de l'organe chargé du contrôle a priori.

L'OBJET DU LITIGE

Considérant qu'il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :

1. la validité d'une lettre de soumission sur laquelle n'est pas mentionné le montant de l'offre financière du candidat ;
2. la non production par l'attributaire de copies de son offre ;
3. la non transmission du procès verbal d'ouverture des plis par la commission des marchés ;
4. la sincérité du procès verbal sur lequel l'autorité contractante aurait ajouté des prénoms et noms de personnes qui n'ont pas participé à l'ouverture des plis.

AU FOND

- 1) Sur le défaut d'inscription du montant de l'offre financière sur la lettre de soumission du candidat :

Considérant que selon les articles 54 de la Directive n°4/2005/CM/UEMOA et 11 du Code des Marchés publics, les marchés passés après mise en concurrence comprennent une soumission, acte signé par le candidat qui présente son offre et adhère aux dispositions du marché. Cet acte, établi, après signature par la personne responsable du marché, l'engagement contractuel des deux parties ;

Considérant que selon les dispositions de la clause 30.1 des Instructions aux soumissionnaires, l'Acheteur établira la conformité de l'offre sur la base de son seul contenu ; qu'à cet égard, une offre conforme pour l'essentiel est celle qui respecte toutes les stipulations, spécifications et conditions du DAO, sans divergences, réserves ou omissions substantielles ;

Sont considérées comme divergences, réserves ou omissions substantielles celles qui :

- a) limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes ; ou
- b) limitent d'une manière substantielle et non-conforme au DAO, les droits de l'Acheteur ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ; ou
- c) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel ;

Considérant qu'en application de cette clause, l'Acheteur écartera toute offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel au DAO et le soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle ;

Considérant que selon les dispositions des clauses 11.1.a et 12.1. des Instructions aux candidats des DAO des marchés susvisés, il est exigé des candidats la production d'une lettre de soumission qui sera remplie de manière à fournir tous les renseignements demandés, conformément au formulaire fourni à la Section IV dudit DAO ;

Qu'à cet égard, la clause 14 des Instructions aux candidats prévoit que le montant à indiquer sur la lettre de soumission sera le prix total de l'offre et devra mentionner le prix global ainsi que tout rabais éventuel, proposé par le candidat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code des Obligations civiles et commerciales, les dispositions des obligations civiles et commerciales relatives au régime juridique des offres sont applicables aux contrats administratifs, sauf les règles spéciales imposées par le présent code et les textes législatifs et réglementaires aux offres intervenant au cours d'une procédure d'appel d'offres ;

Considérant que selon le Code des Obligations de l'Administration, l'offre est une proposition ferme et précise de contracter, ayant vocation à emporter la formation du contrat par la seule survenance d'une acceptation ; que par conséquent, l'offrant doit fixer l'objet du marché et les conditions financières ; que n'est pas une offre, celle qui ne fixe que l'objet du marché envisagé, et non son prix ;

Considérant que ce manquement constitue une omission substantielle dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres candidats ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel, en référence à la clause 30.2 du DAO ;

Que si la commission des marchés avait agi autrement, elle aurait rompu le principe d'équité entre les candidats en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle ;

Que pour cette raison, la décision de la commission des marchés est fondée ;

2) SUR L'ABSENCE DE PRODUCTION DES COPIES DE L'OFFRE :

Considérant qu'en référence aux dispositions de la clause 22.1 des Données particulières des Instructions aux candidats, l'offre de chaque candidat doit être établie en un seul original, accompagné de deux (2) copies ;

Considérant que le requérant reproche au soumissionnaire ESEDIC, déclaré attributaire du marché relatif à l'équipement de 213 salles de classe et 28 blocs administratifs dans les Départements de Fatick et Foundiougne, d'avoir produit uniquement l'original de son offre en l'absence de toute copie ;

Considérant que la présentation du nombre de copies exigées a pour objectif de faciliter l'évaluation des offres par la commission des marchés ;

Qu'à cet égard, le non respect des formalités liées cette exigence n'altère pas la substance de l'offre et ne porte atteinte ni à la recevabilité de l'offre ni à sa conformité, en référence à la clause 30.2 du DAO;

3) SUR LA NON TRANSMISSION DU PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS :

Considérant que selon les dispositions de l'article 67.4 du Code des Marchés publics, dès la fin des opérations d'ouverture des plis, un procès verbal dressé et signé par la commission des marchés est remis à tous les candidats ;

Considérant que le requérant reproche à la commission des marchés la violation de cette exigence, notamment le défaut de transmission aux candidats du procès verbal d'ouverture des plis pour les marchés relatifs à l'équipement de salles de classes et blocs administratifs dans les Départements de Kébémér, Linguère et dans la Région de Diourbel ;

Considérant que le requérant déclare avoir reçu les résultats de l'ouverture des plis de l'appel d'offres relatif à l'équipement de 213 salles de classes à Fatick et Foundiougne, ce qui n'est pas le cas des trois autres marchés dont l'ouverture des plis a eu lieu le 16 septembre 2010 ;

Considérant que la commission des marchés a finalisé la rédaction des procès verbaux de la séance d'ouverture des plis desdits marchés à la date du 17 septembre 2010 au lieu du 16 septembre 2010, date effective de la tenue de ladite séance ;

Considérant que ce manquement a poussé l'AGETIP à effectuer des corrections sur les procès verbaux susvisés, provoquant un défaut de fiabilité des informations consignées ;

Considérant d'autre part qu'en réponse à cette reproche, l'AGETIP explique dans son courrier datée du 21 janvier 2011, son attitude par l'absence d'une demande de transmission desdits procès verbaux par le requérant ;

Qu'à ce propos, elle déclare que cette exigence a été d'ailleurs remplie par lettre datée du 12 janvier 2011 en réponse au recours gracieux du requérant ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 67.4 du Code des Marchés publics que dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la commission des marchés est tenue de remettre aux candidats, le procès verbal de la séance consignant toutes les informations ;

Considérant que l'inobservation de cette formalité est de nature à porter atteinte à la transparence du processus en privant les candidats d'éléments de preuve ;

Considérant cependant que le requérant n'a pas subi de préjudice du fait de la non transmission desdits procès verbaux d'ouverture des plis et ne l'a pas empêché d'exercer son droit de recours devant le CRD ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas être déclaré attributaire par la commission des marchés du fait de la non-conformité de son offre ;

Qu'en considération de cet élément, il n'y a pas lieu de statuer comme il est demandé ;

4) SUR LA NON PRESENCE DE CERTAINS MEMBRES DE LA COMMISSION DES MARCHES A LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS :

Considérant que selon l'article 35 du Code des Marchés publics modifié, la commission des marchés est chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution des marchés ;

Considérant que le requérant soutient que Messieurs Ibra Seck et Idrissa WADE dont les noms figurent sur le procès verbal d'ouverture des plis n'ont pas participé à la séance d'ouverture des plis alors qu'ils sont membres de la commission des marchés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmises par l'AGETIP, qu'en sus des autres membres de la commission des marchés, les noms et signatures des sus nommés ont été consignés aussi bien sur le procès verbal d'ouverture des plis que sur la feuille de présence ;

Que la preuve contraire n'est pas établie ;

DECIDE :

- 20) Déclare recevable la requête introduite par la société CITG ;
- 21) Constate que le requérant n'a pas indiqué le montant de son offre sur la lettre de soumission ;
- 22) Dit que ce manquement constitue une omission substantielle qui entraîne le rejet de l'offre ;
- 23) Dit que le défaut de production du nombre de copies exigé n'altère pas la substance de l'offre et ne porte pas atteinte à sa recevabilité ;
- 24) Dit que la non transmission du procès verbal d'ouverture des plis dans les formes indiqués à l'article 67.4 du Code n'a pas empêché le requérant d'exercer son droit de recours ;
- 25) Constate que, d'une part, les surcharges irrégulières opérées sur la date d'ouverture des plis ne rendent pas fiables les informations consignées sur les procès verbaux, d'autre part, la non transmission des procès verbaux aux candidats ne satisfait pas aux dispositions de l'article 67.4 du Code des Marchés publics ; que malgré tout,
- 26) Dit que ces manquements n'ont pas empêché le requérant d'exercer son droit de recours devant le CRD ;
- 27) Dit qu'au regard des informations consignées sur le procès verbal d'ouverture des plis et sur la feuille de présence, Messieurs Ibra Seck et Idrissa WADE ont participé au dépouillement des offres;
- 28) Dit que la preuve contraire n'est pas établie ;
- 29) Ordonne la continuation de la procédure ;
- 30) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société CITG, à l'AGETIP ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Cette conception a été confirmée par la Cour Suprême (arrêt n° 01 du 9 février 2012 – Complexe Industriel Thiaré GUEYE contre CRD de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)) qui a jugé qu’en « se fondant sur l’article 54 de la décision n° 04 de l’UEMOA et sur les articles 14 et 30.1 relatifs aux instructions aux candidats, le CRD en a exactement déduit que l’obligation de mention du montant de l’offre sur la lettre de soumission est une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne le rejet de l’offre »).

En France, le code des marchés publics stipule en son article 11, alinéas 2 et 3 :

« Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l’acte d’engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.

L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans lequel le candidat présente son offre sur sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur ».

La doctrine française pense que « l’acte d’engagement est la pièce fondamentale et hiérarchiquement la plus importante d’un marché public qui prévaut en cas de contradiction entre les différentes pièces du marché. Il cristallise les parties, l’objet, le prix et la durée, conditions de validité essentielles applicables à tous les contrats ».

Comme la doctrine, la jurisprudence française va dans le même sens que celle sénégalaise (CE, 14 janvier 1998, req. N° 154929, Commune de Saint Pierre (Réunion) contre M. Pihouée).

Le Conseil d’Etat va plus loin en estimant même qu’en l’absence d’acte d’engagement régulièrement signé, la proposition doit être rejetée (C.E., 3 novembre 1997, req. N°148150, Préfet de la Marne contre Commune de Francheville).

IV. REJET DES OFFRES NON CONFORMES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Il résulte de la combinaison des articles 68 et 69 du code des marchés publics que la commission des marchés, après avoir déterminé si les candidatures sont recevables ou non, doit déterminer si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison.

Ainsi, n'est pas pertinent l'argument du requérant qui sollicite l'annulation de la procédure de passation de marché au motif que, la Commission des marchés, avant de rejeter son offre aurait dû demander des précisions sur sa teneur, alors que ladite offre n'est pas conforme aux spécifications définies dans le cahier des charges.

C'est pourquoi par décision numéro 22 du 9 février 2011 (groupement d'entreprises FI, FGT SAU contre SAED), le CRD a déclaré non fondé la requête en annulation du groupement concerné. Le CRD a précisé qu'en vertu de l'article 69 du code des marchés publics, la commission, qui a rejeté l'offre du requérant non conforme « ne peut demander des précisions sur la teneur des offres que si celles-ci présentent des caractéristiques identiques ou équivalentes aux spécifications demandées ».

S'y ajoute le fait que ladite demande n'est pas une obligation mais une simple possibilité donnée à la Commission.

**DECISION N° 022/11/ARMP/CRD DU 09 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT
D'ENTREPRISES FI/FGT SAU CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE A
L'APPEL D'OFFRES LANCE PAR LA SAED PORTANT FOURNITURE DE
DIVERS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECHANIQUES DESTINES
AUX STATIONS DE POMPAGES DES PERIMETRES DE HAMADY OUNARE,
ORKADIERE ET A L'OUVRAGE DE DIOULOL**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ; notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 05 janvier 2011 du Groupement d'entreprises FI/FGT SAU ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Oumar SARR, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, et de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Mamadou DEME, Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 05 janvier 2011, enregistrée le 06 janvier 2011 sous le numéro 009 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Groupement d'entreprises FI/FGT SAU a saisi le CRD d'un recours contestant le rejet de son offre relative à la fourniture de divers équipements électriques et électromécaniques destinés aux stations de pompes des périmètres de Hamady Ounare, Orkadière et à l'ouvrage de Dioulol.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Le 24 décembre 2010, la SAED a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » l'attribution du marché relatif à la fourniture de divers équipements électriques et électromécaniques destinés aux stations de pompes des périmètres de Hamady Ounare, Orkadière et à l'ouvrage de Dioulol.

Le 27 décembre 2010, le GE/FI/FGT SAU lui a adressé un recours gracieux aux fins de réexamen de sa décision.

Le 05 janvier 2011, le Groupement a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre.

Considérant que l'autorité contractante n'a pas donné suite au recours gracieux du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Code des marchés publics, en l'absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant peut introduire un recours devant le CRD dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de l'expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l'autorité contractante pour répondre au recours gracieux qui lui a été présenté ;

Considérant que la saisine du CRD est intervenue dans le délai prescrit, il convient de déclarer recevable le recours du Groupement ;

LES FAITS :

Dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples du bassin du Fleuve Sénégal (PGIRE), la SAED a lancé un appel public à concurrence qui a été publié :

- au Sénégal dans le journal quotidien « Le Soleil » du 28 juin 2010 ;
- au Mali dans le journal quotidien « L’Essor » du 28 juin 2010 ;
- en Mauritanie dans le journal « L’Horizon » du 28 juin 2010 ;
- en Guinée dans le journal « Lynx » du 05 juillet 2010.

A l’ouverture des plis, comme en atteste le procès verbal en date du 26 août 2010, quatre offres ont été reçues des candidats EQUIP PLUS, RMT/CLEMESSY, Groupement d’entreprise FI/FGT SAU et SAHE.

Suivant procès verbal en date du 14 octobre 2010, la Commission des marchés a proposé l’attribution provisoire du marché au candidat SAHE pour la somme de 1 129 096 249 F CFA.

Le 24 décembre 2010, donnant suite à la proposition de la Commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » l’attribution du marché au candidat SAHE.

Le 27 décembre 2010, le GE/FI/FGT SAU lui a adressé un recours gracieux aux fins de réexamen de sa décision.

Le 05 janvier 2011, le Groupement a saisi le CRD pour contester le rejet de son offre.

LES MOYENS PRESENTES A L’APPUI DU RECOURS :

A l’appui de sa réclamation, le requérant a soutenu avoir satisfait à toutes les conditions du règlement de l’appel d’offres, notamment les spécifications indiquées à l’article 9.2.6 du bordereau des quantités qui ont exigé que la commande de la vanne soit assurée par une colonnette par commande à vis ou crémaillère, généralement manœuvrés à l’aide de volant ou de bouche à clé ». Or ces deux options sont des commandes manuelles, c’est-à-dire non motorisées.

A cet égard, l’autorité contractante pouvait, conformément à la clause 31.2 du règlement de l’appel d’offres, lui demander « la documentation nécessaire pour remédier aux omissions non essentielles dans l’offre en rapport avec la documentation demandée ».

MOTFS INVOQUES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre n°00303/SAED/DAIH du 01^{er} février 2011, de transmission des documents de l'appel d'offres au CRD, le Directeur général de la SAED a soutenu qu'à l'évaluation détaillée des offres techniques, il a été relevé que les vannes proposées par GE/FI/FGT/SAU ne sont pas à commande motorisée et donc ne sont pas conformes aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges notamment à l'article 9.2.6 de la section VI intitulée « Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Plans, Inspection et Essais ». ;

Par ailleurs, l'autorité contractante a exposé que les cadres et pelles proposés sont en fonte, alors que selon les exigences du cahier des charges elles doivent être en inox ;

Qu'accepter telles quelles les offres du Groupement porterait préjudice aux intérêts des autres candidats qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel (cf. article 30 des Instructions aux soumissionnaires et 30.2 c)

OBJET DU LITIGE

Considérant qu'il résulte des faits, moyens et motifs présentés par les parties, que le litige porte sur :

- la conformité de l'offre du requérant aux spécifications techniques demandées.
- les prérogatives de la Commission des marchés de demander des précisions aux candidats sur la teneur de leurs offres ;

AU FOND

SUR LA CONFORMITE DE L'OFFRE DU REQUERANT AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES :

Considérant qu'il résulte du rapport d'évaluation des offres que la Commission des marchés a écarté l'offre du requérant aux motifs que les vannes de GE/FI/FGT/SAU ne sont pas conformes aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges ; qu'elles ne sont pas motorisées et que les cadres et pelles proposés sont en fonte ;

Considérant que le requérant a soutenu qu'il est disposé au paragraphe 3 de la clause 9.2.6 des spécifications techniques que « *la commande de la vanne est assurée par une colonnette par commande à vis ou à crémaillère qui sont généralement manœuvrés à l'aide de volant ou bouche à clé* » ; que ces deux options sont des commandes manuelles, c'est-à-dire non motorisées ;

Considérant que selon les stipulations de la clause 9.2.6 de la section VI intitulée « Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Plans, Inspection et Essais », consacrée aux vannes murales que celles-ci doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

Cadre et pelle en Inox ;

- Protection par peinture brai époxy ;
- Double étanchéité amont-aval ;
- Détecteur de position pour un système d'automatisation ;
- Commande motorisée 220V ou 380V ;
- Capteurs de position ;
- Limiteur de couple.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que comme l'a soulevé le requérant, le paragraphe 3 donne une description de la commande de la vanne qui est assurée par une colonnette par commande à vis ou à crémaillère qui sont généralement manœuvrés à l'aide de volant ou bouche à clé, les dispositions suivantes de la même clause précisent les caractéristiques techniques de la commande dont le cadre et la pelle doivent être en inox et la commande motorisée 220V ou 380V ;

Qu'à cet égard, il est constant que les vannes proposées par le requérant ne sont pas à commande motorisée et que le cadre et la pelle n'étaient pas en inox comme il est indiqué dans le cahier des charges ;

Qu'en considération de ces éléments, la Commission des marchés a déclaré l'offre du Groupement non conforme aux spécifications données par le cahier des charges ;

Considérant que sur ce point, le requérant a opposé à la Commission des marchés les stipulations de la clause 31.2 selon lesquelles, l'autorité contractante pouvait lui demander « la documentation nécessaire pour remédier aux omissions non essentielles constatées dans l'offre en rapport avec la documentation demandée »

SUR LES PREROGATIVES DE LA COMMISSION DES MARCHES DE DEMANDER DES PRECISIONS AUX CANDIDATS :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 du Code des marchés publics, la Commission des marchés, après avoir statué sur la recevabilité des candidatures, détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;

Considérant que suite aux constatations que les vannes de ne sont pas conformes aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges notamment à l'article 9.2.6 de la section VI intitulée « Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Plans, Inspection et Essais » ; que les cadres et pelles ne sont pas en inox et que la commande n'est pas motorisée, la Commission a écarté l'offre du soumissionnaire sans que ne lui soit demandé des précisions sur la teneur de son offre ;

Considérant que selon les dispositions in fine de l'article 69 du Code des marchés publics, la commission des marchés peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison ;

Considérant qu' il résulte de cette disposition que la Commission des marchés ne peut demander des précisions sur la teneur des offres que si celles-ci présentent des caractéristiques identiques ou équivalentes aux spécifications demandées ; que dès lors que la Commission des marchés a relevé des différences entre l'offre du soumissionnaire et ce qui est demandé, elle n'est pas alors tenue de demander des précisions sur la teneur de son offre qui n'est pas, du fait de la différence constatée, conforme ;

Qu'en revanche, le fait pour le candidat d'avoir constaté ce qu'il a cru être une contradiction entre des éléments des spécifications techniques, donnait à celui-ci la faculté de demander des éclaircissements à l'autorité contractante ; qu'une telle demande de sa part aurait eu le mérite de faciliter la compréhension des stipulations du cahier des charges et éviter de faire des offres susceptibles d'entrer en contradiction avec les spécifications techniques définies dans le cahier des charges ;

Qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de dire que l'offre du requérant n'est pas conforme aux exigences du cahier des charges, en conséquence,

DECIDE :

- 31) Déclare le Groupement d'entreprises FI/FGT SAU recevable en son recours ;
- 32) Constate que son offre n'est pas conforme aux spécifications techniques relatives au cadre et à la pelle qui doivent être en inox ainsi que la commande qui doit être motorisée ; en conséquence ;
- 33) Rejette la demande du Groupement ;
- 34) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché ;
- 35) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au Groupement d'entreprises FI/FGT SAU, à la SAED ainsi qu'à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

V. OBLIGATION DE PRODUIRE LES PIECES EXIGEEES PAR LE CAHIER DES CHARGES

A la suite de la décision n° 97/09/ARTP/CRD du 18 novembre 2009 du CRD ordonnant la reprise de l'appel d'offres relative à la fourniture d'un scanner de 64 coupes à détecteur multi barrettes lancé par l'hôpital Principal de Dakar, ce dernier a procédé à un nouvel appel à la concurrence qu'il a fait publier dans les journaux.

Au terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés a attribué le marché à Carrefour Médical et a publié l'avis d'attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » en date du 7 juin 2010. Après avoir introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante, la société CERTEC a saisi le CRD d'une requête en annulation de la décision d'attribution du marché, en faisant valoir que l'attribution du marché à Carrefour Médical est irrégulière parce qu'il y a eu violation des stipulations du cahier des charges.

Son recours a été déclaré mal fondé par le CRD qui a estimé, entre autres, que d'une part, la commission des marchés a respecté les dispositions de la clause 5.1 des instructions aux candidats exigeant des candidats qu'ils fournissent l'autorisation de mise sur le marché, non pas lors du dépôt des offres, mais au moment de la livraison du produit et d'autre part, le dossier d'appel d'offres n'a pas prévu de critères d'évaluation du personnel affecté au service après vente et du matériel requis pour les opérations de maintenance.

DECISION N° 088/10/ARMP/CRD DU 07 JUILLET 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE LA SOCIETE CERTEC. SA CONTESTANT L'ATTRIBUTION A LA SOCIETE CARREFOUR MEDICAL DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE D'UN SCANNER DE 64 COUPES A DETECTEUR MULTI BARETTES LANCE PAR L'HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CERTEC.SA du 14 juin 2010, enregistré le 16 juin 2010 sous le numéro 410/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd'El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Youssouf SAKHO, Directeur Général de l'ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire du 14 juin 2010, enregistrée le 16 juin 2010 sous le numéro 410/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société CERTEC.SA a introduit un recours en annulation de la décision d'attribution du marché portant sur la fourniture d'un scanner de 64 coupes à détecteur multi barrettes lancé par l'Hôpital Principal de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'au terme des articles 86 et 87 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, tout candidat à une procédure d'attribution est habilité à saisir soit la personne responsable du marché d'un recours gracieux, soit le CRD ;

Considérant que la société CERTEC SA a saisi par courrier du 9 juin 2010, l'Autorité contractante d'une demande de communication des motifs ayant conduit au choix de l'attributaire, deux jours ouvrables après la parution de l'avis d'attribution du marché dans le journal « Le Soleil » en date du 7 juin 2010 ;

Considérant que non satisfait de la réponse apportée par l'autorité contractante par lettre datée du 10 juin 2010, le requérant a introduit devant le secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) un recours par courrier en date du 14 juin 2010, enregistré le 16 juin 2010 sous le numéro 410/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Que le dit recours étant exercé dans les délais prescrits, il doit être déclaré recevable.

LES FAITS

A la suite de la décision n° 097/09/ARMP/CRD du 18 novembre 2009 du CRD ordonnant la reprise de l'appel d'offres sus visé, l'Hôpital Principal de Dakar a procédé à un nouvel appel à la concurrence qu'il a fait publier dans les journaux suivants :

- Le Soleil des 19 et 20 décembre 2010 ;
- L'Observateur des 19 et 20 décembre 2010 ;
- Le Populaire des 19 et 20 décembre 2010 ;
- Sud Quotidien du 21 décembre 2010.

Au terme de l'évaluation des offres, la Commission des marchés a attribué le marché à Carrefour Médical et a publié l'avis d'attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » en date du 7 juin 2010.

Après avoir introduit un recours gracieux, la société CERTEC SA a saisi le Comité de Règlement des Différends d'une demande de communication des raisons qui ont présidé au choix de l'attributaire.

Par décision n° 074/10/ARMP/CRD du 16 juin 2010, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché sus visé.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa requête, la société CERTEC.SA déclare que l'offre du candidat Carrefour Médical a été irrégulièrement déclarée recevable, conforme et moins disante pour les raisons suivantes :

1. l'offre de l'attributaire ne comporte pas d'autorisation de mise sur le marché et d'attestation de conformité du matériel, en violation respective des clauses 5.1 et 11.1 g) des Instructions aux candidats ;
2. la commission des marchés n'a pas prouvé que l'attributaire dispose de ressources humaines formées par le fabricant pour assurer le service après vente des produits proposés, en référence à l'article 16 du cahier des clauses techniques du dossier d'appel d'offres ;
3. le Directeur de l'Hôpital n'a pas fait prévaloir le principe d'équité entre les candidats en demandant plus de renseignements complémentaires à la société Carrefour Médical sur son offre dans le but de la rendre conforme ;
4. l'article 86 du Code des Marchés publics autorise tout candidat non retenu à poser à l'autorité contractante, des questions relatives aux éléments qui ont fondé l'évaluation de l'offre de chaque concurrent ; par conséquent, en refusant de communiquer les renseignements demandés sur l'offre de l'attributaire du marché, l'autorité contractante a violé le principe de transparence édicté à l'article 69 du Code des Marchés publics et à la clause 28.1 des Instructions aux candidats ;

Compte tenu de tous ces faits constants, la société CERTEC a sollicité l'annulation de la décision d'attribution du marché sus nommé ;

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

En réponse aux arguments soulevés par le requérant, l'autorité contractante note la confusion entretenue par le requérant entre la notion d'autorité contractante avec celle de commission des marchés instituée par le Code des Marchés publics ; en effet, toutes les demandes d'éclaircissement ont été traitées par la commission des marchés de l'établissement, et non par le Directeur de l'Hôpital Principal de Dakar, comme en atteste les différentes correspondances versées au dossier ;

A propos de la première question du requérant portant sur la production par l'attributaire du marché d'une autorisation de mise sur le marché, une réponse lui avait été servie par lettre n°1874/HPD/MC du 24 décembre 2009 l'informant que ledit document est exigé au plus tard à la date de livraison du matériel, en référence à la clause 5.1 des Instructions aux candidats indiquant que le système fourni doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de livraison ;

Il s'y ajoute que cette disposition figurait sur le marché annulé par décision n° 097/09/ARMP/CRD du 18 novembre 2009 du CRD et que le requérant avait toute latitude de saisir l'ARMP avant l'ouverture des plis, aux fins de faire annuler ou rectifier cette disposition du cahier des charges ;

Concernant les autres manquements soulevés par le requérant sur le défaut d'attestation de conformité du matériel et la non disponibilité d'un service après vente efficace, la commission des marchés s'est assurée que l'attributaire a rempli les critères fixés et s'est abstenue de communiquer les renseignements contenus sur une offre concurrente, en référence à l'article 85.3 du Code des Marchés publics qui proscriit toute transmission à un candidat d'informations non publiques sur la situation financière, juridique ou sur les méthodes de fabrication ou de gestion dont la divulgation serait contraire à la loi ou porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes ;

Par ailleurs, la commission des marchés a demandé par écrit, des éclaircissements à chacun des candidats sur la teneur de leur offre en vue d'une évaluation technique optimale sans modifier la nature des offres, conformément à l'article 69 du Code des Marchés publics ;

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :

1) la conformité de l'offre de l'attributaire par rapport aux critères d'évaluation, notamment ceux relatifs à la production de l'autorisation de mise sur le marché, de l'attestation de conformité du matériel et de la disponibilité d'un service après vente efficace ;

2) le traitement jugé inéquitable des demandes de renseignements complémentaires adressées aux candidats ;

3) le refus de la commission des marchés de communiquer à un candidat, des informations portant sur l'offre d'un de ses concurrents ;

AU FOND

- 1) SUR LA CONFORMITE DES CRITERES D'EVALUATION, NOTAMMENT CEUX RELATIFS A LA PRODUCTION DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET DE LA DISPONIBILITE D'UN SERVICE APRES VENTE EFFICACE ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics que la détermination de l'offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères , tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires ;

Considérant qu'après évaluation financière des offres des candidats, les résultats s'établissent comme suit :

NOM CANDIDAT	PRIX DE L'OFFRE A L'OUVERTURE DES PLIS	CORRECTIONS	RABAIS PROPOSES	PRIX DE L'OFFRE CORRIGEE AVEC RABAIS
AFRIMED	670 000 000/HTHD	Néant	Néant	670 000 000/HTHD
BIAMED	690378 598 /DDU	Néant	1% sous conditions non-conformes au DAO	690 378 598 /DDU
CERTEC	634 971 557 HTHD	Néant	Néant	634 971 557 HTHD
CARREFOUR MEDICAL	597 000 000 HTHD	Néant	Néant	597 000 000 HTHD

SUR L'ABSENCE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :

Considérant qu'en référence à la clause 5.1 des Instructions aux candidats, le soumissionnaire doit prouver, document à l'appui, que le système fourni doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de livraison ; en particulier, il devra disposer d'une autorisation de mise sur le marché adaptée à son statut de dispositif d'imagerie à usage en médecine humaine qui sera complétée selon le pays de construction du marquage CE médical européen ou équivalent ;

Considérant que l'objectif visé à travers la production de l'autorisation de mise sur le marché est de vérifier que le produit du fabricant est conforme aux exigences d'une spécification technique ou d'une norme harmonisée grâce à un système de contrôle de production appliqué en usine ; et qu'en cas de dysfonctionnement dudit produit, le fabricant en assume l'entière responsabilité ;

Considérant que bien que cette obligation de fournir un matériel conforme aux normes pèse sur le candidat, la justification de cette exigence par la disponibilité d'une autorisation de mise sur le marché peut se faire non pas lors du dépôt des offres, mais au moment de la livraison, comme le requiert du reste la clause 5.1 des Instructions aux candidats ;

1.1) SUR L'EXISTENCE D'UN SERVICE APRES VENTE DOTE D'UN PERSONNEL QUALIFIE ET DE MOYENS MATERIELS AINSI QUE LA DISPONIBILITE D'UN PROGRAMME DE FORMATION AU PROFIT DES AGENTS DE L'HOPITAL PRINCIPAL :

Considérant que le requérant reproche à la commission des marchés d'avoir retenu la société Carrefour Médical sans pour autant s'assurer de la disponibilité d'un service après vente fonctionnel exigé à la clause 18.1b) des Instructions aux candidats ;

Considérant que la société Carrefour Médical a prévu dans le cadre de l'appel d'offres, un service après vente doté de moyens matériels (parc véhicules, matériel de test complet, divers outillages), de moyens humains et d'un atelier de maintenance ;

Considérant cependant qu'il n'est précisé dans le dossier d'appel d'offres aucun critère de qualification sur le niveau de formation des équipes de maintenance, ni sur les moyens matériels mis en œuvre ;

Considérant qu'en outre, la société Carrefour Médical propose dans son offre :

- a) la formation à l'utilisation du matériel proposé de deux médecins radiologues, trois manipulateurs radio, un ingénieur biomédical et trois techniciens de maintenance,
- b) la formation aux protocoles et logiciels d'application cliniques du personnel utilisateur,
- c) la formation initiale de l'ingénieur biomédical et de deux techniciens locaux pour la surveillance et le diagnostic simple des dysfonctionnements,

- d) la formation des techniciens informaticiens sur la connexion au réseau informatique et la maintenance du logiciel,
- e) la formation sur le site du fabricant ou un site de référence d'un médecin, d'un manipulateur, d'un technicien et d'un ingénieur ;

Qu'après vérification, la commission des marchés a valablement conclu que l'offre de la société Carrefour Médical est conforme aux prescriptions de la clause 18.1b) des Instructions aux candidats et du point 17 des spécifications techniques exigeant l'existence d'un service après vente et la proposition d'un programme de formation du personnel à l'utilisation du matériel ;

2) SUR LE TRAITEMENT JUGE INEQUITABLE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ADRESSEES AUX CANDIDATS :

Considérant que pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des candidats, l'autorité contractante a adressé par lettre à tous les soumissionnaires des demandes d'éclaircissement par courriers respectifs en date du 2 mars 2010 ;

Considérant qu'à cet égard, la commission des Marchés a saisi la société Carrefour Médical pour une demande d'informations sur les points suivants :

- préciser les modalités de la télémaintenance et de la télésurveillance,
- préciser les pièces qui sont couvertes par la garantie de trois ans et spécifier si le tube est inclus dans celle-ci,
- préciser le système de refroidissement utilisé et le niveau de température et d'humidité recommandé pour le tube,
- préciser la taille du foyer du tube,
- préciser le nombre maximal de tours par minutes en mode hélicoïdal et la longueur maximale couverte,
- préciser le modèle d'imprimante papier couleur proposé,
- préciser si la liste indicative des pièces de rechange fournie correspond effectivement à l'équipement proposé (SCENARIO 64) ;

Considérant que selon les dispositions combinées de l'article 69 du Code des Marchés publics et de la clause 28 des Instructions aux candidats, une demande d'éclaircissement dont l'objectif est de préciser la teneur de l'offre du candidat afin d'en préciser le contenu, est une faculté laissée à la libre appréciation de l'Autorité contractante, sous réserve de ne provoquer aucun changement sur les offres ;

Considérant que dans un souci d'objectivité et de transparence, la commission des marchés a, sur proposition du comité technique d'évaluation, sollicité des précisions qui portent essentiellement sur des aspects techniques du matériel proposé et qui ne peuvent en aucun cas, sous toutes réserves, dénaturer ou modifier l'offre de l'attributaire ;

Considérant que ces demandes de précision ont certainement permis à la commission des marchés de se fonder une opinion sur la conformité du matériel proposé sans pour autant le modifier, qu'à cet égard, il ne peut être reproché à la commission d'avoir fait un traitement inéquitable et différencié des candidats ;

3) SUR LE REFUS DE LA COMMISSION DES MARCHES DE COMMUNIQUER AU REQUERANT, DES INFORMATIONS PORTANT SUR L'OFFRE D'UN DE SES CONCURRENTS :

Considérant qu'en référence à l'article 85.1 du Code des Marchés publics, la personne responsable du marché communique par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ;

Considérant que la société CERTEC a sollicité de la commission des marchés, les raisons qui ont fondé le choix de la société Carrefour Médical, attributaire du marché, alors les dispositions de l'article 85.1 du Code des Marchés publics n'autorisent la personne responsable du marché à communiquer aux soumissionnaires que les motifs du rejet de leur propre candidature ou offre ;

Considérant qu'au-delà de cette restriction, la personne responsable du marché ne peut communiquer à un candidat des renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'autres candidats en révélant des informations non publiques sur leur situation financière ou juridique ou sur leurs méthodes de fabrication ou de gestion ;

Considérant également que le refus de l'autorité contractante n'a pas privé la société CERTEC de son droit de recours devant le CRD ; qu'à cet égard, la décision d'attribution du marché doit être maintenue ;

DECIDE :

36) Déclare recevable la requête introduite par la société CERTEC S.A ;

37) Dit que la commission des marchés a respecté les dispositions de la clause 5.1 des Instructions aux candidats exigeant des candidats qu'ils fournissent l'autorisation de mise sur le marché non pas lors du dépôt des offres, mais au moment de la livraison du produit ;

- 38) Constate que le dossier d'appel d'offres n'a pas prévu de critères d'évaluation du personnel affecté au Service après vente et du matériel requis pour les opérations de maintenance ;
- 39) Constate que l'attributaire a proposé un programme de formation, en référence aux dispositions de la clause 18.1b) des Instructions aux candidats et du point 17 des spécifications techniques ;
- 40) Constate que la commission des marchés a sollicité ces informations qui portent essentiellement sur des aspects techniques du matériel proposé, conformément aux dispositions combinées de l'article 69 du Code des Marchés publics et de la clause 28 des Instructions aux candidats ;
- 41) Dit que les dispositions de l'article 85.1 du Code des Marchés publics n'autorisent la personne responsable du marché qu'à communiquer aux candidats, les motifs du rejet de leur propre candidature ou offre ; qu'à cet égard,
- 42) Dit que le refus de l'autorité contractante de répondre à un recours gracieux ne peut constituer un motif d'annulation de la procédure de passation du marché ;
- 43) Déclare mal fondé le recours de la société CERTEC SA ;
- 44) Ordonne la poursuite de la procédure de passation ;
- 45) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société CERTEC, à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

Mais la Cour Suprême, saisie par la société CERTEC d'un recours en annulation, a, par arrêt n° 19 du 3 juin 2011, annulé la décision du CRD en statuant comme suit : « considérant que le cahier des charges , en son point 16, prévoit que : « si le fournisseur n'est pas le constructeur, il devra produire tous certificats d'agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes ; qu'ainsi la décision attaquée, qui a rejeté le recours de la société CERTEC, sans relever la production par l'attributaire provisoire des certificats d'agrément du constructeur et de formation technique de ses équipes, comme exigé par le cahier des charges, encourt l'annulation ».

En France, la Commission d'appel d'offre est tenue de refuser d'admettre les candidats qui ne produisent pas les documents exigés par le règlement de consultation. Le Conseil d'Etat considère aussi que sont irrecevables les offres, certes, déposées dans le délai fixé, mais qui sont incomplètes.

VI. OBLIGATION DE RESPECTER LES PRINCIPES DE TRANSPARENCE DES PROCEDURES ET DE FORMALITES DE PUBLICITE

A la suite de l'avis d'appel d'offres avec pré-qualification publié dans le journal « Le Soleil » les 11 et 15 mai 2009 et portant sur la sélection d'un gestionnaire de l'activité de contrôle technique des véhicules et des ouvrages, le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD a transmis une lettre d'invitation à trois (3) candidats qui ont été déclarés qualifiés à l'issue de cette phase. Au terme de l'évaluation des offres, le CETUD a attribué le marché au Bureau Véritas, puis a notifié aux autres candidats le rejet de leurs offres par lettre datée du 30 novembre 2009.

Dès réception de la notification de l'attribution du marché, la Société Générale de Surveillance (SGS) a demandé à l'autorité contractante les motifs de rejet de son offre, puis a saisi le CRD, qui a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché susvisé. La SGS a soutenu, entre autres moyens, que le CETUD a violé le principe de transparence.

Statuant par décision n° 003 du 11 janvier 2010, le CRD a ordonné la relance de la procédure après redressement du dossier d'appel d'offres aux motifs que, entre autres, en mettant en application des sous-critères de notation qui n'ont pas été portés préalablement à la connaissance des candidats, le CETUD a violé le principe de transparence, en référence à l'article 59 du code des marchés publics, or le non-respect du principe de transparence des procédures et des formalités de publicité entraîne la nullité de la procédure de passation, en application de l'article 24 du Code des Obligations de l'Administration (COA), modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006.

**DECISION N° 003/10/ARMP/CRD DU 11 JANVIER 2010
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE LA SOCIETE GENERALE DE
SURVEILLANCE SA (SGS) CONTESTANT LA DECISION D'ATTRIBUTION POUR
NON APPLICATION DES CRITERES D'EVALUATION CONTENUS DANS LE
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES PORTANT SUR LE MARCHE DE SELECTION
D'UN GESTIONNAIRE DE L'ACTIVITE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES
VEHICULES ET DES OUVRAGES LANCE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DES
TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR (CETUD)**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire en date du 14 décembre 2010 du Ministère de l'Economie Maritime (MEM), enregistrée le 17 décembre 2010 sous le numéro 860/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Ministère de l'Economie Maritime a saisi le CRD d'une demande d'autorisation de sélectionner des cabinets étrangers pour les besoins de l'étude portant sur l'extension du plateau continental du Sénégal, dont le financement est assuré par le budget national.

A l'appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :

- une copie de la lettre de la DCMP n° 5183/MEF/DCMP/22 du 5 novembre 2010 ;
- une copie de la lettre du Ministère de l'Economie maritime de la Pêche et des Transports maritimes n° 869/MEMPT/DAGE/DAA du 27 octobre 2010 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 4215/MEF/DCMP/5 du 9 septembre 2010 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 2360/MEF/DCMP/44 du 31 mai 2010 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 1730/MEF/DCMP/40 du 26 avril 2010 ;
- une copie de la lettre du Ministère de l'Economie maritime de la Pêche et des Transports maritimes n° 279/MEMPT/DAGE/DAA du 15 avril 2010 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 1140/MEF/DCMP/ms du 25 mars 2009 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 975/MEF/DCMP/m du 13 mars 2009 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 884/MEF/DCMP/34 du 3 mars 2010 ;
- une copie de la lettre du Ministère de l'Economie maritime de la Pêche et des Transports maritimes n° 169/MEMPT/DAGE/DAA du 20 mars 2009 ;
- Transports maritimes n° 95/MEMPT/DAGE/DAA du 19 février 2010 ;
- une copie de la lettre de la DCMP n° 525/MEF/DCMP/DCV/BACEP/mad en date du 10 février 2009 ;
- une copie de la lettre du Ministère de l'Economie maritime de la Pêche et des Transports maritimes n° 157/MEMPT/DAGE/DAA du 6 février 2009 ;
- une copie de la lettre de la Présidence de la République n°5940/PR/CAB/MEDC/SP du 19 août 2008 ;
- une copie de la lettre de la Présidence de la République n°5782/PR/CAB/MEDC/SP du 13 août 2008 ;
- une copie du rapport de mission de l'Atelier sous régional sur les limites extérieures du Plateau continental au-delà des 200 milles marins ;
- une copie du compte rendu de réunion du 6 août 2008 ;
- une copie du procès verbal d'ouverture des plis de la Manifestation d'intérêt portant sur l'étude préliminaire pour l'extension du Plateau continental ;
- une copie de la Demande de propositions sur l'étude préliminaire pour l'extension du Plateau continental.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP modifié, en son article 2, donne compétence au CRD à statuer sur les recours relatifs aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le MEM a saisi le Comité de Règlement des Différends par lettre en date du 14 décembre 2010, sollicitant l'autorisation de présélectionner des cabinets étrangers dans le cadre du marché relatif à l'étude préliminaire pour l'extension du plateau continental du Sénégal, dont le financement est assuré sur le budget national ;

Que le recours n'étant soumis à aucun délai, il doit être déclaré recevable.

LES FAITS

En vue de la saisine de la Commission des Limites du Plateau continental des Nations Unies d'une demande d'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des deux cent (200) milles marins, le Ministère de l'Economie Maritime (MEM) a reçu mandat de réaliser une étude préliminaire dont le financement est assuré par les crédits du budget d'investissement 2011.

Après avoir lancé dans le journal « Le Soleil » du 09 juillet 2010 un avis à manifestation d'intérêts, la commission des marchés a déclaré infructueux les résultats de la compétition lors de sa réunion en date du 9 août 2010 ;

Puis, le MEM a sollicité l'avis favorable de la DCMP par lettre en date du 27 octobre 2010 pour ouvrir la compétition à des candidats étrangers.

Après examen, l'organe chargé du contrôle a priori donne un avis défavorable.

Le MEM saisi le CRD d'une demande d'autorisation de procéder par appel d'offres restreint sur la base d'une sélection de cabinets étrangers spécialisés pour ce type de mission.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa demande, le MEM expose qu'à la suite de l'appel à manifestation d'intérêts paru dans le journal « Le Soleil » du 09 juillet 2010, la commission des marchés a reçu deux plis ;

Après évaluation des candidatures, les conclusions ci après ont été dégagées :

1. les qualifications du candidat Pante Entreprise et son personnel ne sont pas conforme sans compter qu'aucune mission similaire n'a été relevée ;
2. la candidature du groupement Tous Travaux Sous Marins (société Sénégalaise) et Abarloa 2 (société Espagnole) n'est pas recevable en référence aux dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics modifié qui réserve la participation aux appels à la concurrence aux seules entreprises communautaires ;

Sur la base de ces conclusions, l'autorité contractante a déclaré infructueux l'avis à manifestation d'intérêts, puis a saisi l'organe chargé du contrôle a priori par lettre en date du 27 octobre 2010 pour procéder à un appel d'offres restreint sur la base d'une présélection de cabinets étrangers ;

A l'appui de sa demande, l'autorité contractante déclare que la réalisation de la mission requiert une expertise avérée qui est inexistante au niveau national, mais disponible dans certains pays comme l'Afrique du Sud, les Etats Unis, le Royaume Uni, le Japon, la Norvège, la France et l'Australie ;

La DCMP a ensuite donné un avis défavorable par lettre datée du 5 novembre 2010 ;

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Au motif de son rejet, la DCMP soutient que le décret n°2010-1188 modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics qui a été adopté le 13 septembre 2010 a procédé à la suppression du dernier alinéa de l'article 52 initial qui autorisait la participation d'entreprises étrangères aux appels d'offres financés sur le budget national lorsque lesdites prestations ne pouvaient être livrées ou réalisées par des entreprises locales ;

Qu'avec cette modification, aucune dérogation n'était permise pour autoriser la participation d'entreprises étrangères sur les marchés financés sur budget national.

Qu'en conséquence, elle ne pouvait donner un avis favorable à pareille requête.

L'OBJET DU RECOURS :

Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée porte sur la demande d'autorisation du MEM d'ouvrir l'accès du marché aux entreprises étrangères non communautaires en dépit des restrictions imposées par l'article 52 nouveau du Code des Marchés publics.

AU FOND :

Considérant que le MEM a lancé dans le journal « le Soleil » dans son édition du 09 juillet 2010, un avis à manifestation d'intérêts pour la réalisation d'une étude préliminaire pour l'extension du plateau continental du Sénégal au-delà des 200 milles marins ;

Qu'après évaluation des deux candidatures reçues, la commission des marchés a déclaré infructueux l'avis à manifestation d'intérêts en raison de l'irrecevabilité de la première offre puisqu'il s'agit d'une entreprise étrangère, et de la non-conformité du deuxième dossier présenté par le candidat PANTE ENTREPRISE ;

Considérant qu'il apparaît des dispositions de l'article 52 nouveau du décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics que l'alinéa 2 de l'ancien article 52 n'a pas été repris par le nouvel article, écartant ainsi toute possibilité à l'autorité contractante de recourir à des candidatures étrangères lorsque les prestations demandées ne peuvent pas être réalisées par des entreprises communautaires ;

Qu'en effet, la disposition supprimée ou omise disposait que « toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent en application d'accords internationaux ou lorsque qu'il s'agit de fournitures, travaux ou services ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 nouveau du Code des obligations de l'Administration, l'acheteur public doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Que l'article 28 nouveau dispose que « par dérogation au principe de l'égalité de traitement, une préférence peut être attribuée lors de la passation d'un marché aux offres portant sur des fournitures, services ou travaux d'origine ou de fabrication sénégalaise présentés par une entreprise nationale dans les conditions et limites déterminées par le Code des marchés public et dans le respect des dispositions des traités et accords internationaux conclus par la République du Sénégal »

Considérant qu'en application de cette disposition, la Section 5 du chapitre 2 titre III du Code des marchés, intitulés : « Régimes préférentiels » a prévu à l'article 52 que « la participation aux appels à la concurrence et aux marchés publics de prestations-et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un desdits Etats » ;

Considérant qu'il ressort de ces articles que la dérogation prévue à l'article 28 du Code des obligations de l'Administration et, à son application, par l'article 52 du Code des marchés publics, ne s'applique pas :

- 1) lorsqu'un accord international y déroge ; ou,
- 2) lorsqu'à contrario, les fournitures, services ou travaux ne sont pas d'origine ou de fabrication sénégalaise présentés par une entreprise nationale ou communautaire, autrement dit lorsque les fournitures, travaux ou services objet de la commande publique ne peuvent pas être livrés ou réalisés par des entreprises locales ;

Que donc la disparition de l'alinéa 2 de l'article 52 ancien, que tout semble laisser croire qu'il s'agit d'une omission car ni les travaux préparatoires aux modifications apportées au Code ni le rapport de présentation du nouveau décret ne l'ont évoqué dans le sens de sa suppression, ne peut faire échec aux dispositions de l'article 28 du Code des obligations de l'Administration qui elles mêmes constituent une dérogation aux principes de la liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

Que surabondamment, même si l'avis de la DCMP serait fondé, force est de constater que lui donner application risquerait de créer un blocage relativement à l'exécution de certains projets et programmes dont la mise en œuvre ne peut être réalisée par des entreprises nationales, ce qui constituerait une atteinte à la vocation du code qui est de faciliter aux autorités contractantes l'acquisition des biens ou la réalisation de service ou travaux en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général ;

Qu'une telle autorisation ne serait pas contraire aux principes fondamentaux applicables aux achats publics énoncés à l'article 24 du Code des obligations de l'Administration modifié, notamment à savoir, la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures ;

Qu'à cet égard,

DECIDE :

- 1) Constate que le marché susvisé est financé sur les crédits du budget d'investissement 2011 du Ministère de l'Economie Maritime ;
- 2) Dit qu'en vertu de l'article 28 du Code des obligations de l'administration, la suppression ou l'omission de l'alinéa 2 de l'article 52 ancien ne constitue pas un empêchement au recours aux entreprises étrangères lorsque les fournitures, travaux ou services objet de la commande publique ne peuvent pas être livrés ou réalisés par des entreprises locales ;
- 3) Dit que, dans le cas d'espèce, il y a lieu d'autoriser la participation d'entreprises étrangères pour le marché concerné qui ne peut être livré ou réalisé par des entreprises locales ;
- 4) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l'Economie Maritime et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

**DECISION N° 011/11/ARMP/CRD DU 19 JANVIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE LA PHARMACIE NATIONALE
D'APPROVISIONNEMENT RELATIVE A L'OUVERTURE DE L'APPEL
D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS GENERIQUES,
MATERIELS ET CONSOMMABLES PHARMACEUTIQUES, REACTIFS DE
LABORATOIRE, VACCINS, PRODUITS DENTAIRE ET MEDICAMENTS ANTI
RETROVIRAUX AUX ENTREPRISES ETRANGERES NON COMMUNAUTAIRES**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 02920/MSP/PNA/SAF du 01^{er} décembre 2010 du Directeur général de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement. ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller juridique, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, MM. Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire en date du 1^{er} décembre 2010, enregistrée le 31 décembre 2010 sous le numéro 885/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Directeur général de la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (PNA.) a saisi le CRD d'une demande d'éclairage sur l'article 52 du décret n°2019-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la saisine de la PNA fait suite à l'avis défavorable émis par la DCMP sur le dossier d'appel d'offres relatif à l'achat de médicaments génériques, matériels et consommables pharmaceutiques, réactifs de laboratoire, vaccins, produits dentaires et médicaments anti rétroviraux ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 138 et 139 du Code des marchés publics que, lorsque l'avis ou la recommandation concerne la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou est relative à la proposition d'attribution du marché, l'autorité contractante qui n'accepte pas ledit avis ou ladite recommandation peut saisir le CRD dans un délai de trois (3) jours suivant sa réception ;

Qu'a contrario, en dehors de ces hypothèses, lorsque l'avis ou la recommandation formulée par la DCMP porte sur l'utilisation de l'appel d'offres ouvert ou sur le dossier d'appel d'offres, la saisine du CRD n'est enfermée dans aucun délai ;

Qu'en considération de ces éléments, il convient de déclarer recevable la présente saisine, improprement qualifiée de demande d'éclairage des dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics ;

LES FAITS

Par lettre n°02411/MSP/PNA/DIR du 24 septembre 2010, la PNA a soumis à la DCMP pour avis le projet de dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture de médicaments essentiels génériques, matériels et consommables pharmaceutiques, réactifs de laboratoire, vaccins, produits dentaires et médicaments anti rétroviraux au titre de l'exercice budgétaire 2011.

Suite aux observations formulées par la DCMP, la PNA a par lettre en date du 27 octobre 2010 soumis à la DCMP la version corrigée dudit projet.

La DCMP, qui a constaté que, d'une part, le marché a été ouvert aux entreprises étrangères non communautaires, d'autre part, les quantités ont été modifiées en hausse y a émis un avis défavorable.

La PNA a alors saisi le CRD pour un éclairage sur l'article 52 du Code des marchés publics. Cependant, à l'appui de sa demande d'éclairage, elle a développé les moyens suivants.

ELEMENTS FOURNIS A L'APPUI DE LA DEMANDE D'AVIS

A l'appui de sa demande, la PNA a soutenu la spécificité de l'appel d'offres concerné qui porte sur les marchés relatifs aux programmes de santé (paludisme, tuberculose, SIDA).

Par ailleurs, elle a exposé que les programmes ci-dessus décrits bénéficient d'appuis financiers extérieurs tel le fonds mondial.

MOYENS DONNES PAR LA DCMP AU SOUTIEN DE SON AVIS

Par lettre en date du 05 novembre 2010, la DCMP a communiqué son avis sur le dossier d'appel d'offres litigieux soumis à son avis par la PNA.

Il résulte dudit avis que :

- Par rapport à sa précédente revue formalisée dans la lettre n°044963/MEF/DCMP/17 du 22 octobre 2010, la DCMP a noté une modification de quantité dans le nombre des articles qui est passé de 697 à 701 articles PNA ;
- Les nouvelles dispositions de l'article 52 telles que modifiées par le décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010 n'offrent plus la possibilité aux autorités contractantes d'ouvrir l'appel d'offres aux entreprises étrangères hors communautaires lorsque le financement du marché est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire.

OBJET DU LITIGE :

Il résulte de ce qui précède que l'objet du litige porte :

- d'une part, sur l'ouverture de l'appel d'offres aux entreprises étrangères non communautaires alors même que l'article 52 nouveau du Code des Marchés publics limite la compétition aux entreprises nationales et communautaires ;
- d'autre part, sur l'augmentation du nombre d'articles sans cette augmentation soit mise en cohérence avec la clause 1.1 des DPAO.

EXAMEN DE LA DEMANDE :

Sur l'ouverture du marché aux entreprises étrangères non communautaires :

Considérant que la disposition unique de l'article 52 nouveau du décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics est ainsi disposée : *« la participation à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans les Etats membres de l'UEMOA »* ;

Que l'alinéa 2 de l'ancien article 52, qui permettait à l'autorité contractante de recourir à des candidatures étrangères lorsque les prestations demandées ne pouvaient pas être réalisées par des candidats issus du tissu communautaire n'a pas été repris par le nouvel article ;

Qu'en effet, la disposition supprimée ou omise disposait qu'il peut être dérogé à l'alinéa précédent en application d'accords internationaux ou lorsque qu'il s'agit de fournitures, travaux ou services ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales » ;

Mais considérant selon l'article 24 nouveau du Code des obligations de l'administration, dont le Code des marchés publics est censé traduire, l'acheteur public, en matière de commande publique, a l'obligation de respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Que cependant, l'article 28 nouveau dispose que « par dérogation au principe de l'égalité de traitement, une préférence peut être attribuée lors de la passation d'un marché aux offres portant sur des fournitures, services ou travaux d'origine ou de fabrication sénégalaise présentés par une entreprise nationale dans les conditions et limites déterminées par le Code des marchés public et dans le respect des dispositions des traités et accords internationaux conclus par la République du Sénégal »

Qu'en application de cette disposition, la Section 5 du chapitre 2 titre III du Code des marchés, intitulés : « *Régimes préférentiels* » a prévu aux articles 50 et 52 un régime préférentiel aux entreprises nationales et communautaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du Code des obligations de l'administration que la dérogation prévue aux principes de la liberté d'accès et de l'égalité de traitement des candidats ne s'applique pas :

- 3) lorsqu'un accord international y déroge ; ou,
- 4) lorsqu'a contrario, les fournitures, services ou travaux ne sont pas d'origine ou de fabrication sénégalaise présentés par une entreprise nationale ou communautaire, autrement dit lorsque les fournitures, travaux ou services objet de la commande publique ne peuvent pas être livrés ou réalisés par des entreprises locales ;

Que la disparition de l'alinéa 2 de l'article 52 ancien, que tout semble laisser croire qu'il s'agit d'une omission car ni les travaux préparatoires aux modifications apportées au Code ni le rapport de présentation du nouveau décret ne l'ont évoqué dans le sens de sa suppression, ne peut faire échec aux dispositions précitées de l'article 28 du Code des obligations de l'administration ; Que dans ce contexte, si les conditions définies pour l'application d'une dérogation ne sont pas réunies, un retour au principe ne peut qu'accroître la concurrence, restaurer la liberté d'accès au marché et favoriser le choix des fournitures, prestations ou travaux au meilleur prix ;

Que surabondamment, même si l'avis de la DCMP serait fondé, force est de constater que lui donner application risquerait de créer un blocage relativement à l'exécution de certains projets et programmes dont la mise en œuvre ne peut être réalisée par des entreprises nationales, ce qui constituerait une atteinte à la vocation du code qui est de faciliter aux autorités contractantes l'acquisition des biens ou la réalisation de service ou travaux en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général ;

SUR LA MODIFICATION CONSTATEE DU NOMBRE D'ARTICLE :

Considérant que la DCMP a relevé, entre la version première et la version corrigée du dossier d'appel d'offres une modification de quantité dans le nombre des articles qui est passé de 697 à 701 articles PNA sans cette augmentation soit mise en cohérence avec la clause 1.1 des DPAO ;

Considérant que le choix de la procédure à mettre en œuvre se détermine en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser ; qu'il est indispensable de procéder, en amont, à une définition précise des besoins ; que de cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché ;

Qu'il en résulte :

- au stade de la préparation, que la définition des besoins doit porter sur la totalité du projet ;
- que la DCMP soit saisie de l'ensemble du projet et qu'elle soit informée de manière expresse des modifications apportées au projet pour lui permettre d'assurer convenablement sa mission de contrôle ;

Qu'à cet égard, la recommandation de la DCMP vise à mettre en concordance les besoins exprimés par l'autorité contractante avec le règlement de la consultation en vue de garantir la réussite ultérieure du marché ;

Considérant la pertinence de la recommandation de mettre en cohérence les nouvelles quantités avec les clauses des DPAO, il convient pour une poursuite de la procédure soit de respecter les quantités figurant dans le dossier examiné en première revue, soit corriger les DPAO et soumettre à nouveau le dossier à la DCMP ;

Qu'en considération des articles 24 et 28 du Code des obligations de l'administration et sous réserve des prescriptions sus indiquées relativement à la mise en cohérence des quantités et les clauses des DPAO, il convient d'autoriser l'autorité contractante à poursuivre la procédure ; en conséquence,

DECIDE :

5) Constate :

- que le marché susvisé est financé sur les crédits du budget d'investissement 2011 de la PNA ;
- qu'entre la première revue du dossier d'appel d'offres et la revue de la version corrigée le nombre d'articles a varié en hausse sans que cette variation soit mise en cohérence avec les DPAO ;

- 6) Dit qu'en vertu de l'article 28 du Code des obligations de l'Administration, la suppression ou l'omission de l'alinéa 2 de l'article 52 ancien du Code des Marchés publics ne constitue pas un empêchement à l'ouverture de l'appel d'offres aux entreprises étrangères lorsque les fournitures, travaux ou services objet de la commande publique ne peuvent pas être livrés ou réalisés par des entreprises locales ; en conséquence,
- 7) Autorise l'autorité contractante à poursuivre la procédure sous réserve de la mise en cohérence des quantités commandées et les clauses des DPAO ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Pharmacie nationale d'Approvisionnement et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Cette conception du CRD est conforme à la loi, car il résulte de la combinaison des articles 24 nouveau et 28 nouveau du code des obligations de l'Administration que la règle est que l'acheteur public doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que la dérogation au principe d'égalité de traitement est accordée lorsque l'objet du marché peut être satisfait par une entreprise nationale et dans le respect des engagements internationaux conclus par la République du Sénégal ; qu'ainsi, ladite dérogation en faveur des entreprises nationales ne s'applique pas lorsqu'elle est en contradiction avec un traité ou un accord international ou lorsque l'objet de la commande ne peut être satisfait par lesdites entreprises.

L'avenir semble avoir donné raison au CRD, car avec l'avènement du code des marchés publics de 2011, l'alinéa 2 de l'article 52 de ce code est revenu sous la formulation suivante : « Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent lorsque l'appel d'offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L'accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constituées conformément aux dispositions de l'article 47 du présent décret ».

Fort de ces nouvelles dispositions de l'article 52 et de celles des articles 24 et 28 du code des obligations de l'administration, le CRD a déclaré que : « considérant que l'Administration

des Douanes, dans ses justifications, soutient d'une part, la complexité des prestations et de la valeur des investissements nécessaires à l'exécution d'un programme de vérification en vue de garantir un fonctionnement sécurisé du dispositif de collecte des recettes douanières et de contrôle des opérations commerciales, d'autre part, l'obligation pour le prestataire, d'avoir un dispositif effectif dans la plupart des pays ; qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, l'ouverture de la procédure de sélection dudit marché aux entreprises étrangères » (décision du CRD n° 13 du 30 janvier 2013 statuant sur la demande du Directeur Général des Douanes, suite à l'autorisation de la DCMP , à titre exceptionnel, d'ouvrir aux entreprises étrangères, l'appel d'offres relatif au marché de renouvellement du Programme de Vérification des Importations (PVI).

**DECISION N° 013/13/ARMP/CRD DU 30 JANVIER 2013
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA DIRECTION GENERALE DES
DOUANES SOLLICITANT L'AUTORISATION D'OUVRIR AUX ENTREPRISES
ETRANGERES, L'APPEL D'OFFRES RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU
PROGRAMME DE VERIFICATION DES IMPORTATIONS (PVI).**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 16 janvier 2013 de la Direction générale des Douanes ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Babacar DIOP, Mamadou WANE et Mademba GUEYE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'enquête sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou Cissé, chargé d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection et Mme Khadidjatou LY, chargée d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre en date du 16 janvier 2013, enregistrée le 17 janvier 2013, au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 009/13, le Directeur général des Douanes a saisi le CRD d'une demande d'autorisation, à titre exceptionnel, d'ouvrir aux entreprises étrangères, l'appel d'offres relatif au marché de renouvellement du programme de Vérification des Importations (PVI).

Selon la Direction générale des Douanes, le contrat liant le gouvernement du Sénégal et la société COTECNA est arrivé à terme depuis le 24 novembre 2012.

Pour prévenir les graves conséquences sur les recettes douanières et sur la lutte contre la fraude qui découleraient d'un arrêt brutal dudit contrat, elle a sollicité et obtenu de la DCMP, suivant lettre en date du 03 septembre 2012, une autorisation pour conclure un marché par entente directe avec l'actuel prestataire pour un délai de quatre (4) mois, afin d'éviter toute rupture dans la continuité du service public et permettre par la même occasion, le déroulement à son terme, de la procédure de passation par appel d'offres en deux étapes, pour la mise en œuvre d'un nouveau contrat de partenariat.

La DGD soutient que le PVI a été, depuis sa première année de mise en œuvre en 1991, confié à des sociétés internationales, du fait, notamment, que le prestataire doit disposer, d'une part, de représentations dans quasiment tous les pays du monde pour réaliser l'inspection avant embarquement, d'autre part, d'une expertise avérée dans le contrôle non intrusif et le tracking.

En conclusion, elle sollicite l'autorisation du CRD pour ouvrir l'appel d'offres sur l'international.

L'OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d'autorisation porte sur la possibilité d'ouvrir aux entreprises étrangères, le marché de la Direction générale des Douanes pour la réalisation des prestations susmentionnées.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que l'article 52 du Code des marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 de ce Code est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.

Que, toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent lorsque l'appel d'offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées. L'accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l'article 47 du même texte ;

Considérant que l'Administration des Douanes, dans ses justifications, soutient d'une part, la complexité des prestations et de la valeur des investissements nécessaires à l'exécution d'un programme de vérification en vue de garantir un fonctionnement sécurisé du dispositif de collecte des recettes douanières et de contrôle des opérations commerciales, d'autre part, l'obligation pour le prestataire, d'avoir un dispositif effectif dans la plupart des pays ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, l'ouverture de la procédure de sélection dudit marché aux entreprises étrangères ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le marché envisagé, financé sur le budget de l'Etat, est en principe réservé aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité, sauf dérogation, en référence aux dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics ;
- 2) Constate cependant que les justifications apportées par l'autorité contractante militent en faveur d'une ouverture dudit marché aux entreprises étrangères ; à cet égard,
- 3) Autorise, à titre exceptionnel, l'ouverture de la procédure de sélection dudit marché aux entreprises étrangères, tout en prévoyant l'application d'une marge de préférence aux entreprises communautaires et aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires ;
- 4) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Direction générale des Douanes et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président
Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Babacar DIOP

Mademba GUEYE

Mamadou WANE

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

Le principe de l'égalité de traitement des candidats découle du principe général de droit énoncé dans l'article 6 de la « Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ». Son application est ancienne, car déjà en 1906, le Commissaire du Gouvernement Romieu déclarait dans ses conclusions de l'affaire « Ballande » : « le soumissionnaire évincé a le droit de demander l'annulation de l'adjudication pour l'inobservation des règles fondamentales, même si elles sont édictées dans l'intérêt de l'Administration, du moment où une inégalité a été créée entre les concurrents (CE, 30 mars 1906, Rec., p. 281 ; M. Guibal, « l'égalité entre concurrents dans le droit des marchés publics, contrats et marchés publics, 1985, n° 211 p. 31).

De par sa valeur juridique, ce principe d'égalité est d'application générale.

En France, l'article 53-IV du code des marchés publics accorde un droit de préférence qui ne s'exerce que dans des cas où il existerait égalité de prix ou équivalence des offres entre un organisme protégé (société coopérative ouvrière de production, groupement de producteurs agricoles, artisans, société de coopérative d'artisans ou société de coopérative d'artistes, etc....) et une société commerciale. Souvent les organismes d'insertion des personnes handicapées, comme les ateliers protégés, ne peuvent pas soutenir la concurrence des entreprises purement commerciales.

La CJCE a rappelé maintes fois l'attachement du droit communautaire au principe de transparence, qui est rattaché, entre autres, au principe de non discrimination en raison de la nationalité (Laure Marcus, « la Jurisprudence de la CJCE sur les marchés publics »).

XVII. COMPUTATION DU DELAI DE CINQ (5) JOURS IMPARTI A LA DCMP

A la suite de l'évaluation des offres de l'appel d'offres portant sur la couverture du risque maladie groupe de son personnel, le Port Autonome de Dakar (PAD), par lettre reçue à la DCMP le 17 février 2010, a saisi cette dernière pour avis sur la proposition d'attribution provisoire du marché.

La DCMP ayant répondu par courrier reçu le 25 février 2010 par le PAD, ce dernier a estimé que l'organe chargé du contrôle à priori a répondu en dehors du délai de cinq (05) jours ouvrables qui lui est imparti par l'article premier de la décision n° 1/CRMP du 06 mars 2008, prise en application des articles 138 et 139 du code des marchés publics de 2007.

Le PAD a donc poursuivi la procédure de passation dudit marché en soumettant le projet de contrat y relatif à la DCMP qui le rejeta. Suite à ce rejet, le PAD a introduit un recours devant le CRD pour demander l'autorisation de poursuivre la procédure de passation.

Faisant une combinaison pertinente des dispositions de l'article 4.16 du code des marchés publics et de la décision n° 1 CRMP du 6 mars 2008, prise en application des articles 138 et 139 dudit code, le CRD considéra que la DCMP a servi sa réponse dans le délai de cinq (05) jours francs qui lui imparti ; en effet, il a estimé que la DCMP ayant reçu la lettre du PAD le 17 février 2010 et sa réponse ayant été réceptionnée par ce dernier le 25 février 2010, il s'est écoulé sept (7) jours francs auxquels ont été défalquées les journées du samedi 20 et dimanche 21 février 2010. En conséquence, il n'autorisa pas la poursuite de la procédure de passation et invita le PAD à se conformer à l'avis de la DCMP (décision du CRD n°40 du 21 avril 2010).

**DECISION N° 040/10/ARMP/CRD DU 21 AVRIL 2010
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES SUR LA DEMANDE D'ARBITRAGE DU PORT AUTONOME DE DAKAR
PORTANT SUR L'INTERPRETATION PAR LA DIRECTION CENTRALE DES
MARCHES PUBLICS (DCMP) DU DELAI DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
IMPARTI PAR LA DECISION N° 01/CRMP DU 06 MARS 2008 PRISE EN
APPLICATION DES ARTICLES 138 ET 139 DU CODE DES MARCHES PUBLICS**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES :**

Vu le Code des obligations de l'administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 027/PAD/DG du 24 mars 2010 du Port Autonome de Dakar, enregistrée le 26 mars 2010 sous le numéro 169/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd'El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,

De MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l'ARMP, Oumar Sarr, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire n° 027/PAD/DG du 24 mars 2010 du Port Autonome de Dakar, enregistrée le 26 mars 2010 sous le numéro 169/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Port Autonome de Dakar (PAD) a saisi l'Autorité de Régulation des Marchés publics d'une demande d'arbitrage portant sur l'interprétation par la DCMP de la computation des délais de traitement des dossiers qui lui sont impartis par la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics.

A l'appui de son recours, le requérant a produit les pièces suivantes :

- Une copie du procès verbal d'ouverture des plis ;
- Une copie du procès verbal d'examen des offres ;
- Une copie de la lettre du PAD n° 10/PAD/SG/CT/DG du 16 mai 2010 ;
- Une copie de la lettre de la DCMP n° 43/MEF/DCMP/jd du 24 février 2010 ;
- Une copie de la lettre du PAD n° 517/PAD/DG du 16 mars 2010 ;
- Une copie de la lettre du PAD n° 26/PAD/SG/CT/DG du 18 mars 2010 ;
- Une copie de la lettre de la DCMP n° 60/MEF/DCMP/7 du 19 mars 2010 ;
- Une copie du rapport dévaluation des offres relative à la couverture du risque maladie groupe du personnel permanent du PAD.

SUR LA RECEVABILITE:

Considérant qu'au terme de l'article 139 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, l'autorité contractante peut saisir le CRD en cas d'avis défavorable de la DCMP sur la proposition d'attribution du marché qu'elle lui a soumise ;

Considérant que le PAD a introduit par lettre n° 027/PAD/DG du 24 mars 2010, enregistrée le 26 mars 2010 sous le numéro 169/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, une requête aux fins de poursuivre la procédure de passation suite à l'avis défavorable de la DCMP sur l'attribution provisoire du marché susvisé ;

Considérant que le Code des Marchés publics ne prévoit pas de délai de saisine dans pareil cas ;

Que le recours doit être déclaré recevable.

LES FAITS

A la suite de l'évaluation des offres de l'appel d'offres portant sur la couverture du risque maladie groupe de son personnel, le PAD a saisi la DCMP pour avis sur la proposition d'attribution provisoire du marché ;

N'ayant pas reçu de réponse de la part de la DCMP dans les délais requis, le PAD a poursuivi la procédure de passation dudit marché, et a soumis le projet de contrat pour examen à l'organe chargé du contrôle a priori qui l'a rejeté ;

Le PAD a introduit par lettre en date du 24 mars 2010 le présent recours devant le Comité de Règlement des Différends pour demander l'autorisation de poursuivre la procédure de passation.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa requête, le PAD déclare que la DCMP n'a pas respecté les dispositions de l'article premier de la décision n°1/CRMP du Conseil de Régulation fixant un délai de cinq (5) jours ouvrables imparti à elle pour l'examen du rapport d'évaluation des offres et de la proposition d'attribution du marché ;

C'est pourquoi en application de l'article 2 de la décision sus nommée, il a poursuivi la procédure de passation dudit marché en soumettant le projet de marché pour examen puisque l'avis de l'organe chargé de la revue a priori est réputé favorable en cas d'absence de réponse dans les délais indiqués ;

SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Selon la DCMP, son avis a été donné dans les délais requis puisqu'elle a été saisie le 17 février 2010 et apporté sa réponse par courrier reçu le 25 février 2010 ;

Elle précise que pour la computation des délais, ne sont prises en compte ni le premier et le dernier jour du délai, ni les jours non ouvrés, notamment le samedi et le dimanche, en référence aux dispositions combinées de l'article 4.16 du Code des Marchés publics et de l'article premier de la décision n°1/CRMP du Conseil de Régulation.

A cet égard, le PAD a mal apprécié la computation des délais et a poursuivi à tort, la procédure de passation sans attendre son avis.

SUR L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que la demande d'avis porte sur le mode de computation des délais de contrôle impartie à la DCMP par décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 de l'ARMP prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions combinées des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics, la DCMP a l'obligation de procéder à la revue des dossiers qui lui sont soumis par les autorités contractantes dans les délais fixés par la décision n°1/CRMP du 6 mars 2008 du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Considérant que suite à l'évaluation des offres relatives au marché de couverture du risque maladie groupe de son personnel, le PAD a saisi la DCMP par lettre en date du 16 février 2010 pour solliciter son avis sur le rapport d'évaluation des offres et la proposition d'attribution dudit marché ;

Considérant que le PAD, estimant que l'organe chargé du contrôle a priori n'a pas délivré sa réponse dans les cinq (5) jours fixés par l'article premier de la décision n°1/CRMP du 6 mars 2008 du Conseil de Régulation, a poursuivi la procédure de passation en application de l'article 2 de la décision sus nommée, et a soumis le projet de marché pour avis ;

Considérant que la DCMP soutient au contraire que les délais de réponse indiqués par la décision n°1/CRMP du 6 mars 2008 du Conseil de Régulation ont été respectés ;

Considérant qu'au terme de l'article 4.16 du Code des Marchés publics, les délais sont exprimés, sauf précision contraire, en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers sans inclure le jour de son point de départ, ni le dernier jour ;

Considérant cependant qu'en référence à l'article 4.16 du Code des Marchés publics, la décision n° 01/CRMP du 06 mars 2008 prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics et fixant les délais impartis pour l'examen par la DCMP des dossiers prévoit la computation des délais sur la base de jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier par l'organe chargé de la revue a priori ;

Qu'il convient dès lors de défalquer dans le décompte du délai les jours non ouvrés, notamment le samedi, le dimanche et les jours fériés ;

Considérant que la DCMP a été saisie par le PAD par courrier en date du 16 février 2010, reçu le 17 février 2010 et qu'en réponse l'organe chargé du contrôle a priori a réagi à cette requête par courrier en date du 24 février 2010 réceptionné le 25 février 2010 par le requérant sous le numéro 10234 ;

Que sur la base de ces informations non contestées, il s'est écoulé sept (7) jours francs auxquels il y'a lieu de défalquer les journées non ouvrées, notamment ceux du samedi 20 et dimanche 21 février 2010, ramenant ainsi le délai de réaction de la DCMP à cinq (5) jours ouvrés ;

Qu'il y'a lieu par conséquent, de considérer que la réponse de la DCMP a été servie dans les délais indiqués ;

EMET L'AVIS SUIVANT :

- 1) Constate que les dates des différents courriers ne font pas l'objet de contestation par les deux parties ;
- 2) Constate que la DCMP a respecté le délai de traitement de cinq (5) jours ouvrés fixé par la décision n° 1/CRMP du 6 mars 2008 prise en application des articles 138 et 139 du Code des Marchés publics ; par conséquent,
- 3) Dit qu'il n'y a pas lieu à autoriser la poursuite de la procédure de passation et que le PAD doit se conformer à l'avis de la DCMP donné par lettre n°43/MEF/DCMP/jd en date du 24 février 2010 ;
- 4) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au Port autonome de Dakar et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

XVIII. PRESENCE OBLIGATOIRE DU MAGISTRAT AU MOMENT DE LA PRISE DES DECISIONS ET AVIS DU CRD

Suite au recours en annulation formé par le PAD devant la Cour Suprême, ladite Cour annula la décision du CRD n° 40 du 21 avril 2010, non pas pour des motifs liés aux règles de computation des délais, mais pour le moyen tiré du vice de forme.

En effet, par arrêt n° 1 du 13 janvier 2011, ladite Cour statua comme suit : « sur le premier moyen tiré du vice de forme en ce que la composition du CRD était irrégulière lors de la prise de la décision attaquée puisque Mamadou DEME, Magistrat, nommé membre du Conseil de Régulation par décret n° 2009-502 du 29 mai 2009 n'y siégeait pas alors qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le Comité doit, pour statuer, comprendre dans sa composition un magistrat au moins parmi les membres de l'administration ;

Considérant que l'ARMP a conclu au rejet de la demande d'annulation en faisant valoir principalement que le manuel de procédure interne adopté par le Conseil de Régulation permet au CRD de statuer lorsque le quorum fixé à trois (3) membres est atteint ;

Considérant que l'article 18 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 dispose que le CRD est composé de membres dont le Président dudit Conseil, un autre membre parmi les représentants de l'administration, deux membres appartenant l'un au secteur privé et l'autre à la société civile, désignés par le Conseil de Régulation, en précisant à son alinéa 3 que « dans tous les cas, au moins, un des membres de l'administration doit être un magistrat ;

Considérant que le décret a ainsi fixé la constitution de l'organe collégial en prévoyant qu'un magistrat doit être obligatoirement dans la composition ;

Considérant que cette présence du magistrat dans un organe investi du pouvoir de trancher des litiges, doit être analysée comme une formalité substantielle dans la mesure où elle garantit les droits des personnes et est susceptible de changer le sens de la décision ;

Qu'en conséquence, la méconnaissance de la règle impérative qui détermine la composition du CRD a vicié, en la forme, la décision prise sans la présence du magistrat ;

Considérant que l'argument de l'ARMP tiré du quorum fixé à trois (3) membres par le manuel de procédure, adopté par son Conseil de Régulation, ne saurait couvrir ce vice de forme entachant l'acte puisque ce manuel n'a pas vocation à édicter une procédure contraire à celle instituée par les lois et règlements ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et qu'il échet d'annuler la décision du CRD ».

- XIX. - OBLIGATION DE TRANSMETTRE DES PIECES COMPLETES A LA DCMP ET D'ASSURER LA TRANSPARENCE ET L'EGALITE DES CANDIDATS ;**
- REGULARITE DE LA DECISION DU CRD NON AFFECTEE PAR LA PRESENCE D'OBSERVATEURS EN SON SEIN ;**
 - ABSENCE DE DESSAISISSEMENT DE LA DCMP TANT QUE TOUTES LES ETAPES DE LA PHASE DE CONTROLE NE SONT PAS TERMINEES.**

Conformément à l'avis général de passation de ses marchés publié dans le soleil du 06 janvier 2011, le Port Autonome de Dakar (PAD) a lancé un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection des candidats intéressés par la mission de réalisation des études architecturales et techniques, la préparation des dossiers d'appel d'offres et l'assistance du PAD pour la sélection des offres et la supervision des travaux relatifs à la construction de son siège.

Par lettre du 1^{er} juillet 2011, le PAD saisit la DCMP du dossier d'attribution dudit marché pour avis, mais par courrier daté du 25 juillet 2011, la DCMP émet un avis défavorable à la poursuite de la procédure ; suivant lettre du 1^{er} août 2011, le PAD saisit le CRD pour arbitrage.

Selon décision n° 153 du 10 août 2011, le CRD estima que la décision de la DCMP est justifiée, annula la procédure et ordonna à l'autorité contractante, en cas de relance, de publier préalablement les critères de présélection ou de sélection des candidats dans l'avis à manifestation d'intérêt ou d'appel public à la concurrence.

Cette décision du CRD est pertinente et cohérente parce que :

1. Le PAD n'a pas mis la DCMP dans les conditions lui permettant d'émettre son avis, en ne lui communiquant pas le rapport d'évaluation des offres, le procès-verbal d'attribution provisoire et les documents de la procédure qui ont servi à leur établissement par la commission des marchés (article 138 du code de 2007) ;
2. Le PAD a manqué à son obligation de rendre transparente la procédure de passation et d'assurer l'égalité de traitement des candidats, en violation de l'article 24 nouveau du code des obligations de l'administration et des articles 79 et suivants du code des marchés publics de 2007, en n'indiquant pas dans l'avis à manifestation d'intérêt les critères et sous-critères de sélection des candidats, ainsi que leur mode d'application qui doivent être rendus publics en amont de la procédure.

**DECISION N° 153/11/ARMP/CRD DU 10 AOUT 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU PORT AUTONOME DE
DAKAR (PAD) SOLLICITANT UNE AUTORISATION DE POURSUIVRE LA
PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIFS A LA
CONSTRUCTION DE SON SIEGE.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en son article 31 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CR du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n°01668/CEP/DG du 01^{er} août 2011 du Directeur général du PAD ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Oumar SARR, Conseiller juridique, présentant les faits et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, et de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Mamadou DEME, Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, assurant le secrétariat du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 1^{er} août 2011, enregistrée le 2 août 2011, sous le numéro 771/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le PAD a saisi le CRD d'une demande d'autorisation de poursuivre la procédure d'attribution du marché de travaux relatif à la construction du siège du PAD.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant que la saisine du CRD se fonde sur les dispositions des articles 81 et 139.3 du Code des marchés publics qui disposent que, si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui auront été formulés par la DCMP concernant la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le CRD ;

Qu'à cet effet, l'article 81.4 du Code dispose que la saisine du CRD a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'avis ou de la recommandation contestée ;

Considérant qu'il ressort de la copie de la lettre n°003352/MEF/DCMP/DCV/54 du 25 juillet 2011 que le PAD a reçu, le jeudi 28 juillet 2011 comme en atteste les mentions du service courrier du PAD, notification de l'avis défavorable émis par la DCMP à la poursuite de la procédure d'attribution du marché litigieux ;

Considérant que le PAD a saisi le CRD le 02 août 2011 ;

Considérant qu'il ressort des constatations ci-dessus que le PAD a saisi le CRD dans le délai de trois (3) jours prescrit ; en conséquence, il convient de déclarer recevable la présente saisine ;

LES FAITS

Conformément à l'avis général de passation de ses marchés publié dans Le Soleil du 06 janvier 2011, le PAD a lancé un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection des candidats intéressés par la mission de réalisation des études architecturales et techniques, la préparation des dossiers d'appel d'offres et l'assistance du PAD pour la sélection des offres et la supervision des travaux relatifs à la construction de son siège.

Par lettre n°000898PAD/SMC/DAGE/SG/DG du 01^{er} juillet 2011, le PAD a saisi la DCMP du dossier d'attribution dudit marché pour avis.

Suivant lettre n°003352MEF/DCMP/DCV/54 du 25 juillet 2011, la DCMP a fait parvenir à l'autorité contractante son avis défavorable à la poursuite de la procédure d'attribution.

Par lettre n°01668 du 01^{er} août 2011, le PAD a saisi le CRD pour arbitrage.

MOYENS PRESENTES PAR LE PAD:

A l'appui de sa demande, l'autorité requérante a exposé que la DCMP a contesté la procédure de constitution de la liste restreinte des candidats présélectionnés aux motifs que :

- le nombre de points exigé par critère de qualification et le nombre minimum de points requis pour être présélectionné ne sont pas renseignés dans l'avis à manifestation d'intérêt ;
- le procès-verbal d'ouverture des candidatures en date du 31 mars et le procès-verbal de validation du rapport de présélection de consultants ne sont pas joints au dossier.

L'autorité contractante, qui a reproché à la DCMP son silence sur le document type d'avis à manifestation d'intérêt (AMI), lequel figurait dans le dossier validé par la DCMP avant le lancement de la procédure, a soutenu que nulle part sur ledit document il n'est indiqué qu'il faut préciser le nombre de points exigé par critère de qualification et le nombre minimum de points requis pour être présélectionné.

En conclusion, elle a déclaré s'être conformée aux dispositions de l'article 79 du Code des marchés publics applicable à la procédure de présélection des candidats.

MOTIFS DE L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP

Par lettre n°003352/MEF/DCMP/35 du 25 juillet 2011, la DCMP a notifié au PAD l'avis défavorable qu'elle a émis au dossier d'attribution du marché de travaux relatif à la construction du siège du PAD aux motifs que concernant la liste des candidats présélectionnés :

- l'avis à manifestation d'intérêt ainsi que le rapport d'évaluation ne comportent pas de grille de notation ;
- les pièces suivantes n'ont pas été transmises :
 - l'original du procès-verbal d'ouverture des candidatures daté du 31 mars et le procès-verbal de validation du rapport de présélection de consultants ;
 - les lettres d'invitation ainsi que les accusés de réception par les candidats sélectionnés ;
 - le rapport d'évaluation des offres techniques signé par les membres de la commission compétente.

OBJET DE LA DEMANDE DU PAD :

Il ressort des éléments ci-dessus exposés que l'objet de la demande porte sur :

- 1) le caractère incomplet du dossier soumis à l'avis de la DCMP ;
- 2) le défaut de renseignement dans l'avis à manifestation d'intérêt des modalités d'application des critères de sélection ;
- 3) l'incidence de l'avis de la DCMP sur l'avis à manifestation d'intérêt alors qu'elle avait, avant le lancement de la procédure, validé le dossier de la procédure parmi lequel figurait l'avis à manifestation d'intérêt.

EXAMEN DE LA DEMANDE

1) SUR LE CARACTERE INCOMPLET DU DOSSIER SOUMIS A L'AVIS DE LA DCMP :

Considérant que dans sa lettre du 25 juillet 2011, adressée à l'autorité contractante, la DCMP a relevé que le dossier transmis était composé des pièces suivantes :

- le document type d'avis à manifestation d'intérêt ;
- la copie du procès-verbal d'ouverture des candidatures en date du 31 mars 2011 ;
- la copie du procès-verbal d'ouverture des offres techniques en date du 9 juin 2011 ;
- la copie de la décision de nomination des membres de la Commission des marchés ;
- la copie de la décision portant création de la Cellule de passation des marchés.

Qu'à l'examen dudit dossier, il est ressorti que l'original du procès-verbal d'ouverture des candidatures daté du 31 mars 2011, le procès-verbal de validation du rapport de présélection de consultants, les lettres d'invitation ainsi que les accusés de réception et le rapport d'évaluation des offres techniques signé par les membres de la commission compétente n'ont pas été transmis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 138 du Code des marchés publics, la DCMP assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés. A ce titre, elle émet un avis sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal d'attribution provisoire du marché établi par la commission des marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances ;

Considérant qu'il résulte de ce texte une obligation pour l'autorité contractante, dès lors que le seuil fixé par l'arrêté visé à l'article 138 est atteint, de communiquer le rapport d'évaluation des offres et le procès-verbal d'attribution provisoire ainsi que les documents de la procédure qui ont servi à leur établissement par la commission des marchés ;

Qu'à cet égard, malgré la production par l'autorité contractante de la lettre n°001019/CEP/SG du 19 juillet 2011 de transmission des pièces dites manquantes adressée à la DCMP en réponse à sa lettre n°3092/MEF/DCMP/DCV/54 du 08 juillet 2011, la DCMP a maintenu, comme il ressort des mentions de la lettre n°003352/MEF/DCMP/DCV/54 du 25 juillet 2011, la non transmission desdites pièces ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la DCMP a reçu les pièces concernées avant la date de prise de son avis ;

Qu'en considération de ces constatations, il convient de dire que la DCMP n'a pas été mise dans les conditions pour émettre son avis ;

1) SUR LE NON RENSEIGNEMENT DES MODALITES D'APPLICATION DES CRITERES DE SELECTION :

Considérant qu'il ressort de la copie de l'avis à manifestation d'intérêt produite par l'autorité contractante la mention suivante : *« les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment des références concernant l'exécution de marchés analogues, l'organisation technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 10 pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.*

Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'autorité contractante, ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon le mode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) »

Considérant que l'avis à manifestation d'intérêt ne comporte aucune indication relative aux critères et sous-critères ainsi leur mode d'application selon lesquels les candidats seront évalués ; que l'avis à manifestation d'intérêt n'a pas été renseigné sur ce point ;

Considérant qu'aux termes des articles 79, 80 bis et 80 ter du Code des marchés publics, les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une présélection des candidats admis à présenter une proposition ; qu'à cet effet, l'avis à manifestation doit comporter entre autres indications celles relatives aux critères de sélection ; qu'elle concerne tant les critères que les sous-critères et leur mode d'application, qui doivent avoir été rendus publics en amont de la procédure ;

Considérant que cette obligation résulte des exigences de transparence de la procédure et d'égalité de traitement des candidats prévues par l'article 24, nouveau, de la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des obligations de l'Administration, modifiée par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;

Considérant que n'ayant pas satisfait à cette exigence de publicité préalable des critères de sélection, l'autorité contractante a manqué à son obligation de rendre transparente la procédure de passation et d'assurer l'égalité de traitement des candidats ;

2) DE L'INCIDENCE DE L'AVIS DE LA DCMP SUR L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET ALORS QU'ELLE AVAIT, AVANT LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE, VALIDE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE DONT FIGURAIT L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET :

Considérant qu'il est constant que, comme l'a soutenu l'autorité contractante, le dossier comprenant entre autres le projet de demande de proposition et le modèle type de l'avis à manifestation d'intérêt a été examiné et validé par la DCMP ; que celle-ci n'a formulé aucune réserve ou suggestion sur le modèle d'avis produit bien que celui-ci ne fasse pas état de la mention obligatoire des critères et sous-critères de sélection ainsi que de leur mode d'application notamment du nombre de points affecté par critère de qualification et le nombre minimum de points requis pour être présélectionné ;

Que, certes, il n'est pas cohérent que la DCMP, après avoir validé le dossier de la consultation auquel était joint le modèle type de l'avis à manifestation d'intérêt, vienne ensuite émettre un avis défavorable au motif que ledit avis à manifestation d'intérêt n'est pas conforme ;

Considérant cependant, qu'aux termes de l'article 79 et des articles 80 bis et 80 ter visés plus haut, les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une présélection des candidats admis à présenter une proposition ; qu'à cet effet, l'avis à manifestation doit comporter entre autres indications celles relatives aux critères de sélection ;

Considérant que cette obligation vise à protéger l'intérêt général à travers les principes de transparence des procédures de passation des marchés et d'égalité de traitement des candidats ; qu'à ce titre, elle ne protège ni les intérêts de la DCMP, ni ceux de l'autorité contractante et des candidats, mais les intérêts de tous ;

Considérant que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité absolue de la procédure conformément à l'article 24, alinéa 4 précité, qui dispose que « *le non respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe de l'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marché, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure* » ;

Qu'en considération de ces éléments, il convient d'annuler la procédure de passation concernée et d'ordonner, en cas de relance, la publication préalable des critères de présélection ou de sélection des candidats dans l'avis à manifestation d'intérêt ou d'appel public à la concurrence, selon le cas ; en conséquence,

DECIDE :

- 1) Reçoit le PAD en sa saisine ;
- 2) Constate :
 - d'une part, que l'autorité contracte n'a pas transmis à la DCMP l'ensemble des pièces de la procédure qui ont servi à établir le rapport d'analyse comparative des offres et le procès-verbal d'attribution provisoire établis par la Commission des marchés ;
 - d'autre part, que l'autorité contractante a jugé les candidats sur la base de critères et sous critères qui n'ont pas été renseignées dans l'avis à manifestation d'intérêt ; en conséquence,
- 3) Dit que la présélection des candidats a été faite en violation des règles de transparence et de traitement égal des candidats ; qu'à cet égard,
- 4) Dit que la décision de la DCMP est justifiée ;
- 5) Ordonne à l'autorité contractante, en cas de relance, de porter préalablement à la connaissance des candidats les critères suivant lesquels ils seront présélectionnés ou sélectionnés ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au PAD et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Saisi d'un recours en annulation de cette décision du CRD, la Cour Suprême, par arrêt n° 18 du 22 mars 2012, rejeta le recours et partageant la même conception que le CRD elle déclara que :

1. Le moyen relatif à l'irrégularité de la composition du CRD n'est pas fondée car, conformément à l'article 18 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD a statué dans la composition de ses seuls membres, la présence d'observateurs n'affectant pas la régularité de la décision ;
2. L'existence d'un avis favorable émis par la DCMP lors du contrôle du projet de l'avis à manifestation d'intérêt, ne couvre pas les vices de la procédure, ne lie ni le CRD ni la DCMP, cette dernière n'étant pas dessaisie tant que toutes les étapes de la phase de contrôle ne sont pas terminées ; le PAD n'ayant pas respecté les règles de transparence et d'égalité des candidats en n'indiquant pas les modalités de leur sélection, a violé les articles 24 nouveau du COA et 79 et suivants de Code des Marchés Publics.

XX. OBLIGATION POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE D'AVOIR LA PERSONNALITE MORALE ET DE SOUMETTRE LE MARCHE A LA FORMALITE DE LA REVUE PREALABLE

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a fait publier dans le quotidien « le Soleil » des 19 et 20 avril 2010 un avis d'appel d'offres pour l'achat de deux (2) véhicules d'un montant total de F CFA 40 500 000 (Quarante millions cinq cent mille francs CFA).

Le 04 juin 2010, elle a fait publier dans le même quotidien un avis d'attribution provisoire dudit marché à la Société d' Equipement et de Représentation Automobile (SERA), puis saisit le 12 juillet 2010 la DCMP pour avis sur le rapport comparatif des offres et le procès verbal d'attribution provisoire.

La DCMP ayant émis un avis défavorable le 16 août 2010, aux motifs que les articles 67 à 70 du code n'ont pas été respectées et que le dossier n'a pas été soumis à la revue à priori, la CENTIF a saisi le CRD, par lettre du 19 août 2010, pour demander l'autorisation de poursuivre la procédure de passation.

Par décision n° 125 du 8 septembre 2010, le CRD prononça l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation et ordonna sa relance en faisant valoir que, d'une part, la commission des marchés qui a opéré est irrégulière et ses actes nuls de nullité absolue parce que la CENTIF étant un organisme non doté de la personnalité morale, relevant de l'Etat et placé sous l'autorité du Ministère chargé des Finances, sa commission des marchés est celle du Ministère de l'Economie et des Finances ; que d'autre part, le cumul des deux lots du marché étant de F CFA 40 500 000 (Quarante millions cinq cent mille francs CFA), il aurait dû être soumis à l'examen par la DCMP des rapports d'analyse comparative des offres et des procès-verbaux d'attribution provisoire, en vertu de l'arrêté n° 11 580 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 138 du code des marchés publics de 2007.

**DECISION N° 125/10/ARMP/CRD DU 08 SEPTEMBRE 2010
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA CELLULE NATIONALE DE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF) CONTESTANT
LA DECISION DE REJET PAR LA DCMP DE SA DEMANDE
D'IMMATRICULATION DU MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE DEUX
VEHICULES.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 308/MEF/CENTIF/AP du 19 août 2010 de la CENTIF ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, MM. Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends ;

De Messieurs Youssouf SAKHO, Directeur Général de l'ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre n° 308/MEF/CENTIF/AP du 19 août 2010, enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 623, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la CENTIF a contesté la décision de rejet de sa demande d'immatriculation du marché relatif à l'acquisition de deux véhicules par la DCMP.

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant qu'aux termes des articles 81.4 et 139.3 du code des Marchés publics, si l'autorité contractante n'accepte pas les recommandations formulées par la DCMP sur la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le CRD dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations ;

Considérant que dans le cas d'espèce, l'avis contesté de la DCMP a été rendu le 16 août 2010 ; que la saisine de l'ARMP est intervenue le 19 août 2010, la lettre de saisine enregistrée au Secrétariat du CRD le 20 août 2010 sous le numéro 623/10 ;

Qu'en considération de ces éléments, il convient de déclarer recevable le recours de la CENTIF qui a saisi le CRD dans le délai de trois jours prescrit par l'article 81.4 du Code des Marchés publics ;

LES FAITS

Suivant publication dans le quotidien « Le Soleil » des 19 et 20 avril 2010, la CENTIF a lancé un appel d'offres pour l'achat de deux véhicules, un 4 x 4 et une berline.

Le 04 juin 2010, elle a fait publier dans le même quotidien un avis d'attribution provisoire dudit marché à la Société d'Equipement et de Représentation automobile (SERA).

Suivant bordereau d'envoi du 12 juillet 2010, l'autorité contractante a saisi la DCMP pour avis sur le rapport comparatif des offres et le procès verbal d'attribution provisoire.

Le 16 août 2010, la DCMP a rendu un avis défavorable sur la proposition d'attribution du marché.

Par lettre en date du 19 août 2010, la CENTIF a saisi le CRD pour demander l'autorisation de poursuivre la procédure de passation.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa demande, la CENTIF a exposé avoir saisi une première fois la DCMP pour immatriculation du marché litigieux ; que le dossier a fait l'objet d'observations qui ont été prises en compte.

Par la suite, après plusieurs échanges de courriers, le dossier a fait l'objet de nouvelles observations, puis d'un second rejet par la DCMP pour des motifs qui sont étrangers à la CENTIF.

Par lettre en date du 29 juillet 2010 adressée à la DCMP et jointe au dossier, la CENTIF a soutenu que « *le principe de la revue a priori de la DCMP posé par l'article 2a de l'arrêté n°11580 du 28 décembre 2007, pris en application de l'article 138 du Code des marchés*

publics, fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés n'est pas applicable à la CENTIF et cela au regard des dispositions de l'article 2.2 du code » ;

Que sur la représentation de la tutelle au niveau de la Commission des marchés de la CENTIF, sur saisine du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, en réponse, il a été indiqué par lettre n°0404/MEF/DGF/COF du 15 avril 2010 que cette représentation n'est pas nécessaire ;

Qu'en ce qui concerne le rapport d'analyse comparative des offres et le procès verbal d'attribution du marché, les observations initialement formulées par la DCMP ont été prises en compte et le rapport corrigé transmis ;

Que s'agissant de la qualification du candidat dont l'offre est la moins disante, elle a été bien examinée dans le respect strict des dispositions des articles 67 à 70 du Code des marchés publics par la Commission des marchés.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Il ressort des lettres en date des 16 juillet et 10 août 2010, que la DCMP a justifié son avis défavorable à la poursuite de la procédure, par l'irrégularité résultant de la composition de la Commission des marchés qui a procédé à l'évaluation des offres et a proposé à l'attribution provisoire le marché litigieux.

En effet, la DCMP a estimé que la Commission ne comprenait pas le représentant du ministère de tutelle.

Sur le rapport d'analyse et d'attribution, la DCMP a relevé que le modèle de rapport d'analyse type n'a pas été utilisé.

Par ailleurs, l'examen de la qualification du candidat, dont l'offre conforme a été évaluée la moins disante, n'a pas été fait.

Au regard de ces éléments et d'autres, la DCMP a conclu que la proposition d'attribution n'a pas été faite conformément aux dispositions des articles 67 à 70 du Code des marchés publics.

Enfin, la DCMP a estimé que le seuil de revue du rapport d'analyse et du procès verbal d'attribution provisoire, soit 40 000 000, a été atteint et que, par conséquent, le dossier aurait du être soumis à la revue a priori.

SUR L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs exposés par les parties que le litige porte sur :

- la régularité de la composition de la Commission des marchés ;
- le fondement du refus d'immatriculer pour non soumission du rapport d'analyse comparative des offres et du procès verbal d'attribution du marché à la formalité de revue préalable.

AU FOND

SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA CENTIF :

Considérant que selon la DCMP, la Commission des marchés de la CENTIF doit être constituée conformément aux dispositions des articles 36 et 37.3 et donc, comporter en son sein le représentant du Ministre chargé de la tutelle de la CENTIF ;

Qu'à cet égard, la CENTIF a produit copie de la lettre n°0404/MEF/DGF/COF du 15 avril 2010 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, Ministre de tutelle de la CENTIF, par laquelle celui-ci a soutenu n'être plus représenté dans les Commissions des marchés des ministères ou autres structures administratives, comme la CENTIF ;

Que cette autorité a justifié sa décision par la simplification introduite depuis le 1^{er} janvier 2008 dans les procédures de passation des marchés, mais aussi dans la composition des nouvelles structures devant accompagner ce processus, notamment les cellules de passation des marchés qui sont uniquement composées de membres choisis au sein de chaque structure dépendant d'une autorité contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 alinéa 1^{er} du Code des marchés publics, les commissions des marchés sont composées de représentants de l'autorité contractante dont le nombre et les conditions de désignation sont déterminés par chaque catégorie d'autorité contractante par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics, ainsi que des représentants des autres administrations et organismes concernés mentionnés à l'article 37 ;

Que selon l'article 37 du Code des marchés publics, pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.1c) du code, outre les représentants de l'autorité contractante, participe également aux commissions des marchés de ces structures un représentant du Ministre chargé de la tutelle de la société, établissement, agence ou organisme concerné ;

Considérant qu'il ressort du décret n°2004-1150 du 18 août 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CENTIF, notamment en son article 2, que la CENTIF est un service administratif doté de l'autonomie financière, placée sous l'autorité du Ministre chargé des Finances ;

Considérant qu'en considération de cette disposition, la CENTIF, qui n'a pas de personnalité propre est au regard de l'article 2.1.a) un organisme non doté de la personnalité morale relevant du Ministère de l'Economie et des Finances, comme autorité contractante ;

Qu'à cet égard, la Commission des marchés de la CENTIF se confond avec celle de l'autorité de tutelle, en l'occurrence, Ministère de l'Economie et des Finances ;

Considérant que la désignation des membres des Commissions des marchés doit se faire selon les règles régissant leur composition ; que l'irrégularité de la composition des commissions des marchés entraîne la nullité des actes pris par ces commissions ;

Qu'en conséquence et en considération des développements qui précèdent, la Commission constituée par la CENTIF sans considération de ces exigences est irrégulière et les actes pris par elle sont nuls et de nullité absolue ;

Sur le fondement du refus d'immatriculer pour non soumission du rapport d'analyse comparative des offres et du procès verbal d'attribution du marché à la formalité de revue préalable :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté n°11580 du 28 décembre 2007, pris en application de l'article 138 du Code des marchés publics, le seuil d'examen par la DCMP des rapports d'analyse comparative des offres et des procès verbaux d'attribution provisoire des marchés établis par les commissions des marchés visées à l'article 138 b) du Code des Marchés publics sont fixés comme suit pour les marchés autres que ceux relatifs à l'entretien courant de routes et ceux passés par les personnes morales visées par les alinéas 2.1c et 2.1d de l'article 2 du Code des Marchés publics :

- quarante (40) millions FCFA TTC pour les marchés de fournitures et les services y compris les prestations intellectuelles ;
- cent (100) millions FCFA TTC pour les marchés de travaux ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le marché litigieux composé de deux lots est chiffré à trente et un millions (31 000 000) FCFA TTC pour le lot 1, et à neuf millions cinq cent mille (9 500 000) F CFA TTC pour le lot 2 ;

Que le cumul des deux lots fait que le seuil d'examen par la DCMP des rapports d'analyse comparative des offres et des procès verbaux d'attribution provisoire est atteint ; qu'en conséquence, le marché litigieux est soumis à l'examen par la DCMP des rapports d'analyse comparative des offres et des procès verbaux d'attribution provisoire ;

Qu'en considération de ces éléments et, surtout, de l'irrégularité de la composition de la Commission des marchés qui a ouvert les plis et évalué les offres, il convient de prononcer l'annulation de l'ensemble de la procédure et d'ordonner sa relance ; en conséquence,

DECIDE :

- 7) Reçoit la CENTIF en sa saisine ;
- 8) Constate que la CENTIF est un organisme non doté de la personnalité morale, relevant de l'Etat et placé sous l'autorité du Ministre chargé des Finances ;
- 9) Dit que la Commission des marchés en charge des opérations de la CENTIF est celle du Ministère de l'Economie et des Finances ; en conséquence,
- 10) Dit que la Commission des marchés qui a ouvert les plis et évalué les offres relatives au marché litigieux est irrégulière et que les actes qu'elle a pris, notamment la proposition d'attribution du marché concerné, sont nuls de nullité absolue ;
- 11) Ordonne à la CENTIF la relance de la procédure de passation du marché concerné ;
- 12) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la CENTIF et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mansour DIOP

Suite à la décision du CRD, la CENTIF intenta un recours en annulation devant la Cour Suprême et cette dernière le rejeta en jugeant que :

1. Le moyen de la CENTIF tirée de l'incompétence de la commission des litiges du CRD de l'ARMP n'est pas fondé parce que même si la CENTIF a donné la qualification de demande d'avis au recours qu'elle a adressé au CRD, il s'agit plutôt d'une contestation de l'avis défavorable de la DCMP dont est compétente la commission des litiges du CRD ;
2. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle est mal fondé parce que le marché ayant atteint le seuil de 40 000 000 (Quarante millions) devait être soumis à la formalité de revue préalable, en vertu de l'arrêté 11 580 du 28 décembre 2007 ;
3. Les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ; en effet, c'est à bon droit que le CRD a retenu comme nuls et de nullité absolue les actes pris par la commission des marchés mise en place irrégulièrement par la CENTIF qui, en tant que service administratif dépourvu de la personnalité morale ne peut avoir sa propre commission des marchés, parce que même si le code des marchés publics, en son article 2.1-a fait des organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous l'autorité de l'Etat, des autorités contractantes, cela est en contradiction avec l'article 1^{er} de la directive n° 04/2005/CM/UEMOA, norme supérieure, qui rend tributaire la qualité ;

4. d'autorité contractante de ces organisations ou agences à l'octroi de la personnalité morale (arrêt n° 29 du 10 mai 2012)

En France, c'est la notion de « pouvoir adjudicateur public », remplaçant celle de personne responsable du marché, qui est utilisée dans le code. Et l'article 2 dudit code ne donne la qualité de « pouvoir adjudicateur public » soumis au code qu'à des entités ayant une personnalité morale, à savoir :

1. L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

XXI. CONCLUSION D'UN AVENANT POSTERIEUREMENT A LA REALISATION DES PRESTATIONS ET APPLICATION DU CODE A TOUS LES MARCHES PUBLICS

A la suite d'un appel d'offres, la SICAP SA. a désigné les entreprises CSTP SARL et SAHEL Group SA pour réaliser les travaux de construction de logements du programme SICAP MBAO Villeneuve – Phase II.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, les deux (2) entreprises précitées ont réalisé des prestations supplémentaires en fondation, non comprises dans leur devis de base en vue d'assurer la stabilité des constructions et garantir leur sécurité, sans attendre la signature d'un avenant.

Par lettre en date du 09 mai 2012, la SICAP SA. a saisi la DCMP pour obtenir un avis préalable relatif au projet d'avenant au contrat initial, en vertu de l'article 23 alinéa 2b du code des marchés publics de 2011.

Mais la DCMP émet un avis défavorable aux motifs que, d'une part, la SICAP a violé les dispositions de l'article 44 du Code des Obligations de l'Administration (COA), pour avoir réalisé les travaux incriminés sans attendre la conclusion de l'avenant et que d'autre part, en vertu de la clause 15 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), la seule exception aux dispositions précitées concerne les travaux non prévus dans le marché de base, auquel cas l'avenant en charge desdits travaux pourrait intervenir après leur exécution.

Par lettre du 30 juillet 2012, la SICAP, en précisant que l'article 23 du code lui permet de signer l'avenant avant la réception provisoire, saisit le CRD sur la question et sur la conduite à tenir face à des situations similaires auxquelles elle est régulièrement confrontée tout en demandant des précisions sur le champ d'application de l'article 4 du COA.

Le CRD, par décision n° 93 du 21 août 2012 autorisa la conclusion de l'avenant puisque la réception provisoire des travaux du marché litigieux n'a pas été prononcée, en référence à l'article 23.3 du code des marchés publics tout en faisant valoir que certes les travaux sont dûs à des imprévus, mais que l'autorité contractante doit observer les règles régissant les travaux de cette nature et éviter à l'avenir de pareils manquements.

Le CRD précisa, en outre, qu'en application des dispositions combinées des articles premier du COA et 4.21 du code des marchés publics de 2011, tous les marchés publics conclus par les personnes morales de droit public qu'ils soient des contrats administratifs ou non, sont soumis audit code.

DECISION N° 093/12/ARMP/CRD DU 21 AOUT 2012
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE LA SICAP.SA SOLLICITANT
L'AUTORISATION DE CONCLURE, PAR AVENANT, LES TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES EFFECTUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
CONSTRUCTION DE DEUX CENT LOGEMENTS ECONOMIQUES ET
CINQUANTE DUPLEX A SICAP MBAO VILLENEUVE PHASE 2, SUITE A L'AVIS
DEFAVORABLE DE LA DCMP.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 1321/DT en date du 30 Juillet 2012 de la SICAP SA, reçue le 1^{er} août 2012, puis enregistrée le 02 août 2012 sous le numéro 662/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd'El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d'enquête sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre n° 1321/DT en date du 30 Juillet 2012, reçue le 1er août 2012, puis enregistrée le 02 août 2012 sous le numéro 662/12, la SICAP SA a saisi le CRD pour bénéficier d'un avis relatif aux modifications apportées au contrat de travaux de construction de deux cent logements économiques et cinquante duplex à SICAP MBAO Villeneuve Phase 2, suite à l'avis défavorable de la DCMP.

A l'appui de sa demande, le requérant a produit copie des documents suivants :

- Copie de la lettre de la SICAP SA en date du 02 avril 2012,
- Copie de la lettre n° 0824/MEF/DCMP/24 en date du 14 février 2012,
- Copie de la lettre de la SICAP SA en date du 17 février 2012,
- Copie du projet d'Avenant N°1 au marché N° T/121/FM,
- Copie de la lettre n° 1680/MEF/DCMP/72 en date du 17 avril 2012,
- Copie de la lettre de la SICAP SA en date du 09 mai 2012,
- Copie de la lettre n° 2125/MEF/DCMP/14 en date du 16 mai 2012,
- Copie de la lettre de TOPO PLUS en date du 24 juillet 2012,
- Copie de la lettre du Bureau ALPAGES en date du 15 janvier 2010,
- Copie du devis des travaux projetés.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 140 du Code des marchés publics, la DCMP est chargée d'émettre un avis sur les avenants aux marchés qui sont soumis à la revue a priori ;

Considérant que selon l'article 22 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, la Commission Litiges est chargée de statuer sur les litiges entre les organes de l'Administration ;

Considérant que suite à une saisine de la SICAP SA, l'organe chargé du contrôle a priori a, en réponse par courrier du 16 mai 2012, reçu le 21 mai 2012, donné un avis défavorable à la conclusion de l'Avenant n°1 du marché susnommé ;

Considérant que l'autorité contractante a introduit une requête devant le CRD par lettre du 30 Juillet 2012, reçue le 1er août 2012, puis enregistrée le 02 août 2012, pour demander l'autorisation de conclure ledit avenant ;

Considérant qu'en l'espèce, ce recours n'est soumis à aucun délai, il y a lieu de le déclarer recevable ;

LES FAITS

A la suite d'un appel d'offres, la SICAP SA a désigné les entreprises CSTP SARL et SAHEL GROUP SA, respectivement attributaires des lots 1 et 2 du marché pour la réalisation des travaux de construction de 300 logements économiques et 50 duplex du programme SICAP MBAO VILLENEUVE PHASE II, actuellement en cours à hauteur du carrefour de Keur Massar.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, les deux entreprises précitées ont réalisé, entre autres, les prestations supplémentaires en fondation non comprises dans leur devis de base.

La SICAP SA a saisi la DCMP par lettre en date du 09 mai 2012, pour obtenir un avis préalable relatif au projet d'avenant au contrat susvisé en vertu de l'article 23 alinéa 2 b du Code des Marchés Publics (CMP).

Après examen du dossier, La DCMP a rendu un avis défavorable.

La SICAP SA a sollicité, par lettre en date du 30 juillet 2012, l'avis du CRD sur la question et sur la conduite à tenir face à des situations similaires auxquelles elle est régulièrement confrontée.

MOYENS FOURNIS A L'APPUI DE LA SAISINE

Afin de garantir la stabilité et la sécurité des constructions du marché pour la réalisation des travaux de construction de 300 logements économiques et 50 duplex du programme SICAP MBAO VILLENEUVE PHASE II, l'entreprise CSTP SA a effectué, en cours de travaux, les modifications suivantes :

- l'augmentation de la profondeur des fondations pour atteindre le bon sol situé au-delà des 60 cm prévus dans le Cahier des prescriptions techniques particulières,
- l'installation d'une couche de polyane pour éviter les remontées capillaires en raison de la situation géographique du terrain et surtout du constat fait après la saison des pluies,
- l'élévation du niveau des dallages pour assurer une bonne mise hors d'eau des constructions et
- la mise à la terre du neutre sur le réseau d'alimentation électrique.

Ensuite, la SICAP SA a supprimé du marché, certaines prestations comme la niche pour le compteur électrique dans le lot « Electrification », le bac à laver, le portail, le portillon et la rampe pour escalier pour le « Type Economique ».

Selon l'autorité contractante, l'avenant résultant des modifications opérées ne peut être signé avant l'exécution des travaux, au motif que certains coûts y relatifs ne peuvent être calculés d'avance.

C'est le cas par exemple de la sur-profondeur à creuser pour atteindre le bon sol d'assise d'une fondation, ou de la quantité de sable nécessaire pour réaliser une purge sur une route.

Ces travaux font l'objet d'attachements contradictoires pour déterminer les quantités effectivement mises en œuvre, sur lesquelles seront appliquées les prix unitaires de base.

Pour terminer, la SICAP SA se pose des questions sur l'étendue du champ d'application de l'article 4 du Code des Obligations de l'Administration, étant donné que les marchés conclus avec une société à participation publique majoritaire de droit privé, ne constituent pas des contrats administratifs selon l'article 4.21 du Code des marchés publics.

Elle précise également que l'article 23 du CMP permet à l'autorité contractante d'ordonner la réalisation de certaines prestations, en prenant soin de signer l'avenant s'y rapportant avant la réception provisoire des travaux.

LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LA DCMP

La DCMP estime que l'autorité contractante n'a pas respecté les dispositions de l'article 44 du Code des obligations de l'Administration qui prévoit que le contrat ne peut produire d'effet qu'après l'approbation de l'autorité administrative compétente.

Or, l'autorité contractante a réalisé les travaux incriminés sans attendre la conclusion dudit avenant.

Pour justifier ce refus, elle invoque également la clause 15 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui stipule que la seule exception aux dispositions précitées concerne les travaux non prévus dans le marché de base, auquel cas l'avenant prenant en charge lesdits travaux pourrait intervenir après leur exécution.

L'OBJET DU RECOURS

Il ressort des faits, moyens et motifs ci-dessus développés que la demande porte, d'une part, sur la possibilité de conclure un avenant après avoir effectué les prestations, d'autre part, sur la conduite à adopter dans le futur, face à des cas similaires.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 23 du Code des marchés publics que les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire l'objet d'un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l'autorité contractante et du titulaire du marché. Un avenant ne peut porter que sur les objets suivants :

- a) la modification de clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution, y compris les changements affectant l'autorité contractante ou ceux affectant la forme ou la structure juridique du titulaire, sans remettre en cause les éléments du choix initial ni l'économie du marché, ni le titulaire du marché ;

- b) l'augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux excédant les variations maximales prévues par le dossier d'appel à la concurrence ;
- c) la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l'exécution de son objet, du fait de la survenance de sujétions imprévues ;
- d) la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial.

Considérant que dans le cadre du marché susnommé, la SICAP SA, en relation avec le bureau de contrôle ALPAGES et le géomètre du projet, TOPO PLUS, a pris des mesures en cours de travaux, pour assurer la stabilité des constructions et garantir leur sécurité, sans attendre la signature d'un avenant ;

Considérant que pour cette raison, la DCMP a valablement estimé que la SICAP n'a pas respecté les dispositions de l'article 44 du COA et a refusé ainsi, d'accorder un avis favorable à la demande introduite ;

Considérant que dans le procès-verbal de visite de chantier daté du 21 octobre 2009, établi par le bureau de contrôle ALPAGES, il est mentionné ce qui suit : « Suite à notre visite de ce jour au chantier ci-dessus, nous vous faisons part de :

Vu sondages de profondeur de 1,70 m, nous avons un sable homogène de couleur ocre sur toute la hauteur. Nous validons la contrainte de calcul de 1,5 bars.

Le niveau de la nappe variant entre 1,50 m et 60 cm suivant les zones, nous vous demandons de prendre les dispositions suivantes :

- prévoir un film polyane au dessus du dallage,
- élever le niveau fini de dallage au sol à au moins 50 cm par rapport au TN,
- prendre les dispositions pour couler les semelles avant remontées de la nappe...,
- Ancrer les semelles au moins à 80 cm par rapport au TN... » ;

Considérant que par lettre du 24 juillet 2012, le topographe TOPO PLUS a fait parvenir à la SICAP SA, les hauteurs des soubassements suivantes qui ont été effectuées, après code de terrassement :

- 35 logements à 0,80 m,
- 95 logements à 0,60 m,
- 76 logements à 0,30 m ;

Considérant qu'à cet égard, s'il est établi que les travaux qui portent sur des postes prévus, ont été effectués préalablement à la signature d'un avenant, il apparaît que la SICAP SA a commis un manquement en omettant de déterminer aussi exactement que possible, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;

Qu'en effet, il appartenait à l'autorité contractante, compte tenu de la nature du marché, de diligenter les études géotechniques et topographiques nécessaires en amont, afin de les porter à l'information des candidats ;

Considérant que toutefois, l'avis défavorable de la DCMP, quoique bien fondé, entrainerait une sanction à l'égard de l'entreprise pour avoir exécuté de bonne foi, des prestations imprévues pour assurer une sécurité à l'édifice, mais recommandées par le bureau de contrôle ;

Considérant qu'à cet égard, et compte tenu des recommandations du bureau ALPAGES, le CRD admet à titre exceptionnel, la conclusion de l'avenant portant sur les prestations effectuées par la société CSTP ;

Considérant qu'en revanche, il appartient à la SICAP SA d'observer les règles régissant les travaux de cette nature et éviter, pour l'avenir, la survenance de pareils manquements ;

Considérant également que par rapport à l'étendue du champ d'application de l'article 4 du COA, tous les marchés publics conclus par des personnes morales de droit public, qu'ils soient des contrats administratifs ou non, demeurent soumis au Code des marchés publics, en référence aux dispositions combinées des articles premier du COA et 4.21 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 ;

Considérant que par ailleurs, même s'il est constant que l'autorité contractante a commis un manquement, il apparaît que la conclusion d'un avenant est possible en considération des dispositions de l'article 23.3 du Code des marchés publics, au motif que la réception provisoire desdits travaux n'a pas été prononcée ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare recevable la saisine ;
- 2) Dit que tous les marchés publics conclus par des personnes morales de droit public, qu'ils soient des contrats administratifs ou non, demeurent soumis au Code des marchés publics, en référence aux dispositions combinées des articles premier du COA et 4.21 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 ;
- 3) Constate que les travaux litigieux ont été réalisés avant la signature de l'avenant ; à cet égard,
- 4) Constate que les travaux résultent de la survenance, en cours de travaux, d'imprévus dûs à des manquements imputables à l'autorité contractante ; toutefois,
- 5) Dit qu'il peut être autorisée la conclusion de l'avenant n°1 précité puisque la réception provisoire des travaux du marché litigieux n'a pas été prononcée, en référence aux dispositions de l'article 23.3 du Code des marchés publics ;
- 6) Dit qu'il appartient désormais à la SICAP SA d'observer les règles régissant les travaux de cette nature et éviter, pour l'avenir, la survenance de pareils manquements ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la SICAP SA, ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président
Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD**Mamadou DEME****Abd'El Kader NDIAYE****Ndiacé DIOP****Le Directeur Général
Rapporteur****Saër NIANG**

Les marchés publics ne sont pas forcément des contrats administratifs, car les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire demeurent des contrats de droit privé, même s'ils sont passés selon les règles prévues par le code des marchés publics (exposé de motif de la loi n° 2006.16 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant code des obligations de l'administration).

Par ailleurs, l'article 23.3 d code de 2011 est aussi formulé : « aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet ».

Donc, à contrario, il est possible de conclure un avenant tant que la réception provisoire de l'objet du marché n'a pas été faite.

C'est ce raisonnement à contrario que le CRD a utilisé pour pouvoir autoriser la conclusion de l'avenant.

Cette disposition n'existe pas dans l'article 20 du code français relatif à la condition de validité des avenants.

Pour la doctrine française, l'avenant doit être totalement imprévisible. Il est généralement estimé raisonnable d'admettre qu'une augmentation du montant d'un marché par un ou plusieurs avenants successifs, inférieurs à 15% du montant initial de ce marché, ne présente pas, généralement, de caractère abusif.

Le juge saisi statue in concreto ; il a ainsi refusé un avenant augmentant de 18% le montant total d'un marché fractionné (T.A Lille, 8 juillet 1997, Préfet du Pas-de-Calais contre Commune de Lens et autres ; RFDA, 1998, p. 546), tandis qu'il a admis la validité d'une augmentation de près de 38% d'un autre marché (CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois, req. N° 150681).

XXIII. DENONCIATION D'IRREGULARITES COMMISES PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES

Aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des marchés Publics (ARMP) : « Le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission des litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes, ».

Suite à la publication par le COSEC d'un avis d'appel d'offres pour des travaux de construction à Ndoum répartis en deux (2) lots, le lot 1 d'un montant de F CFA 466 821 050 (Quatre cent soixante six millions huit cent vingt et un mille cinquante francs CFA) a été attribué provisoirement à la Société Sénégal Everyday International Trade Company (SEITC) qui en a reçu notification par l'autorité contractante par lettre n° 02089/COSEC du 21 décembre 2009. Dans l'attente de la publication de l'avis d'attribution définitif, l'attributaire provisoire, SEITC, a été informée, par le Président du Conseil d'Administration du COSEC, de l'annulation du marché.

Trouvant cette manière de faire irrégulière, SEITC en a saisi le CRD par dénonciation. Par décision n° 23 du 9 février 2011, le CRD, statuant en commission litiges, a déclaré que la décision d'annulation est irrégulière et a ordonné son retrait en demandant à l'autorité contractante de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite de la procédure conformément à la réglementation en vigueur.

A l'appui de sa décision, le CRD a fait valoir, d'une part, que le Président du Conseil d'Administration n'est pas compétent pour annuler le marché parce qu'il résulte de la combinaison des articles 27, 28, et 82 du code des marchés publics et des dispositions de la loi n° 75-51 du 3 avril 1975 créant le COSEC, que non seulement il appartient au Directeur Général du COSEC, personne responsable du marché, de conduire la procédure de passation du marché et de le signer au nom de l'autorité contractante, mais également au vu du montant du marché l'autorité d'approbation est le ministre chargé des finances, et le refus d'approbation ne peut intervenir qu'en l'absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants ; que d'autre part, la procédure en matière d'annulation n'a pas été respectée, car non seulement il résulte de la combinaison des articles 11, 64 et 65 du code des marchés publics que l'autorité contractante qui a reçu et ouvert les offres ne peut arrêter la procédure que dans des cas précis limitativement énumérés par la loi, mais également, aux termes de l'article 51 de la directive 04/2005/CM/UEMOA, avant d'annuler un marché, l'autorité contractante doit, préalablement, en faire la demande motivée à l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics.

DECISION N° 023/11/ARMP/CRD DU 09 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LA DENONCIATION DE LA SOCIETE
SENEGAL EVERYDAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY (SEITC) DE LA
DECISION DE NE PLUS DONNER SUITE A L'APPEL D'OFFRES APRES
ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION
D'UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE ET D'UNE FABRIQUE DE GLACE A NDIOUM

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ; notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié.

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 31 décembre 2010 de la SEITC ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Oumar SARR, présentant les faits, moyens et conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, et de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Mamadou DEME, Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre du 31 décembre 2010, enregistrée le même jour sous le numéro 884 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la SEITC a saisi le CRD d'une réclamation relative à l'« annulation » de l'attribution du lot 1 du marché relatif à la construction d'un entrepôt frigorifique et d'une fabrique de glace à Ndioum.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant que la SEITC a saisi le CRD d'une réclamation relative à l'« annulation » du marché dont elle a été déclarée attributaire provisoire alors que l'appel d'offres n'a pas été déclaré infructueux ni que l'autorité contractante n'a décidé de ne pas donner suite ;

Considérant que c'est par une simple déclaration verbale du Président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC), autorité contractante, que la société requérante a été informée de l'annulation de la procédure ; que cette « annulation » a été confirmée au CRD par le Directeur général de ladite autorité par lettre n°00072/COSEC du 01^{er} février 2011, à l'occasion de la transmission du dossier d'appel d'offres ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la SEITC, désignée attributaire provisoire du lot 1 du marché, n'a pas été mise en état d'user de son droit de recours conformément aux articles 86 et 87 du Code des marchés publics ;

Qu'en conséquence, il convient d'analyser sa saisine comme une dénonciation entrant dans les prévisions de l'article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des marchés publics (ARMP) qui dispose : « *Le Comité de Règlement des Différends est chargé :*

- *de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties ou connues de toute autre personne avant, pendant, et après la passation ou l'exécution des marchés et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit la Formation disciplinaire, selon les cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes » ;*

Considérant que la saisine du CRD, effectuée par le Président du CRD, sur le fondement de cette disposition n'est soumise à aucune condition de délai ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la présente saisine ;

LES FAITS :

Le COSEC a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » des 02, 03 et 04 octobre 2009 un avis d'appel d'offres pour des travaux de construction à NDioum, répartis comme suit :

- Lot 1 : Travaux de construction d'un entrepôt frigorifique, d'une fabrique de glace, de chambres froides, de réserve d'eau et la fourniture de groupes électrogènes ;
- Lot 2 : Travaux de construction d'un bâtiment administratif comportant une loge pour gardien, un mur de clôture, une voirie, un assainissement et un raccordement aux réseaux des concessionnaires (électricité, téléphone et eau), d'un parking et d'un aménagement extérieur et l'installation d'un système de sécurité incendie.

A l'ouverture des plis, comme en atteste le procès verbal en date du 04 novembre 2009, trois offres ont été reçues des candidats RDC, SEITC et ESMB, chacun ayant soumissionné pour les deux lots.

Le 03 décembre 2009, comme il résulte du procès verbal d'attribution provisoire, la Commission des marchés du COSEC a proposé à l'approbation de l'autorité contractante l'attribution du marché ainsi qu'il suit :

- Lot 1 au candidat SEITC pour 466 821 050 FCFA;
- Lot 2 au candidat RDC pour 172 674 605 FCFA.

Par lettre n°02089/COSEC du 21 décembre 2009, l'autorité contractante a notifié à la SEITC l'attribution provisoire du marché.

Dans l'attente de la publication de l'avis d'attribution définitif, l'attributaire provisoire a été informé par le Président du Conseil d'administration de l'autorité contractante, de l'« annulation » du marché.

Le 31 décembre 2010, SEITC a saisi le Président du CRD d'une réclamation pour dénoncer cette manière de faire qu'elle a trouvée irrégulière.

LES MOYENS PRESENTES A L'APPUI DE SA SAISINE :

A l'appui de sa réclamation, la SEITC a produit la lettre n°02089/COSEC du 21 décembre 2009 par laquelle, le Directeur général du COSEC lui a notifié l'attribution provisoire du lot 1 du marché pour le prix de 466 821 050 F CFA. Par la même occasion, l'autorité contractante a déclaré revenir vers elle dès que le marché sera approuvé après épuisement du délai de recours non juridictionnel.

La SEITC a exposé sa surprise d'apprendre par le canal du Président du Conseil d'administration l'« annulation » du marché.

MOTFS INVOQUES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre n°00072/COSEC du 01^{er} février 2011, de transmission des documents de l'appel d'offres, le Directeur général du COSEC a déclaré avoir reçu, par lettre en date du 12 novembre 2010 du Président du Conseil d'administration, notification de la décision du Conseil d'administration de ne plus réaliser le projet objet du marché.

OBJET DU LITIGE

Considérant qu'il résulte des faits, moyens et motifs présentés par les parties, que le litige porte sur la régularité de la décision annoncée par le Président du Conseil d'administration d'annuler la procédure de passation du marché, attribué provisoirement à la SEITC.

AU FOND

Considérant que l'examen de l'objet du litige implique aussi que soit déterminée la compétence du président du Conseil d'administration sur ses prérogatives en matière de passation de marchés publics ;

Sur la compétence du Président du Conseil d'administration en matière de passation du marchés publics des établissements publics :

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 27 et 28 du Code des marchés publics, **« la procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante »** ;

Considérant que s'agissant des marchés des établissements publics, agences et autres visé à l'article 2.1c) du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics, modifié, la personne responsable des marchés est l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables ;

Considérant que le COSEC, établissement public créé par la loi n°75-51 du 03 avril 1975, a pour organe exécutif désigné son Directeur général ;

Considérant outre sa qualité de personne responsable des marchés publics du COSEC, selon l'article 28 d) du Code des marchés publics, le Directeur général est également investi du pouvoir d'approbation des marchés lorsque le montant du marché est inférieur à 50 millions de francs ;

Que le pouvoir d'approbation des marchés ne revient au Président du Conseil d'administration que lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions mais n'atteint pas 150 millions ;

Qu'au-delà de 150 millions, le marché litigieux étant de 466 821 050 F CFA, le pouvoir d'approbation est de la compétence du Ministre chargé des Finances ;

Que donc, en l'espèce, l'autorité d'approbation est le Ministre chargé des finances et celle compétente pour conduire la procédure de passation du marché le Directeur général du COSEC, lequel est seul habilité à remplir les formalités nécessaires à la passation du marché, notamment effectuer les notifications aux candidats ou soumissionnaires des décisions des organes compétents pour dérouler la procédure de passation, à savoir : la Commission des marchés, la Cellule de passation des marchés, la personne responsable du marché et l'autorité d'approbation du marché ;

Que l'intervention des autorités d'approbation visées à l'article 29 du Code des marchés publics s'opère dans les limites fixées par l'article 82 qui dispose in fine que **« le refus d'approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu'en l'absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants »** ;

Sur la régularité de la décision du Conseil d'administration ou de son Président d'annuler l'attribution du marché au candidat SEITC :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le Président du Conseil d'administration a, d'une part, annoncé l'annulation du marché à l'attributaire provisoire et d'autre part, notifié au Directeur général du COSEC l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la Directive 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, « *si l'autorité contractante décide que la procédure soit annulée, elle en fait la demande motivée à l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions réglementaires communautaires en vigueur en matière de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public* »

Considérant qu'en dehors de cette hypothèse, comme il résulte des dispositions combinées des articles 11, 64 et 65 du Code des marchés publics, l'autorité contractante qui a reçu et ouvert les offres ne peut pas arrêter la procédure de passation, sauf :

- 1) Lorsqu'aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres non conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à concurrence aient été remplies. Elle peut alors procéder à un appel d'offres restreint conformément aux articles 73 et 74 du Code des marchés publics ;
- 2) Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché ;

Que dans tous les cas, pour en décider, comme il est indiqué aux 1) et 2), l'autorité contractante doit au préalable requérir l'avis de la DCMP ;

Considérant que dans le cas d'espèce, il ne résulte ni des éléments du dossier, ni des conclusions des parties que l'autorité contractante a pris l'avis de la DCMP avant de décider de l'annulation de la procédure ;

Que bien au contraire, il ressort des informations obtenues auprès de la DCMP que le marché a, après son approbation le 04 juin 2010, fait l'objet d'immatriculation sous le numéro T0363/10 ;

Considérant ces éléments, il y a lieu de s'interroger sur les intentions du Président du Conseil d'administration de l'autorité contractante lorsque celui-ci a déclaré la procédure de passation du marché annulée ;

Qu'en tout état de cause, la décision querellée est irrégulière en ce que, d'une part, elle ne résulte ni de l'organe compétent, ni de la procédure prévue à cet effet ; en conséquence,

DECIDE :

- 13) Déclare la saisine du Président du Comité recevable ;
- 14) Constate que le Président du Conseil d'administration de l'autorité contractante a décidé « *d'annuler l'attribution* » du lot 1 du marché relatif à la construction d'un entrepôt frigorifique et d'une fabrique de glace à NDioum à la SEITC ;
- 15) Dit que cette décision n'a pas été prise ni par l'organe responsable du marché représentant l'autorité contractante, ni conformément à la procédure prévue à cet effet ;
- 16) Dit que l'annulation du marché, décidée par le Président du Conseil d'administration alors qu'il n'est pas l'organe habilité à conduire la procédure de passation en tant que personne responsable, représentant l'autorité contractante, et alors que le marché a fait l'objet d'approbation et d'immatriculation, est irrégulière ;
- 17) Constate que cette décision, indépendamment de l'irrégularité qui la frappe, est, au sens de l'article 89 du Code des marchés publics, de nature à causer un dommage aux intérêts des parties ; en conséquence ;
- 18) Ordonne le retrait de la décision d'annulation et demande à l'autorité contractante de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite de la procédure conformément à la réglementation en vigueur ;
- 19) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société SEITC, à COSEC ainsi qu'à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les règles de compétence sont d'ordre public ; les actes accomplis par une personne incompétente (conclusion de marché, approbation, annulation, etc.) sont nuls et de nullité absolue. Sans qu'aucune partie ne l'invoque, le vice d'incompétence peut être soulevé d'office par la Cour Suprême en cas de contestation de la légalité d'un marché public déféré devant elle.

La doctrine et la jurisprudence française partagent cette conception de la nullité absolue de l'acte entaché de vice d'incompétence. La nullité du marché prononcée pour incompétence est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique ; le cocontractant pourra alors demander l'indemnisation du préjudice que lui aura causé la faute de l'autorité contractante.

XXIV. DENONCIATION DE LA PRODUCTION PAR LES CANDIDATS ET ATTRIBUTAIRES DE DOCUMENTS PRESUMES FAUX

Dans le journal « Le Soleil » des 11, 12 et 13 juin 2011, l'AGETIP a fait publier un avis d'appel d'offres ayant pour objet des travaux de construction de voiries, d'ouvrages de franchissement et des travaux confortatifs de la gare routière de Kothiary dans la Commune de Tambacounda, dans le cadre du Programme de Renforcement et d'Equipement des collectivités Locales (PRECOL) ;

A l'ouverture des plis du 26 juillet 2011, plusieurs entreprises, dont l'entreprise sénégalaise de Promotion immobilière et de Services (SPIS), ont présenté des offres. Mais, au cours de l'évaluation, à la suite des investigations menées par la commission des marchés de l'AGETIP, il s'est avéré que des « attestations de travaux similaires » fournies par le candidat SPIS ne sont pas authentiques.

Mis au courant de cela, le Directeur Général de l'AGETIP a saisi d'une dénonciation le Président du CRD qui, à son tour, a saisi le CRD siégeant en commission disciplinaire. Les investigations menées par le CRD auprès des entreprises qui auraient établi ces attestations pour le compte de SPIS, révélèrent que les attestations produites par ladite entreprise sont fausses. Les responsables de l'entreprise SPIS n'ont pu être entendus sur la question parce que l'unique numéro de téléphone mentionné dans l'offre est hors service et un soin particulier a été pris pour dissimuler l'auteur du document présumé faux, aucune personne physique n'apparaissant dans les pièces déposées par le candidat, toutes choses pouvant faire penser que la SPIS est une société fictive.

Par décision n° 11 du 26 janvier 2012, le CRD, statuant en formation disciplinaire, après avoir constaté que la SPIS a violé les règles de passation des marchés publics et commis des faits présumés de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie aux deniers publics, a prononcé, en application des articles 147d et 148 du code des marchés publics de 2011, l'exclusion de SPIS des marchés publics, des délégations de services publics et des contrats de partenariat pour une durée de 10 ans ; de même que le CRD a ordonné au Directeur Général de l' ARMP de saisir l'autorité judiciaire compétente des infractions présumées de faux, usage de faux et de tentative d'escroquerie aux deniers publics contre SPIS et contre la personne de son dirigeant légal.

**DECISION N° 11/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS REPROCHES A L'ENTREPRISE
SENEGALAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET DE SERVICES (SPIS)
RELATIFS A LA PRODUCTION DE FAUSSES ATTESTATIONS DE BONNE
EXECUTION DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES DE L'AGENCE
D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC (AGETIP) AYANT POUR
OBJET LA CONSTRUCTION DE VOIRIES, D'OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET DES TRAVAUX CONFORTATIFS DE LA GARE
ROUTIERE DE KOTHIARY DANS LA COMMUNE DE TAMBACOUNDA**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 147 et 148 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP);

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de l'AGETIP en date du 07 septembre 2011 ;

Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre référencée TEC/2498/11 du 07 septembre 2011, enregistrée le 13 septembre 2011 sous le numéro 942 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Directeur général de l'AGETIP a saisi le CRD d'une dénonciation relative à la production par l'entreprise SPIS de fausses attestation de bonne exécution de travaux, dans le cadre de l'appel d'offre dont objet rappelé ci-dessus.

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit le CRD en formation disciplinaire ;

Qu'en application de cette disposition, le Président du CRD a régulièrement saisi la Formation disciplinaire des faits dénoncés par l'AGETIP ;

SUR LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » des 11, 12 et 13 juin 2011, l'AGETIP a fait publier un avis d'appel d'offres ayant pour objet des travaux de construction de voiries, d'ouvrages de franchissement et travaux confortatifs de la gare routière de Kothiary dans la commune de Tambacounda, dans le cadre du Programme de Renforcement et d'Equipement des Collectivités Locales (PRECOL).

A l'ouverture des plis du 26 juillet 2011, les entreprises Consortium 19, Henan Chine, CDE, SPIS et Senthra ont présenté des offres pour les montants respectifs de 1 070 597 629 FCFA HT, 1 281 044 322 FCFA HT, 2 029 100 317 FCFA HT, 1 061 659 363 FCFA HT et 1 338 363 825 FCFA HT.

Toutefois, au cours de l'évaluation, après investigation de la commission des marchés de l'AGETIP, il s'est avéré que les attestations de travaux similaires fournies par le candidat SPIS ne sont pas authentiques.

Mis au courant de cette situation, le Directeur Général de l'AGETIP a saisi d'une dénonciation le Président du CRD qui a, à son tour, saisi l'organe de règlement des différends siégeant en commission disciplinaire.

AU FOND

1- Sur les faits reprochés à SPIS

Considérant qu'il est constant comme résultant de son offre que SPIS a produit les attestations de travaux suivants :

- Attestation du 14 janvier 2009 pour des travaux de construction et réparation d'ouvrages dans les régions de Fatick et Kaolack (marché n° TA3/061/ATR pour un montant de F CFA 1 785 548 800 FCFA),
- Attestation du 14 juillet 2009 pour des travaux d'entretien courant de la route en terre Kaffrine-Nganda (Marché n° TA3/060/ATR),
- Attestation du 26 septembre 2010 pour des travaux de routes sur le réseau routier de Malam Hoddar (Marché n° TA1/171/ATR) ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que, sur interpellation de l'AGETIP, Monsieur Lamine NDIAYE, chef d'Antenne de Fatick de l'Agence de Gestion des Routes (AGERROUTE), ex AATR, a apporté la réponse suivante : « cette attestation est absolument fausse et l'auteur de ce document doit être poursuivi et dénoncé aux autorités comme la DCMP et l'ARMP pour servir d'exemple dans l'avenir. En ce qui me concerne, mes autorités seront saisies pour nécessaire. L'Antenne Régionale ne connaît pas et n'a jamais exécuté de contrat avec cette entreprise. Les entêtes sont de Kaolack et les cachets aussi. Il s'agit manifestement de fraudes qu'il faut dénoncer avec toute la rigueur requise et larges diffusions » ;

Considérant que l'instruction a révélé que la société SPIS a produit, en outre, trois (3) autres attestations de bonne exécution du 27 décembre 2007, du 22 avril 2008 et du 12 mai 2011 portant l'entête de Générale d'Entreprise (GE) concernant les travaux de construction de l'immeuble Thiandoum (758 900 000 FCFA TTC), les travaux de construction et de voirie de l'immeuble Abdoulaye DIA (985 155 708 FCFA TTC) et les travaux de construction et d'assainissement de Water Front (Gros œuvres et parking pour un montant de 1 457 819 000 FCFA TTC) ;

Considérant qu'au vu de la lettre de demande de confirmation du Président du CRD, le Directeur Général de Générale d'Entreprises, dans sa correspondance du 05 décembre 2011 référencée MMF/LGE2011 N° 0954/DG, a affirmé que lesdites attestations sont fausses, en faisant les précisions suivantes :

- Pour Waterfront, les travaux d'assainissement sont en cours et sont en train d'être réalisés par GE ;
- Pour l'immeuble Abdoulaye Dia, GE n'a jamais eu à réaliser des travaux de voirie ;
- L'immeuble Thiandoum n'existe pas dans les livres de GE ;

Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société SPIS a violé les règles de passation des marchés publics en fournissant délibérément dans son offre de fausses pièces, fait prévu et puni par les articles 147,d et 148 du Code des Marchés Publics ;

SUR LA SANCTION

Considérant que l'article 148 du Code des Marchés Publics prévoit, au titre des sanctions pouvant être prononcées contre les candidats coupables de violation des règles de passation des marchés publics , la confiscation des garanties constituées par le contrevenant et l'exclusion du droit de concourir pour l'obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ;

Qu'ainsi, la nature et la durée de la sanction encourue dépendent des circonstances propres à chaque affaire ;

Considérant qu'en l'espèce, la production par SPIS de fausses attestations n'est que la manifestation d'une volonté de fraude affirmée ;

Qu'en effet, un soin particulier a été pris aux fins de dissimuler l'auteur de la fraude, eu égard au fait qu'aucune personne physique ne transparaît dans les pièces qui ont été déposées par le candidat ;

Qu'il est au demeurant notable que la soumission et les différentes pièces produites sont signées par Monsieur Oussoumane Diallo présenté comme le Directeur général adjoint, ou par la Direction générale, et que le seul numéro de téléphone mentionné dans l'offre est hors service, toutes choses qui pourraient faire penser que la SPIS est une société fictive ;

Considérant par ailleurs que les agissements de la SPIS sont de nature à porter atteinte aux objectifs de la réforme des marchés publics et aux principes de transparence, d'égalité des candidats et de libre accès à la commande publique ;

Considérant surtout que les pratiques de SPIS risquaient de compromettre la satisfaction des besoins de l'autorité contractante et d'obvier l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ;

Qu'en effet, seule la vigilance de la commission des marchés de l'AGETIP a permis d'écarter l'offre de SPIS moins disante, alors que l'entreprise ne justifie d'aucun savoir-faire.

Qu'en raison de ces circonstances, il y a lieu de prononcer l'exclusion de la SPIS des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans, en application de l'article 148 du Code des Marchés Publics ; en conséquence,

DECIDE

- 1) Reçoit le Président du CRD en sa saisine,
- 2) Constate que dans le cadre de la passation du marché de l'AGETIP ayant pour objet des travaux de construction de voiries, d'ouvrages de franchissement et travaux confortatifs de la gare routière de Kothiary dans la commune de Tambacounda, la société SPIS a produit de fausses attestations de bonne exécution de travaux similaires,

- 3) Dit qu'ainsi, SPIS a violé les règles de passation des marchés publics et commis des faits présumés de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie sur les deniers publics ;
- 4) Prononce, en application de l'article 148 du Code des Marchés Publics, l'exclusion de SPIS des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans ;
- 5) Ordonne au Directeur général de l'ARMP de saisir l'autorité judiciaire compétente des infractions présumées de faux, usage de faux et de tentative d'escroquerie aux deniers publics contre SPIS et contre la personne de son dirigeant légal ;
- 6) Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à la dernière adresse connue de SPIS, ou, à compter de la date de sa publication ;
- 7) Dit que le Directeur Général de l'ARMP est chargé de notifier à la SPIS, à l'AGETIP et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)

Président

Abdoulaye SYLLA

Membre du CRD

Membre du CRD

Membre du CRD

Abd'El Kader NDIAYE

Mamadou DEME

Ndiacé DIOP

Directeur général / Rapporteur

Saër NIANG

C'est ainsi également que la formation disciplinaire du CRD a prononcé les sanctions suivantes contre les personnes morales et physiques ci-après :

1. La société Afrik Travaux, qui a déposé, dans le cadre de l'appel d'offres relatif à des travaux de construction et de réhabilitation de voiries dans la ville de Thiès, des « attestations de bonne exécution de travaux » et des états financiers présumés faux, a été exclue pour une durée de dix (10) ans des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat (décision du CRD n° 58 du 31 mai 2012) ;
2. La dame Awa CISSE DIEME, qui a déposé, dans le cadre de l'appel d'offres visé au 1°), ci-dessus, des attestations et états financiers présumés faux, a été exclue pour une durée de dix (10) ans, également (décision du CRD n° 59 du 31 mai 2012).
3. Le sieur Amadou Habib TALL, Directeur Général de l'Entreprise des Travaux de Bâtiment et de Génie Civil – Consultance (ETBGC Consultant), titulaire du marché ayant pour objet, la réhabilitation du stade de Kounghoul et du marché relatif à la réhabilitation et à l'extension du stade municipal de Gossas, a déposé dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux dits marchés des « cautions de remboursement d'avance » et des « garanties de bonne exécution » présumées fausses.

Par décision n° 188 du 17 juillet 2013, le CRD a prononcé son exclusion pour trois (3) ans des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat ;

4. La société GES et son Directeur Général, Mamadou FAYE, ont produit une « attestation de travaux similaires » présumée fautive dans le cadre de l'appel d'offres du Port Autonome de Dakar (PAD) relatif aux travaux d'entretien courant des installations ferroviaires des zones nord et sud sur l'entreprise portuaire de Dakar.

Par décision n° 231 du 24 novembre 2013, le CRD a exclu la société GES pour une période d'un (1) an, des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal ainsi que dans tout autre Etat membre de l'UEMOA. Et ladite sanction a été étendue à son Directeur Général.

Conscient des graves conséquences du faux, le législateur sénégalais lui a consacré toute une section dans le chapitre du code pénal intitulé « crimes et délits contre la paix publique », pour réprimer le faux sous toutes ses formes, de même que l'usage de faux ; et ces délits font partie des infractions les plus sévèrement réprimées par le juge pénal.

En France, l'article 47 du code des marchés publics stipule que : « après la signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements il est fait application, aux torts du titulaire, des conditions de résiliation prévues par le marché ».

L'inexactitude des renseignements et documents devant être produits dans le cadre d'une procédure de commande publique est sévèrement sanctionnée par la résiliation de plein droit aux torts exclusifs du cocontractant, à condition que le contrat contienne des dispositions relatives à la résiliation (Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2001, M. Bernard Djaoui, n° 0100956 : conséquences de fausses déclarations sur la situation fiscale et pénale du candidat).

Pénalement, le législateur français a consacré le chapitre premier du titre IV (des atteintes à la confiance publique), du livre quatrième du code pénal, aux faux. L'article 441.1 dispose : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois (3) ans d'emprisonnement et de 45 000 (quarante cinq mille) euros d'amende ».

Ainsi, en France aussi, le faux et l'usage de faux sont sévèrement punis.

Pour la jurisprudence, constitue un faux pénalement punissable au sens de l'article 441.1 du code pénal, l'altération frauduleuse de la vérité préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre (crim. 8 juin 1994 ; Bull. crim. N° 228) ; constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions des art. 147, 150 et 151 anciens et 441.1 nouveau du code pénal, la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quelque soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice (crim. 19 déc. 1996 ; Gaz Palais 1997 – 1, chron. Crim. 82).

Relativement au préjudice, la jurisprudence française précise que « le préjudice, élément constitutif de faux, et dont la simple éventualité suffit pour faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi, est le préjudice matériel, moral ou social, qui a été causé (ou qui aurait pu être causé) par l'existence ou l'usage de la pièce fausse ; il ne se confond pas nécessairement avec le préjudice personnel, né et actuel qui, en sus de tout dommage résultant de l'usage d'une pièce fausse, découle directement pour la victime d'une infraction de la perpétration même de cette infraction (crim. 15 janvier 1969 ; Bull. crim. N° 30 ».

DENONCIATION DE LA MAUVAISE EXECUTION DU MARCHE

A la suite de l'appel d'offres lancé le 13 août 2010 par la société DDD relatif à la livraison de quatre cents (400) batteries, le GIE Les Constructeurs a été désigné attributaire provisoire, le marché signé le 12 octobre 2010 et une avance de démarrage de F CFA 7 200 000 (sept millions deux cent mille francs CFA) a été versée audit attributaire en contrepartie d'une caution délivrée parla société Askia Assurances. Le GIE Les Constructeurs n'ayant pas exécuté les prestations objet du marché malgré les multiples relances et la lettre de mise en demeure qui lui a été servie le 8 février 2011, finalement le marché a été résilié le 21 février 2011 et la société Askia Assurances sommée de restituer le montant de l'avance de démarrage.

Devant les difficultés rencontrées par la société DDD pour rentrer dans ses fonds, elle saisit l'ARMP par lettre du 30 novembre 2011 pour dénoncer l'attitude du GIE Les Constructeurs ainsi que le comportement de la société Askia Assurances qui refusait de rembourser le montant cautionné.

Le Président du Conseil de Régulation saisit le CRD du dossier, et grâce à son intervention, la société Askia Assurances s'acquitta de ses obligations en remboursant le montant de l'avance, suivant chèque ICB du 21 décembre 2011.

Par décision n° 13 du 26 janvier 2012, le CRD, statuant en formation disciplinaire, après avoir constaté que la société Askia Assurances s'est acquittée de ses obligations, prononça l'exclusion du GIE Les Constructeurs, pour une période de trois (3) ans, des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal, en application des articles 30 du COA, modifié, 147 et 148 du code des marchés publics et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l' ARMP.

A l'appui de sa décision, le CRD a fait valoir que le délai d'exécution des prestations étant dépassé, au vu des clauses du marché, alors qu'en vertu de l'article 62 du COA, modifié, le GIE Les Constructeurs est tenu d'exécuter ses obligations, leur inexécution a causé un préjudice certain à la société DDD et qu'en l'espèce, il n'y a aucun des faits justificatifs prévus par l'article 89 du COA.

DECISION N° 13/12/ARMP/CRD DU 26 JANVIER 2012
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION
DISCIPLINAIRE, D'UNE PART, SUR LES FAITS D'INEXECUTION DU MARCHE
D'ACQUISITION DE BATTERIES PAR LE GIE LES CONSTRUCTEURS, APRES
ENCAISSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE, D'AUTRE PART, SUR LE
REFUS DE ASKIA ASSURANCES D'HONORER SES ENGAGEMENTS, EN
VIOLATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES MARCHES PUBLICS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION
DISCIPLINAIRE :

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de Dakar Dem Dikk en date du 30 novembre 2011, reçue par le Service du courrier le 1^{er} décembre 2011, puis enregistrée le 02 décembre 2011 sous le numéro 788/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mamadou DEME, Abd'El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF Coordonnateur de la Cellule d'enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ;

Par lettre en date du 30 novembre 2011, reçue par le Service du courrier le 1^{er} décembre 2011, puis enregistrée le 02 décembre 2011, Dakar Dem Dikk (DDD) a saisi le CRD pour protester et demander des sanctions contre, d'une part, les agissements du GIE Les Constructeurs, titulaire du marché portant acquisition de batteries pour la gestion 2010, d'autre part, le refus de la société Askia Assurances de rembourser le montant de l'avance de démarrage perçu suite à son cautionnement .

A l'appui de sa requête, DDD a fait parvenir au CRD :

- Copie du marché de commande portant acquisition de batteries ;
- Copie de la lettre datée du 4 novembre 2010, du GIE Les Constructeurs ayant pour objet une demande d'acompte ;
- Copie de l'attestation datée du 23 novembre 2010 transmettant au Gie Les Constructeurs, le chèque représentant le cautionnement d'avance de démarrage ;
- Copie de la caution d'avance de démarrage délivrée par la société ASKIA Assurances ;
- Copie de la lettre de DDD en date du 08 février 2011 valant mise en demeure adressée au GIE Les Constructeurs ;
- Copie de la lettre en date du 21 février 2011 portant résiliation du marché d'acquisition de batteries.

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit le CRD en formation disciplinaire ;

Qu'en application de cette disposition, le Président du CRD a saisi la Formation disciplinaire des faits d'inexécution des prestations objet du marché, après encaissement d'une avance de démarrage s'élevant à la somme de 7 200 000 F CFA.

SUR LES FAITS :

A la suite de l'avis d'appel d'offres en date du 13 août 2010 du marché susnommé, lancé par la société DDD, le GIE Les Constructeurs a été désigné attributaire provisoire.

Après signature du marché, le 12 octobre 2010, portant sur la livraison de 400 batteries, une avance de démarrage d'un montant de 7 200 000 F CFA a été consentie au GIE Les Constructeurs, en contrepartie d'une caution délivrée par ASKIA Assurances .

Selon DDD, après réception dudit montant, le représentant du GIE Les Constructeurs a refusé de s'exécuter malgré les multiples relances et la lettre de mise en demeure qui lui a été servie

le 08 février 2011, prétextant ses « nombreux déplacements » à l'étranger ainsi que la plainte déposée par ses soins à la Division des Investigations Criminelles (DIC) suite à une escroquerie dont il serait victime et qui l'empêcherait d'honorer ses engagements.

Toutefois, DDD attire l'attention du CRD sur le fait que la plainte dont fait cas le représentant du GIE Les Constructeurs a été déposée le 09 février 2011, donc le lendemain de la notification de la lettre de mise en demeure qui lui a été servie.

Finalement, le marché a été résilié le 21 février 2011 et la société Askia Assurances sommée de restituer le montant de l'avance de démarrage perçue.

Devant les difficultés éprouvées pour rentrer dans ses fonds, DDD a confié le contentieux à son conseil juridique avant de saisir l'ARMP pour dénoncer l'attitude du GIE Les Constructeurs « qui a soumissionné en toute mauvaise foi » ainsi que le comportement déplorable de la société Askia Assurances qui refuse de rembourser le montant cautionné, bien que bénéficiant d'un agrément du Ministère chargé des Finances.

C'est la raison pour laquelle DDD a protesté « énergiquement » auprès du CRD, contre les agissements du GIE Les Constructeurs et Askia Assurances.

Pour prouver sa bonne foi, le requérant soutient qu'il avait envoyé un de ses membres aux Etats Unis d'Amérique pour acheter des batteries, objet du marché ; mais que ce dernier est revenu sans lesdits produits.

Le GIE Les Constructeurs soutient avoir été « arnaqué » par Monsieur Modou GUEYE, représentant en Espagne de l'entreprise Productos Naiq pour un montant de 11 000 Euros, raison pour laquelle une plainte a été déposée à la DIC dans le but de rentrer dans ses fonds.

Toutefois, le GIE Les Constructeurs dit regretter l'inexécution des prestations attendues causée par cette situation inattendue, présente ses excuses pour ce manquement à ses obligations contractuelles et espère que le CRD lui fera bénéficier des circonstances atténuantes.

A l'appui de ses déclarations, le GIE Les Constructeurs a produit les pièces suivantes :

- la lettre en date du 06 janvier 2012 adressée au Directeur général de l'ARMP suite à son audition par le CRD,
- Copie de la plainte du GIE Les Constructeurs en date du 08 février 2011 adressée à la DIC,
- Copie du marché de commande portant acquisition de batteries signé entre le GIE Les Constructeurs et Productos Naiq 2005 S.L,
- Copie d'une facture de 22 000 euros émise au nom de Papa Abdoulaye Ndoeye,
- Copie de la sommation interpellative de Maître Ndeye Tègue FALL LO, adressée au GIE Les Constructeurs valant commandement de payer la somme de 7 200 000 F CFA,

AU FOND :

Considérant qu'il n'a pas été contesté que le GIE Les Constructeurs a signé avec DDD un marché à prix unitaires non révisables et non actualisables pour la fourniture de batteries sur une durée de douze (12) mois et que les prestations prévues au titre dudit contrat n'ont pas été exécutées ;

Considérant qu'en application de la clause 5 dudit marché, le Gie Les Constructeurs a sollicité et obtenu de l'autorité contractante, une avance de démarrage pour un montant de 7 200 000 F CFA contre présentation d'une caution en bonne et due forme délivrée par Askia Assurances ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation du contrat litigieux, l'autorité contractante a fait appel à la caution pour rentrer dans ses fonds, mais elle a été confrontée à des lenteurs, de la part de la caution, pour le remboursement des fonds remis au titre de l'avance de démarrage ;

Considérant toutefois que suite à l'intervention du CRD, la société Askia Assurances a décidé de procéder à la radiation de la procédure contentieuse initiée et de rembourser à DDD les sommes perçues par le GIE Les Constructeurs, au titre de l'avance de démarrage ;

Considérant, par lettre du 29 décembre 2011, qu'Askia Assurances a informé l'ARMP du règlement desdites sommes par chèque ICB n° 0212940 daté du 21 décembre 2011 ;

Que par conséquent, il convient de relever in fine, qu'Askia Assurances s'est acquittée de ses obligations lui incombant au titre de la caution fournie ;

Considérant cependant, qu'il ressort des clauses 4 et 7 du contrat litigieux que les prestations projetées sont prévues pour une durée d'un an à compter du 12 octobre 2010 et que tout retard de livraison entraîne de facto, le paiement de pénalités de retard fixé à 0,5% de la valeur de chaque commande ;

Considérant qu'à cet égard, l'inexécution du marché a causé un préjudice certain à l'autorité contractante du fait de la sensibilité et de la complexité du secteur des transports dans lequel elle évolue et qui nécessite une disponibilité des pièces de rechange pour assurer la continuité ainsi que la bonne marche du service public ;

Considérant que pour prouver sa bonne foi, relativement à l'inexécution du marché, le GIE Les Constructeurs déclare avoir été « arnaqué » par son fournisseur basé en Espagne, ce qui a engendré la situation d'insolvabilité de l'entreprise ;

Considérant toutefois que selon les dispositions de l'article 62 du Code des obligations de l'Administration modifié, le cocontractant de l'autorité contractante est tenu d'exécuter les obligations lui incombant ;

Considérant également qu'hormis le cas de force majeure ou le fait de l'autorité contractante qui peuvent constituer des justificatifs valables en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations du titulaire, l'article 89 du Code des obligations de l'Administration n'a pas retenu une autre clause limitative de l'obligation d'exécution ;

Considérant qu'en l'espèce, le manquement observé ne peut être imputable qu'au titulaire du marché et doit être sanctionné sous la forme d'exclusion temporaire, en référence à l'article 23 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP ;

Qu'en considération de ces faits, notamment de l'inexécution de ses obligations contractuelles, il convient de prononcer l'exclusion pour une période déterminée du GIE Les Constructeurs des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat et ordonner le paiement d'indemnités pour le préjudice subi par l'autorité contractante ;

DECIDE :

- 20) Reçoit le Président en sa saisine ;
- 21) Constate que Askia Assurances a finalement remboursé la somme décaissée au profit du GIE Les Constructeurs au titre de l'avance de démarrage ; à cet égard,
- 22) Dit que Askia Assurances s'est acquittée de ses obligations ;
- 23) Dit que les raisons avancées par le GIE Les Constructeurs pour justifier l'inexécution des prestations dues au titre du contrat ne peuvent pas être retenues comme des circonstances atténuantes, en référence aux dispositions de l'article 89 du Code des obligations de l'Administration modifié,
- 24) Constate que le défaut d'exécution du marché par le GIE Les Constructeurs a causé un préjudice à l'autorité contractante ; par conséquent,
- 25) Par application des dispositions des articles 30 du Code des obligations de l'administration modifié, 147 et 148 du Code des marchés publics et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, exclut le GIE Les Constructeurs des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal pour une période de trois (3) ans à compter de la date de notification de la présente décision ;
- 26) Dit que la présente décision est étendue au responsable du Gie Les Constructeurs ;
- 27) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au Gie Les Constructeurs, à Dakar Dem Dikk et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD)**Président****Abdoulaye SYLLA****Membre du CRD****Membre du CRD****Abd'El Kader NDIAYE****Mamadou DEME****Membre du CRD****Ndiacé DIOP****Directeur Général / Rapporteur****Saër NIANG**

En 2008, la Société Africaine de Raffinage (SAR) a importé une cargaison de pétrole brut auprès de la société nigériane Arcadia Petroleum Limited (APL), sans appel d'offres, en méconnaissance des articles 1 et 2 du code des marchés publics, alors que son capital est majoritairement détenu par l'Etat du Sénégal à hauteur de 65,40%.

La cargaison en question, comportant 901.610 barils, totalisant 122 222 tonnes avait été expédiée à partir du Nigéria, à bord du Navire-Tanker dénommé M/T Olinda et a été entièrement payée. Les purges et jaugeages des bacs permirent de déceler la présence massive d'eau d'un volume de 5 494,13 m³ dans le pétrole brut, représentant pour la SAR un préjudice financier de F CFA 9 796 769 077 (Neuf milliards sept cent quatre vingt seize millions sept cent soixante neuf mille soixante dix sept francs CFA).

Les derniers jaugeages effectués à bord, préalablement au déchargement du navire le 10 décembre 2008, ayant déjà révélé un volume de 1 542,76 m³ d'eau dans le pétrole brut, dès le 15 décembre 2008 une lettre de protestation signée conjointement par la Société Générale de Surveillance (SGS), la SAR et le commandant du navire, a été envoyée au fournisseur.

De même qu'après le déchargement, un second contrôle effectué le 16 décembre 2008 dans les bacs de la SAR par ses services techniques, la SGS et la douane ayant révélé un volume d'eau de 2 419,21 m³, le fournisseur a été saisi de nouveau par une lettre datée du 19 décembre 2008, soit 34 jours après la date de connaissance effectué le 15 novembre 2008.

Faisant preuve d'une mauvaise foi manifeste, la société APL, par courrier du 14 décembre 2009, opposa une fin de non-recevoir à la SAR, prétextant de la forclusion de la réclamation qui lui serait parvenue tardivement, soit 101 jours après la date du connaissance alors que le délai fixé dans le contrat est de 43 jours.

Suite au rapport de l'Inspection Générale d'Etat relatif à cette situation, par lettre du 11 novembre 2013, la Primature a saisi le CRD d'une demande de sanction contre la société APL.

Par décision n° 392 du 26 décembre 2013, le CRD, statuant en formation disciplinaire, a prononcé l'exclusion de la société nigériane « Arcadia Petroleum Limited » des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal, pour une période de dix (10) ans, à compter de la notification de la décision, par application des articles 30 du COA, modifié, 147 et 148 du code des marchés publics et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l' ARMP.

A l'appui de sa décision, le CRD a estimé que la société APL ayant livré à la SAR une quantité d'eau importante à la place du pétrole brut, lui a causé un préjudice financier de F CFA 9 796 769 077 (Neuf milliards sept cent quatre vingt seize millions sept cent soixante neuf mille soixante dix sept francs CFA), violant ainsi les dispositions de l'article 62 du COA, modifié, alors qu'en l'espèce il n'y a aucun des faits justificatifs prévus par l'article 89 du COA.

DECISION N° 392/13/ARMP/CRD DU 26 DECEMBRE 2013
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION
DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS RELATIFS A LA LIVRAISON D'UNE
CARGAISON DE PETROLE BRUT CONTENANT UNE QUANTITE MASSIVE
D'EAU PAR LA SOCIETE ARCADIA PETROLEUM LIMITED AU PROFIT DE LA
SOCIETE AFRICAINE DE RAFFINAGE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION
DISCIPLINAIRE :

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre de Madame le Premier Ministre en date du 11 novembre 2013, reçue le même jour au service courrier de l'ARMP ;

Madame Khadijetou DIA LY, chargée des enquêtes entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Mr. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, Rapporteur du CRD ;
de Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé des enquêtes à la Cellule d'enquêtes et Inspection, Moussa Diagne, chef division formation à la Direction de la Formation et des Appuis Techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la demande, les faits et moyens exposés ;

Par lettre en date du 11 novembre 2013, reçue le même jour au service courrier, de l'ARMP, la Primature a saisi le CRD pour demander des sanctions contre la société nigériane Arcadia Petroleum Limited (A.P.L) qui, en 2008, a procédé à la livraison d'une cargaison de pétrole brut contenant une quantité massive d'eau pour le compte de la Société Africaine de Raffinage SAR.

A l'appui de sa requête, la Primature a fait parvenir au CRD, par courrier du 23 décembre 2013, le rapport N° 116/2012 de l'Inspection Générale d'Etat portant sur l'enquête relative aux conditions d'importation par la Société africaine de Raffinage « SAR », d'une cargaison de pétrole brut livrée en décembre 2008 par la société Arcadia Petroleum Limited « APL ».

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit le CRD en formation disciplinaire ;

Qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, le Président du CRD a saisi le Comité à l'effet de statuer, en formation disciplinaire, sur le dossier relatif à la faute commise par la société Arcadia Petroleum Limited, qui a livré à la SAR, du pétrole brut dont une quantité importante était constituée d'eau ;

Qu'en conséquence, le CRD se déclare compétent sur la saisine du Président.

SUR LES FAITS :

En 2008, la Société Africaine de Raffinage « SAR » a importé une cargaison de pétrole brut auprès du fournisseur « Arcadia Pétroleum Limited » sans appel d'offres, en méconnaissance des articles 1 et 2 du Code des Marchés Publics alors que son capital était majoritairement détenu par l'Etat du Sénégal à hauteur de 65,40 %.

La cargaison de pétrole brut en cause comportait neuf cent un mille six cent dix (901 610) barils, totalisant cent vingt deux mille deux cent vingt deux (122 222) tonnes et avait été expédiée à partir du Nigéria, à bord du navire-tanker dénommé M/T OLINDA.

Cette cargaison présentait la particularité de contenir une quantité massive d'eau mélangée au pétrole brut qui a été décelée à l'arrivée du tanker à DAKAR.

Un volume total d'eau de 5494,12 m³ a été drainé des bacs de la SAR, alors que l'intégralité de la cargaison valorisée en pétrole brut a été entièrement réglée en mars 2009, au fournisseur APL qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles en termes de quantité du produit livré.

C'est pourquoi, suite à la recommandation N° 7 issue du rapport N° 116/2012 de l'Inspection Générale d'Etat, la Primature a saisi le CRD pour demander l'exclusion des marchés publics de la société « ARCADIA PETROLEUM LIMITED », qui aurait de manière délibérée, vendu à la SAR, de l'eau à la place du pétrole brut, causant ainsi à cette société, un important préjudice financier estimé à 9 796 769 077 F CFA.

AU FOND :

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier qu'en 2008, la SAR, alors société anonyme à participation publique majoritaire, a importé du pétrole brut, livré en décembre de la même année par la société Arcadia Petroleum Limited ;

Que les résultats des premiers jaugeages effectués à bord, préalablement au déchargement du navire le 10 décembre 2008, ont permis de déceler un volume de mille cinq cent quarante deux virgule soixante- seize (1542,76) m³ d'eau dans le pétrole brut ;

Que ce constat a été formalisé dans une lettre de réclamation appelée «letter of protest» en date du 15 décembre 2008 conjointement établie et signée par les services de contrôle indépendants de la Société Générale de Surveillance (SGS) mandatés par la SAR, par le commandant du navire affrété par le fournisseur et par les services techniques de la SAR ;

Considérant qu'après le déchargement, entamé le 10 décembre et achevé le 15 décembre 2008, un nouveau contrôle des quantités d'eau a été effectué le 16 décembre 2008 dans les bacs de la raffinerie ;

Que ce nouveau contrôle a permis aux services techniques de la SAR, de la SGS et de la douane de détecter la présence de quantités insoupçonnées d'eau non décelées à l'arrivée du navire, soit environ deux mille quatre cent dix neuf virgule vingt et un (2419, 21) m³ d'eau. ;

Qu'à ce propos, la direction commerciale de la « SAR », avait à l'époque, saisi le fournisseur « APL » par courrier électronique du 19 décembre 2008, soit 34 jours après la date du connaissance effectué le 15 novembre 2008, pour signaler d'une part l'anomalie constatée dans le produit livré et l'informer d'autre part de la lettre de réclamation établie à ce sujet depuis le 15 décembre 2008 et envoyée par la SGS pour les besoins d'un dédommagement ;

Considérant que le fournisseur, en dépit des nombreuses relances de la direction commerciale de la SAR, est resté sourd aux réclamations susmentionnées et n'a jamais daigné répondre aux interpellations des dirigeants de cette structure ;

Qu'en définitive, le fournisseur APL a fini par opposer, par courrier électronique du 14 décembre 2009, une fin de non- recevoir aux interpellations de la direction commerciale de la SAR, en prétextant la forclusion de la réclamation qui leur serait parvenu tardivement, soit 101 jours après la date du connaissance en lieu et place des 43 jours fixés dans le contrat ;

Que, paradoxalement, dans le même courrier du 14 décembre 2009, le fournisseur mentionne que ***« dès qu'il a pu disposer, grâce à la SGS, des chiffres relatifs au déchargement de la cargaison à Dakar, il a saisi son propre fournisseur dans le délai acceptable des 45 jours qui ont suivi la date d'établissement du connaissance pour suite à donner »*** ;

Qu'à ce niveau, transparaît la mauvaise foi manifeste du fournisseur APL qui reconnaît ainsi implicitement avoir été informé, de la présence d'eau dans la cargaison OLINDA, avant la fin du délai de forclusion de 43 jours et non de 45 jours après la date du connaissance, fixé par le contrat pour faire des réclamations ;

Que de surcroît, la preuve existe qu'un courrier électronique daté du 19 décembre 2008, soit 34 jours après la date du connaissance, avait été envoyé audit fournisseur par la Directrice commerciale de la SAR, l'informant des graves anomalies constatées ;

Qu'à cet égard, le fournisseur APL doit être rendu responsable de cette situation qui dénote d'une faute grave dans l'exécution du contrat, d'autant plus que les purges quotidiennes des bacs de stockage du pétrole brut, effectuées à MBAO, de janvier à mars 2009, par les services techniques de la SAR, ont permis d'extraire une quantité totale de cinq mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule douze (5 494,12) m³ d'eau ;

Qu'en dépit de cette situation, la totalité de la cargaison valorisée en pétrole brut a été réglée intégralement au fournisseur dès le 12 mars 2009 ;

Qu'ainsi la SAR a acheté de l'eau au prix du pétrole brut pour un montant de 1 164 306 948 F CFA ;

Qu'à cette perte budgétaire, s'ajoutent diverses pertes notamment celles commerciales estimées à 5 443 224 974 F CFA, dues au retard dans la fabrication des produits raffinés et à l'évolution moins favorable de leurs prix de vente ;

Considérant qu'à cet égard, le fournisseur APL, qui n' a pas jugé bon de répondre aux interpellations de la direction commerciale de la SAR relativement à la lettre de réclamation portant sur la quantité excessive d'eau livrée à la place du pétrole brut, a causé un préjudice certain à l'autorité contractante du fait de la sensibilité du secteur de l'énergie, de sa complexité et de son impact direct dans la vie des populations et dans l'économie du pays de manière générale ;

Que sur la base des pièces fournies, le préjudice financier subi par la SAR est estimé à près de 9 796 769 077 F CFA ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 62 du Code des Obligations de l'Administration modifié, le cocontractant de l'autorité contractante est tenu d'exécuter les obligations qui lui incombent ;

Qu'hormis le cas de force majeure ou le fait de l'autorité contractante qui peuvent constituer des justificatifs valables en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations du titulaire, l'article 89 du Code des Obligations de l'Administration n'a pas retenu une autre clause limitative de l'obligation d'exécution ;

Considérant que le fournisseur, pour échapper à ses obligations, a invoqué à tort la forclusion des délais de réclamation, alors qu'il a été informé à temps;

Considérant qu'en l'espèce, le manquement observé ne peut être imputable qu'au titulaire du marché et doit être sanctionné sous la forme d'exclusion temporaire, en référence à l'article 23 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP ;

Qu'en considération de ces faits, notamment de la faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il convient de prononcer, sans préjudice de poursuites pénales et d'action en réparation du préjudice subi par la « Société Africaine de Raffinage », l'exclusion pour une période déterminée de la société nigériane « Arcadia Petroleum Limited » des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ;

DECIDE :

- 28) Reçoit la Primature en sa saisine ;
- 29) Constate que la cargaison MT OLINDA contenait une quantité anormale d'eau mélangée au pétrole brut ;
- 30) Constate que le fournisseur avait été informé à temps, d'une part, à travers une lettre de réclamation dûment signée par le commandant du navire qu'il a affrété et envoyée par la Société Générale de Surveillance et, d'autre part, par de multiples courriers envoyés par la direction commerciale de la SAR dans les délais impartis pour les réclamations ; à cet égard,
- 31) Dit que le fournisseur a commis une faute grave dans l'exécution du contrat en livrant du pétrole contenant une quantité excessive d'eau, causant ainsi un préjudice financier estimé à 9 796 769 077 F CFA ;
- 32) Dit que le fournisseur ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de la SAR ;
- 33) Exclut, par conséquent, la société nigériane « Arcadia Petroleum Limited » des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat lancés au Sénégal pour une période de dix (10) ans à compter de la date de notification de la présente décision, par application des dispositions des articles 30 du Code des Obligations de l'Administration modifié, 147 et 148 du Code des Marchés Publics et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP ;
- 34) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Arcadia Petroleum Limited, à la Société africaine de Raffinage, à la Primature et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP

Boubacar MAR

**Le Directeur Général
Rapporteur**

Saër NIANG

XXIII. PRESENCE DU CONTROLEUR FINANCIER DANS LES COMMISSIONS DE MARCHE NON CONTRAIRE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES FONCTIONS DE REGULATION ET DE CONTROLE

Se fondant sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 37 du code des marchés publics, le contrôleur financier a communiqué à l'Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR) le nom de son représentant et celui de son suppléant à la commission des marchés publics de ladite agence. Le Directeur Général de l'AATR estima que cette agence n'est pas concernée par les dispositions invoquées par le contrôle financier, mais plutôt par les dispositions de l'article 36 du code en vertu desquelles la composition des commissions des marchés est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. L'AATR justifia sa position par le fait qu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale et qu'elle est maître d'ouvrage délégué. Par lettre du 18 juin 2008, le contrôleur financier saisit le président du CRD du litige l'opposant à l'AATR.

S'estimant compétent sur la base de l'article 22 du décret n° 2007-546 relatif à l'ARMP, le CRD par décision n° 14 du 27 juin 2008, déclara que le Contrôleur Financier ne peut pas siéger dans la commission des marchés de l'AATR.

A l'appui de sa décision, le CRD fit valoir que la disposition du paragraphe 3 de l'article 37 du code des marchés publics faisant du contrôleur financier un membre à part entière de la commission des marchés, étant contraire au principe de séparation de l'autorité contractante et des organes de contrôle, consacré par les directives de l'UEMOA numéros 04 et 05 de 2005, il y a lieu d'écarter les dispositions du code des marchés publics, en vertu des articles 98 de la constitution, 6 et 43 du Traité de l'UEMOA.

Par requêtes du 05 août 2008, l'Etat du Sénégal, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, d'une part sollicita l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du CRD n° 14 du 27 juin 2008 et d'autre part demanda son sursis à l'exécution.

La Cour Suprême, par arrêt n° 10 du 25 septembre 2008 et n° 12 du 15 mai 2009, respectivement, ordonna le sursis à l'exécution de la décision querellée et ensuite l'annula aux motifs que :

« En vertu du principe de la primauté du droit communautaire sur la législation nationale, le Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics peut écarter les dispositions du décret portant code des marchés publics contraires aux directives de l'UEMOA.

Toutefois, les articles 36 et 37 combinés dudit code faisant du représentant du contrôle financier un membre de la commission des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, établissements publics, agences et autres organismes dotés de la personnalité morale, ne sont pas contraires au principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle des marchés publics, édicté par les articles 3 et 4 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA dès lors que l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), autorité administrative indépendante ayant une autonomie financière est distincte de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) qui est rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances et chargée du contrôle à priori de la passation des marchés,

sans préjudice, au demeurant, des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses (article 137 du décret portant code des marchés publics).

Par ailleurs, il ressort de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique que le contrôle financier a une mission d'information permanente du Président de la République sur la gestion budgétaire et financière de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Ainsi, le contrôle financier n'étant ni assimilable à la DCMP, ni à l'autorité contractante telle que définie par la directive communautaire, son représentant à la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ne saurait être pris comme un des observateurs prévus par l'article 14 de la directive, mais plutôt comme membre ayant voix consultative, conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 combinés du code des marchés publics.

Par conséquent, encourt l'annulation la décision du comité de règlement de différends de l'Autorité de Régulation des marchés Publics qui a écarté l'application de l'article 37§ 3 du code des marchés publics au motif qu'il serait contraire aux dispositions de la directive suscitée ».

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Société Générale de Surveillance SA (SGS) en date du 7 décembre 2009, enregistré le même jour sous le numéro 782/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Mansour DIOP, Président, de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Birahime SECK et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Youssouf SAKHO, Directeur Général de l'ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Omar SARR Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire en date du 7 décembre 2009, enregistrée le même jour sous le numéro 782/09 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la SGS a sollicité l'annulation de la décision d'attribution du marché portant sur la sélection d'un gestionnaire de l'activité de contrôle technique des véhicules et des ouvrages, lancé par le CETUD.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'au terme des articles 86 et 87 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, tout candidat à une procédure de passation d'un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d'un recours gracieux, soit le CRD ;

Considérant que la SGS a saisi le CETUD par courrier en date du 2 décembre 2009 pour demander les motifs du rejet de son offre dès qu'elle a reçu la notification des résultats de l'appel d'offres par télécopie datée du 30 novembre 2009;

Non satisfait de la réponse de l'Autorité contractante, le requérant a introduit le 7 décembre 2009 auprès du Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), un recours enregistré le même jour sous le numéro 782/09, en contestation de ladite décision d'attribution ;

Que ledit recours étant exercé dans les délais requis, il doit être déclaré recevable.

LES FAITS

A la suite de l'avis d'appel d'offres avec pré qualification publié dans le journal « Le Soleil » les 11 et 15 mai 2009 et portant sur la sélection d'un gestionnaire de l'activité de contrôle technique des véhicules et des ouvrages, le CETUD a transmis une lettre d'invitation à trois (3) candidats qui ont été déclarés qualifiés à l'issue de cette phase ;

Au terme de l'évaluation des offres, le CETUD a attribué le marché au Bureau Véritas, puis a notifié aux autres candidats le rejet de leurs offres par lettre datée du 30 novembre 2009 ;

Dès réception de la notification de l'attribution du marché, la SGS a introduit un courrier demandant les motifs du rejet de son offre, puis a saisi le Comité de Règlement des Différends.

Par décision n° 107/09/ARMP/CRD du 8 décembre 2009, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché susvisé.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa requête, la SGS soutient qu'en application de la formule de notation prévue à l'article 7 des Conditions de l'appel d'offres, la Commission des marchés devait lui octroyer la meilleure note combinée puisque la redevance annuelle à verser à l'Etat qu'elle a proposée est plus élevée de 25,7 % que celle de l'attributaire provisoire du marché ;

Le requérant déclare qu'en raison de son expérience et compte tenu des tarifs pratiqués dans la sous-région et qui sont manifestement supérieurs au tarif d'inspection de six mille cinq cents (6 500) francs fourni à titre indicatif dans le Dossier d'appel d'offres (DAO), aucun candidat ne peut proposer un compte d'exploitation atteignant la rentabilité, à moins de délivrer un service de qualité moindre, avoir un personnel en sous effectif, rémunérer les agents en deçà des normes admises par la réglementation, ou avoir un service de maintenance non performant ;

De ce fait, la SGS considère qu'elle est fondée à proposer une offre qui prend en considération le type d'inspection à effectuer sur les véhicules lourds ou légers, en combinant l'impératif de rentabilité des services fournis par elle et le souci de maximiser les recettes de l'Etat ;

Par ailleurs, la SGS affirme que le CETUD a violé le principe de transparence en recevant une délégation de l'attributaire pendant la période d'évaluation des offres.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

Le CETUD déclare que pour préparer leurs offres conformément aux critères d'évaluation indiqués à la clause 7 des Conditions de l'appel d'offres, les candidats doivent se référer au tarif d'inspection de six mille cinq cents (6 500) francs qui a été fixé par le Ministre chargé des Transports sur proposition du Comité Tarifaire, et établir sur cette base leur compte d'exploitation prévisionnelle ;

Au lieu de se conformer à la clause 7 des Conditions de l'appel d'offres, la SGS a proposé une redevance supérieure au tarif de référence ; c'est pourquoi son offre a été réajustée par la Commission des marchés sur la base du montant de six mille cinq cents (6500) francs fixé dans le Dossier d'appel d'offres ;

A l'issue de l'évaluation des offres, le Bureau Veritas a obtenu la meilleure note pour avoir proposé un pourcentage de redevance de 17,1 % de son chiffre d'affaires contre 15 % offert par la SGS après ajustement de son offre ;

En outre, le CETUD soutient que la SGS a obtenu, sur le critère relatif à la crédibilité du compte d'exploitation prévisionnelle, une note inférieure à celle du Bureau Veritas du fait de la non prise en compte du tarif de référence de six mille cinq cents (6 500) francs, et de l'absence de certaines rubriques du compte d'exploitation prévisionnelle telle que l'assurance, l'audit, la redevance de régulation et d'investissement, entres autres ;

In fine, le CETUD déclare qu'il n'a reçu aucune délégation d'un candidat durant les délibérations de la Commission des marchés et n'a organisé avant le lancement de l'appel d'offres, aucune visite chez un candidat ;

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :

- 1) l'évaluation et les modalités de redressement de l'offre financière de la SGS,
- 2) le fondement des sous critères d'évaluation non portés à la connaissance des candidats.

AU FOND

- 1) Sur l'évaluation et les modalités de redressement de l'offre financière de la SGS :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 80.3 du décret n° 2007- 545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, que les conventions de délégations de service public et les contrats de partenariat sont passés par appel d'offres ouvert avec pré qualification ou en deux étapes, en fonction de la complexité du projet, conformément aux dispositions réglementaires prévues ;

Qu'en application de cette disposition, et conformément à la clause 7 des Conditions générales de l'appel d'offres susvisé, les candidats sont évalués sur la base d'une proposition technique et financière ; qu'à ce titre, la note globale attribuée à chaque candidat est fonction de la crédibilité du compte d'exploitation prévisionnelle sur trois ans, et de la consistance de la redevance proposée, selon la formule suivante :

$$N_i = (R_i/R_M) \times 50$$

N_i : représentant la note du soumissionnaire,

R_i : la redevance proposée par le candidat, et

R_M : la redevance maximale proposée ;

Considérant qu'au terme de l'article 8 des Conditions générales de l'appel d'offres, le marché est attribué au soumissionnaire ayant respecté toutes les conditions de l'appel d'offres et qui aura obtenu la meilleure note sur cent (100) points ;

Qu'il ressort également de l'annexe 1 du DAO relative aux Informations sur le site du centre de contrôle et sur les conditions d'exploitation, que les candidats devront proposer des hypothèses réalistes sur « la base d'un tarif de départ de six mille cinq cents (6 500) francs d'une capacité de 109 440 contrôles par an et d'une redevance d'investissement de soixante millions (60 000 000) de francs par an » ;

Considérant que la SGS a proposé de sa propre initiative, une redevance supérieure de 25,7% à celle offerte par le Bureau Veritas, mais calculée sur la base de neuf mille cinq cents (9 500) francs en lieu et place du tarif de référence de six mille cinq cents (6 500) francs fixé à la clause 7 des Conditions de l'appel d'offres ;

Qu'en évaluant les propositions, la Commission des marchés a réajusté l'offre du requérant ramenant ainsi à 15 % le taux proposé par la SGS pour la redevance au motif que la base de travail ayant conduit à l'établissement de son offre n'est pas conforme aux dispositions de la clause 7 in fine des Conditions générales de l'appel d'offres fixant le tarif d'inspection à six mille cinq cents (6500) francs ;

Qu'en procédant de la sorte, la Commission des marchés a valablement considéré que l'offre de SGS a été faite sans tenir compte du tarif de base auquel tous les candidats devraient se référer pour l'établissement de leurs propositions financières ;

Considérant également que la procédure d'évaluation doit être fondée sur l'adoption de critères et de base de comparaison identiques ;

Qu'à cet égard, la présence d'un canevas de compte d'exploitation dans le DAO aurait pu permettre à la Commission des marchés d'apprécier et de comparer objectivement la pertinence des informations fournies.

2) SUR LE FONDEMENT DES SOUS CRITERES D'EVALUATION NON PORTES A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS:

Considérant qu'il ressort des dispositions de la clause 7 des Conditions générales du DAO que les critères d'évaluation portant sur la crédibilité du compte d'exploitation prévisionnelle notée sur 50 points et sur la consistance de la redevance de fonctionnement proposée évaluée également sur 50 points sont insuffisamment détaillés pour permettre aux candidats de préparer leurs offres en toute connaissance de cause ;

Considérant que lesdits critères doivent, pour être valables, réunir nécessairement les conditions suivantes :

- être liés à l'objet du marché ;
- être précis de façon à éviter à la Commission des marchés d'avoir un pouvoir discrétionnaire sans limites ;
- avoir été portés à la connaissance des candidats ;
- respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité des candidats et de non discrimination ;

Considérant qu'en cours d'évaluation des offres, le CETUD a introduit au niveau du critère relatif à la crédibilité du compte d'exploitation, les sous critères suivants :

1. le respect des hypothèses du DAO dans le calcul du chiffre d'affaires, noté sur 10 points,
2. l'exhaustivité du compte d'exploitation prévisionnelle, sur 20 points et
3. la cohérence des éléments du compte d'exploitation sur 20 points ;

Qu'en procédant ainsi, le CETUD a mis en application des sous-critères de notation qui n'ont pas été portés préalablement à la connaissance des candidats, en violation du principe de transparence, en référence à l'article 59 du Code des Marchés publics;

Qu'à cet égard, le non respect du principe de transparence des procédures et des formalités de publicité prescrites pour les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation du marché susvisé, en référence aux dispositions de l'article 24 du Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

DECIDE :

- 46) Déclare recevable la requête introduite par la SGS ;
- 47) Constate que la Commission des marchés a valablement réajusté l'offre de la SGS sur la base du tarif d'inspection de six mille cinq cents (6 500) francs fixé dans le DAO ;
- 48) Constate que le CETUD n'a pas fourni aux candidats un canevas permettant l'étude comparative de leur compte d'exploitation sur une base équivalente ; en conséquence,
- 49) Relève le manque d'éléments pour apprécier et comparer la crédibilité du compte d'exploitation de chaque candidat ;
- 50) Dit que les sous-critères d'évaluation n'ont pas été portés au préalable à la connaissance des candidats en référence aux dispositions de l'article 59 du Code des Marchés publics ; par conséquent,
- 51) Ordonne la relance de la procédure après redressement du DAO ;
- 52) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la SGS, au CETUD ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

**Le Président
Mansour DIOP**

Suite à cette décision du CRD, le Bureau Véritas a introduit un recours en annulation auprès de la Cour Suprême, qui l'a rejeté, adoptant ainsi la même conception que le CRD.

En France et en Europe, les décisions vont dans le même sens.

VII. OBLIGATION DE NE PAS INSERER DANS LES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES DES CLAUSES CONTRAIRES A LA LOI

Suite à l'avis d'appel d'offres lancé par la société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et ayant pour objet la fourniture de véhicules à ladite société, les offres de Sarre-Cons et de la CFAO ont été enregistrées. Après évaluation desdites offres le marché a été attribué provisoirement à Sarre-Cons. La CFAO ayant saisi le CRD en contestation de cette attribution, ce dernier a rendu le 19 septembre 2012 la décision n° 106 ordonnant la suspension de la procédure du marché.

Par décision n° 118 du 3 octobre 2012, le CRD annula l'attribution provisoire faite au profit de Sarre-Cons et ordonna la reprise de l'évaluation en reprochant, entre autres, à la commission des marchés de PETROSEN, d'avoir méconnu la clause du dossier d'appel d'offres (DAO) exigeant la production de l'autorisation du fabricant.

DECISION N°118/12/ARMP/CRD DU 03 OCTOBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CFAO MOTORS SENEGAL CONCERNANT L'APPEL D'OFFRES N° P001/2012 DE LA SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL (PETROSEN) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURES DE VEHICULES A LADITE SOCIETE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CFAO MOTORS SENEGAL (CFAO) en date du 12 septembre 2012 enregistré le 14 septembre au bureau du courrier et le 17 septembre au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 2673 et 822;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d'enquête sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, et Ely Manel FALL, chef de la Division Règlementation, observateurs;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre en date du 12 septembre 2012, CFAO a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant l'appel d'offres de PETROSEN ayant pour objet la fourniture de véhicules.

SUR LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 13 juillet 2012, PETROSEN a fait publier un avis d'appel d'offres ayant pour objet la fourniture, en un lot unique de deux (02) véhicules 4X4 stations wagon avec une cylindrée comprise entre 2800 et 3100 minimum, deux (02) véhicules 4X4 stations wagon avec une cylindrée comprise entre 4400 cc et 4900 cc minimum, un (01) véhicule Berline utilitaire minimum 2200 cc.

A l'ouverture des plis, le 13 août 2012, les offres de SARRE CONS et CFAO ont été enregistrées, pour le montant respectif de 147 500 000 CFA HTHD et 163 900 000 FCFA HTHD.

Après évaluation desdites offres et suivant procès-verbal du 17 août 2012, le marché a été attribué provisoirement à SARRE CONS pour le montant de 174 050 000 FCFA TTC.

Au vu de la publication de l'attribution provisoire, dans le journal « Le Soleil » du 12 septembre, CFAO a, par lettre datée du même jour, saisi le CRD en contestation de ladite attribution.

Par décision n° 106 du 19 septembre 2012, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

Après avoir rappelé les critères de qualification arrêtés dans le dossier d'appel d'offres, CFAO a relevé que, lors de l'ouverture des offres, il est apparu que SARRE CONS a proposé des véhicules de marque TOYOTA dont elle est le représentant. A ce titre, l'attributaire provisoire ne peut disposer de l'autorisation du fabricant au même titre qu'elle.

En outre, CFAO fait observer que, du fait de son objet social relatif aux BTP, SARRE CONS ne dispose pas d'un service après-vente.

Au regard de ces motifs, elle demande l'annulation de l'attribution provisoire du marché.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs de CFAO, PETROSEN fait observer que SARRE CONS a justifié avoir réalisé des marchés similaires et que, s'agissant du Service Après Vente, il a produit une convention avec une entreprise spécialisée capable d'entretenir, de réparer et de fournir dans un délai d'un (1) à sept (7) jours les pièces de rechange d'origine.

Sur le grief portant sur l'objet social, elle fait valoir que dans les statuts de l'entreprise, il est mentionné « ... négoce, import-export,... toutes activités commerciales », d'où il résulte que SARRE CONS était en droit de soumissionner.

Concernant l'autorisation du fabricant, se fondant sur l'Avis n° 017/10/ARMP/CRD du 11 août 2010, PETROSEN excipe de la nécessité d'assurer le jeu de la concurrence et conclut qu'à ce titre, CFAO ne peut tenter d'entraver le libre accès au marché.

Par ailleurs, l'autorité contractante fait observer qu'il y a un écart de 19 352 000 FCFA entre les deux offres.

Enfin, PETROSEN argue que la commission d'évaluation a constaté que CFAO n'a pas joint à son dossier l'intégralité des trois derniers états financiers requis (2008, 2009 et 2010) et n'a communiqué que ses chiffres d'affaires de 2010 et 2012.

SUR L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte, d'une part, sur la qualification du candidat SARRE CONS et sur la conformité de son offre et, d'autre part, sur la non production par CFAO de tous ses états financiers.

L'EXAMEN DU LITIGE

Sur la qualification de SARRE CONS

Considérant qu'il est stipulé au point 5.1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO), au titre de la capacité technique que le candidat doit prouver, documentation à l'appui, qu'il satisfait aux exigences d'expérience ci-après :

- Avoir réalisé un marché de même nature et de complexité similaire (fourniture de véhicules), durant les trois (3) dernières années pour un montant cumulé égal au moins à deux (2) fois le montant de l'offre ;
- Disposer au Sénégal d'un service après-vente constitué de :
 - Un magasin de stockage et de pièces de rechange ;
 - Un atelier de réparation et d'entretien performant avec un personnel expérimenté ;
 - Un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage ;

Considérant qu'au titre de son expérience spécifique SARRE CONS a produit des documents dont les principaux sont les suivants :

- Contrat du 30/04/07 signé avec la DDI pour un montant de 16 467 000 FCFA ;
- Marché n° 2010 10/039/DGDD/SN de 62 200 000 FCFA HT-HD souscrit le 08 avril 2010 avec l'ASECNA ;
- Contrat de 50 000 000 FCFA signé avec l'ANSD le 26 avril 2007 ;
- Contrat du 07/06/07 de 66 000 000 FCFA HTHD avec le Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Une convention de crédit bail signé, le 20 octobre 2011 entre LOCAFRIQUE et la LONASE pour un montant de 158 839 998 FCFA, désignant SARRE CONS comme fournisseur des véhicules objet de la convention ;

Considérant qu'il résulte de la rédaction du critère que l'expérience pertinente consiste à avoir réalisé un marché dont le montant minimum doit être le double de l'offre du candidat ;

Qu' à cet égard, l'offre de SARRE CONS étant de 147 500 000 HTHD et de 174 050 000 FCFA TTC, il doit faire la preuve de l'exécution d'un marché d'un montant de 295 000 000 FCFA HTHD et 348 100 000 FCFA TTC ;

Que, toutefois, l'examen des pièces qu'il a produites, permet de constater qu'il n'a pas exécuté un marché d'un égal montant ;

Qu'il y a lieu de constater qu'il n'a pas rempli le critère relatif à l'expérience spécifique;

Considérant que, concernant le SAV, SARRE CONS a produit une convention du 2 mars 2009 signée avec AUTOMAX qui stipule que les véhicules neufs commercialisés par lui peuvent être entretenus par ce dernier et que SARRE CONS s'engage à fournir des pièces de rechange d'origine TOYOTA via DEMIMPEX dans un délai d'un à sept jours par DHL;

Qu'il résulte de ces stipulations que SARRE CONS ne dispose pas au Sénégal de magasin de stockage et de pièces de rechange, précision faite qu'AUTOMAX ne procède qu'à la réparation des véhicules sur la base des pièces qui lui sont fournies sous la responsabilité de son cocontractant;

Que dans le même ordre d'idée, SARRE CONS se contente de produire deux attestations signées par son directeur Adjoint affirmant, sans aucun document à l'appui, d'une part, que son garage dispose d'ateliers performants, d'un personnel qualifié de 12 mécaniciens et un cadre supérieur, de lots de pièces de rechange et de deux (2) ponts élévateurs, d'autre part, que la société dispose d'un véhicule de remorquage;

Que du reste, l'existence d'un garage au sein de la société est contredite par la convention du 09 mars 2009;

Qu'il résulte de ses constatations que SARRE CONS n'a pas prouvé disposer au Sénégal d'un service après vente;

SUR LA CONFORMITE DE L'OFFRE DE SARRE CONS

Considérant que CFAO excipe de la non-conformité de l'offre de SARRE CONS, motif pris de la non production de l'autorisation du fabricant, alors qu'il est mentionné à l'IC 18.1 (b) des DPAO que l'autorisation du fabricant est requise ;

Que, toutefois, pour rejeter ce grief, l'autorité contractante invoque la nécessité d'assurer la concurrence et se prévaut de l'Avis n° 017 précité rendu par le CRD ;

Considérant qu'au moment de la confection de son DAO, PETROSEN n'ignorait pas cet Avis qui ne l'a pas empêché d'exiger des candidats la production d'une autorisation du fabricant ;

Que si cet Avis d'ailleurs rendu à la suite d'une saisine concernant les critères retenus dans un DAO, donc avant lancement de la procédure, a une valeur juridique certaine, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est de principe que les critères définitivement arrêtés dans le DAO ne peuvent être remis en cause que dans un délai précis et que l'autorité contractante qui les arrête est tenue de les appliquer;

Qu'ainsi, en déclarant conforme l'offre de SARRE CONS, qui n'a pas produit l'autorisation du fabricant, la commission des marchés de PETROSEN a méconnu et violé les dispositions du DAO et les principes de transparence et d'égalité des candidats;

SUR LA NON PRODUCTION PAR CFAO DE TOUS LES ETATS FINANCIERS REQUIS

Considérant qu'il est demandé, au point 5.1 des DPAO, aux candidats de produire les états financiers certifiés des trois dernières années ;

Que PETROSEN fait grief à CFAO de n'avoir pas fourni tous les états financiers requis et de n'avoir communiqué que ses chiffres d'affaires de 2010 et 2012, comme relevé dans le rapport d'évaluation ;

Considérant que, toutefois, dans le procès-verbal d'ouverture des plis, ce manquement n'a pas été relevé, ce qui induit que l'autorité contractante n'a pas demandé à CFAO de fournir les pièces manquantes, dans un délai précis, en application des dispositions de l'article 43, alinéa 5 du Code des marchés publics ;

Que, dans ces conditions, l'autorité contractante ne peut valablement invoquer le grief précité pour déclarer l'offre de CFAO non conforme ;

PAR CES MOTIFS

- 1- Constate que SARRE CONS n'a pas rempli l'exigence d'avoir exécuté un marché dont le montant est égal à deux fois au moins son offre ;
- 2- Dit que SARRE CONS n'a pas prouvé qu'il dispose au Sénégal d'un service après vente ;
- 3- Constate qu'en dépit de l'Avis de l'ARMP dont elle se prévaut, PETROSEN a exigé dans le DAO la production d'une Autorisation du fabricant ;
- 4- Constate que SARRE CONS n'a pas produit d'Autorisation du fabricant ;
- 5- Dit que PETROSEN, étant tenue par les critères arrêtés définitivement dans le DAO, a violé les principes de transparence et d'égalité des candidats, en déclarant l'offre de SARRE CONS conforme ;
- 6- Constate qu'il n'a pas été relevé dans le procès-verbal d'ouverture des plis le défaut de production par CFAO des états financiers exigés ;
- 7- Constate que PETROSEN n'a pas demandé à CFAO de produire les pièces manquantes ;
- 8- Dit que, dans, ces conditions, PETROSEN ne peut exciper de ce fait pour déclarer l'offre de CFAO non conforme ;
- 9- Dit qu'il doit être demandé à CFAO la production des pièces manquantes, dans un délai déterminé ;
- 10- Annule l'attribution provisoire du marché ;
- 11- Ordonne la reprise de l'évaluation ;
- 12- Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à CFAO MOTORS SENEGAL, à PETROSEN, ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye Sylla

Les membres du CRD

Mamadou DEME

Abd'El Kader NDIAYE

Ndiacé DIOP

**Le Directeur Général
Rapporteur**

Saër NIANG

Sarre-Cons saisit la Cour Suprême d'un recours en annulation de cette décision du CRD.

La clause en question étant illégale, la Cour Suprême, par arrêt n° 47 du 22 août 2013, annula la décision du CRD n° 118 du 3 octobre 2012, en faisant valoir que « considérant que selon les dispositions des articles 88 du traité instituant l'UEMOA et 3 du règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques anticoncurrentielles, des accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises constituent des ententes qui restreignent ou faussent le jeu de la concurrence ; considérant qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 24-3 nouveau code des obligations de l'Administration, les autorités contractantes doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; considérant qu'en application de ces textes, l'autorité contractante ne peut violer les règles de concurrence et de libre accès aux marchés publics, en insérant dans les dossiers d'appel d'offres (DAO) une clause relative à l'autorisation du constructeur à fournir par les candidats au marché de véhicules neufs ;

Considérant que pour annuler l'attribution provisoire faite au profit de Sarre-Cons, le CRD a, dans la décision attaquée, reproché à la commission des marchés de Pétersen d'avoir méconnu cette clause, alors que celle-ci est contraire aux dispositions légales ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche est fondé ».

En France, le juge de l'excès de pouvoir sanctionne l'erreur de droit. Il y a erreur de droit lorsque l'acte attaqué méconnaît directement une règle de droit ou en fait une mauvaise interprétation.

VIII. OBLIGATION DE RESPECTER LES CLAUSES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES – OBLIGATION DE SAISIR PREALABLEMENT LE CRD AVANT DE SAISIR LA COUR SUPREME POUR CONTESTER UNE ATTRIBUTION PROVISOIRE

Suite à l'appel d'offres lancé par le Centre Hospitalier Abass NDAO le 05 mars 2012 et relatif à un marché de nettoyage, la société Al Firdaws a été déclarée attributaire provisoire.

Sur recours de l'entreprise Serigne Fallou (ESEF), le CRD, par décision numéros 52 du 18 mai 2012 et 62 du 6 juin 2012, a, respectivement, ordonné la suspension de la procédure de passation de marché, annulé la décision d'attribution provisoire faite à la société Al Firdaws et prescrit la réévaluation des offres aux motifs que d'une part ESEF a satisfait au critère d'exécution d'un marché similaire et que d'autre part son offre étant exhaustive, le rejet décidé par la commission des marchés pour défaut d'exhaustivité n'est pas fondé.

**DECISION N° 062/12/ARMP/CRD DU 06 JUIN 2012
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ESEF SURL
CONTESTANT LA DECISION D'ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A
L'ENTRETIEN ET AU NETTOIEMENT DE L'HOPITAL ABASS NDAO DE
DAKAR**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu l'article 30 du Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ESEF Surl daté du 08 mai 2012, reçu le lendemain au bureau du Courrier et enregistré le 11 mai 2012 au Secrétariat du CRD sous le numéro 402/12 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'enquête sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :

Par lettre en date du 08 mai 2012, reçue le 09 mai 2012, puis enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 402/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), l'Entreprise Serigne Falou (ESEF Surl) a saisi le CRD d'un recours pour contester l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux d'entretien et de nettoyage de l'Hôpital Abass Ndao de Dakar.

LES FAITS

Le 05 mars 2012, l'Hôpital Abass Ndao a fait paraître dans le journal quotidien « Le Soleil », un avis d'appel d'offres relatif aux travaux d'entretien et de nettoyage de ses locaux.

A l'ouverture des plis, huit (8) offres ont été déposées.

Après évaluation des offres reçues, la commission des marchés a désigné le soumissionnaire Al Firdawsi Services attributaire du marché, puis a notifié, par lettre du 08 mai 2012, aux autres candidats le rejet de leurs offres.

Le même jour, ESEF Surl a introduit auprès du CRD, un recours contestant la décision d'attribution du marché susnommé.

Par décision n° 052/12/ARMP/CRD du 18 mai 2012, le CRD a suspendu la procédure de passation du marché litigieux.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, ESEF Surl soutient qu'elle a soumis l'offre la moins disante à l'ouverture des plis et a respecté les critères indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

Par conséquent, elle conteste la non exhaustivité de son offre, motif avancé par la commission des marchés pour l'écarter.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Selon le Centre Hospitalier Abass Ndao, ESEF Surl a présenté une liste de produits d'entretien non conformes ne comprenant que dix sept (17) articles, en lieu et place des dix neuf (19) exigés par les clauses techniques du dossier d'appel d'offres (DAO).

Le requérant a également omis de présenter la fiche technique desdits produits faisant ressortir les activités antimicrobiennes, ce qui est important, au vu de la nature et de la qualité des produits pour ce type de marché.

Par ailleurs, le requérant n'a pas respecté les exigences de la clause 5.4 des Données particulières en matière de capacité technique, notamment la réalisation, au moins, d'un marché similaire qui porte sur des prestations de nettoyage dans un centre hospitalier.

Pour l'autorité contractante, cette exigence revêt une importance capitale au regard des prescriptions du Programme national de lutte contre les infections nosocomiales (PRONALIN) et de son comité local (CLLIN).

En effet, la récurrence des infections nosocomiales, et leurs conséquences parfois fatales, oblige le Centre Hospitalier, en rapport avec l'Institut Pasteur, à effectuer des prélèvements dans les salles d'hospitalisation, les blocs opératoires, les locaux du laboratoire et lieux de soins, aux fins d'analyses biologiques et microbiologiques pour identifier les souches résistantes.

Pour conclure, l'autorité contractante soutient que le marché a fait l'objet d'une revue a priori à toutes les étapes de la procédure par la DCMP.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la validité des motifs avancés par la commission des marchés pour écarter l'offre du requérant pour, d'une part, défaut d'exhaustivité et, d'autre part, pour absence de preuve indiquant la réalisation d'un marché similaire.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que selon les dispositions de l'article 27 du Code des obligations de l'Administration modifié, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats des justifications concernant notamment l'expérience acquise dans la réalisation d'activités analogues à celle faisant l'objet du marché ; que cependant, ils doivent respecter les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

Considérant que selon les dispositions des articles 68 et 70 du Code des Marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;

Considérant qu'à la suite de cette première étape, la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis dans le dossier d'appel à la concurrence et propose l'attribution du marché au candidat qui a soumis l'offre conforme évaluée la moins disante et qui remplit les critères de qualification ;

1) SUR LA NON EXECUTION D'UN MARCHÉ SIMILAIRE :

Considérant qu'il est constant comme résultant des énonciations de la clause 5.4 des Données particulières de l'Appel d'offres (DPAO) que le candidat doit, notamment, prouver la réalisation d'un marché similaire durant les trois dernières années ;

Considérant que par rapport à ce critère, le requérant a produit copie des marchés suivants, avec à l'appui, des attestations de bonne exécution:

- a) nettoyage et désinfection des immeubles gérés par la Direction de la Gestion du Patrimoine Bâti d'un montant de 11 162 800 F CFA ;
- b) entretien et nettoyage des locaux du Ministère de l'Intérieur pour un montant de 28 780 000 F CFA,
- c) nettoyage du Building administratif et de l'Annexe des Archives nationales pour un montant de 29 880 880 F CFA ;

Considérant que par marché similaire, il faut entendre, non pas des prestations identiques, mais équivalentes, qui peuvent d'une certaine façon, être assimilées, les unes aux autres

Considérant que l'exécution d'un marché de nettoyage, fût-il dans un établissement hospitalier ou autre, suppose, de la part du prestataire, l'obligation, pour l'essentiel, d'avoir à sa disposition, des moyens humains à travers des agents formés à cet effet, des moyens logistiques adéquats et des moyens financiers prouvant sa capacité à exécuter les prestations visées ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation des offres, que le requérant a rempli les critères susnommés qui sont d'ailleurs énoncés à la clause 5.4 (qualification des candidats) des Données particulières du DAO et a produit également, l'agrément du Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Prévention le déclarant apte à effectuer des travaux de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et de nettoyage ;

Qu'à cet égard, il y a lieu par conséquent de considérer que le soumissionnaire ESEF a satisfait à ce critère ;

2) SUR LA NON EXHAUSTIVITE DE L'OFFRE DU REQUERANT :

Considérant que la Section IV du DAO (Programme d'activités) cite les produits d'entretien suivants dont doit disposer chaque soumissionnaire :

- détergent,
- poudre à récurer (ajax),
- aseptol (bouteille),
- lave vitre à l'alcool 30° (starwax),
- klercide désinfectant,
- soludoz,
- florodor,
- eau de javel concentrée pure,
- bombe désodorisante starwax pour les bureaux,
- boule désodorisante pour WC,
- savon pour les toilettes individuelles,
- débouchoir en poudre (acide borique) pour lavabo et chaise anglaise,
- papier hygiénique,
- savon liquide,
- sol plusieurs,
- cire pour cuir, bois, bureaux, miroirs et stores,
- désinfectant bactéricide citronnelle,
- désinfectant bactérmat,
- lave vitres.

Considérant que selon la clause 14.1 des Instructions aux candidats, le candidat devra produire une proposition technique incluant un programme d'activités et les méthodes d'exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d'exécution ainsi que tout autre renseignement demandé ;

Considérant que selon les informations exposées en liminaire à la Section IV du DAO, l'objectif du Programme d'activités est :

- 1) de fournir suffisamment d'informations sur les services à exécuter afin de permettre de préparer efficacement des soumissions précises, et,
- 2) une fois le marché attribué, de permettre la présentation d'un programme d'activités qui sera utilisé pour l'appréciation périodique des services exécutés ;

Considérant qu'il est reproché au requérant, à l'instar des autres soumissionnaires Ets Khady Ndiaye, TGE, SDN/Sécurité, d'avoir omis de présenter la fiche technique des produits demandés ou d'avoir présenté une liste de produits non exhaustive, ce qui justifie la non-conformité de leurs offres ;

Considérant que cependant, la mise en place desdits produits ne peut s'apprécier qu'au moment de l'exécution des prestations par le titulaire, non au moment de l'évaluation des offres, comme semble l'indiquer la commission des marchés ;

Considérant que si l'autorité contractante décide de faire de la disponibilité des produits susmentionnés un critère de conformité, elle doit nécessairement prévoir, dans le DAO, l'obligation pour les soumissionnaires de présenter des échantillons, pour permettre à la commission des marchés d'évaluer en toute objectivité cette exigence ;

Considérant dès lors, qu'en l'absence de toute obligation de présentation d'échantillons, la commission des marchés ne saurait valablement invoquer le défaut d'exhaustivité de la fiche technique ou des produits proposés et motiver par conséquent sa décision de rejet ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que la clause 5.4 des Données particulières du DAO n'a pas exigé des candidats, qu'ils prouvent la réalisation d'un marché identique, mais d'un marché similaire ; à cet égard,
- 2) Constate que le requérant a prouvé la réalisation de trois marchés similaires; par conséquent,
- 3) Dit que ledit critère a été rempli par le requérant ;
- 4) Constate que l'autorité contractante n'a pas fait de la production des dix neuf produits exigés, un critère de conformité ; à cet égard,
- 5) Dit que la décision de rejet de l'offre de ESEF par la commission des marchés pour défaut d'exhaustivité, n'est pas fondée ;
- 6) Annule la décision d'attribution provisoire du marché ;
- 7) Ordonne la reprise de l'évaluation des offres ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société ESEF, au Centre Hospitalier Abass Ndao ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président
Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd'El Kader NDIAYE

Mamadou DEME

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

Le Directeur du Centre Hospitalier Abass Ndao, par lettre du 1^{er} octobre 2012, informa par la suite, la Société Al Firdaws du rejet de son offre et de l'attribution provisoire du marché à ESEF. En réponse au recours gracieux introduit par Al Firdaws le 04 octobre 2012 ledit Directeur rejeta le recours par décision du 11 octobre 2012.

Par requête reçue au greffe de la Cour Suprême le 7 novembre 2012, la société Al Firdaws demanda l'annulation des décisions du CRD numéros 52 du 18 mai 2012 et 62 du 6 juin 2012, ainsi que celle d'attribution provisoire du marché à ESEF par le Centre Hospitalier Abass Ndao ; par exploit du 20 novembre 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de Justice, la Société Al Firdaws a fait également signifier à l'ARMP et au Centre Hospitalier Abass Ndao une requête aux fins de sursis à l'exécution des décisions attaquées.

Selon arrêt n° 67 du 13 décembre 2012, la Cour Suprême rejeta la requête aux fins de sursis en faisant valoir qu'en l'état de l'instruction, le caractère sérieux des moyens reste à être établi par la société Al Firdaws qui ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice encouru du fait de l'exécution des décisions attaquées, au vu de l'article 73-2 de la loi organique sur la Cour Suprême.

De même que, suivant arrêt n° 59 du 28 novembre 2013, ladite Cour déclara irrecevable le recours formé par la Société Al Firdaws contre la décision d'attribution provisoire du marché à ESEF, ladite décision n'ayant pas été déférée au préalable au CRD, en violation des articles 88 et 89 du code des marchés publics.

Partageant la même conception que le CRD, la Cour rejeta également le recours en annulation introduit contre les décisions du CRD, estimant d'une part que l'erreur de droit alléguée par la société Al Firdaws n'est pas fondée dans la mesure où ESEF a satisfait au critère de réalisation d'un marché similaire et qu'il ne résulte pas des clauses du DAO que le soumissionnaire doit disposer d'un matériel spécifique lié à une quelconque spécialité d'une structure hospitalière. D'autre part, la Cour estima que le moyen tiré du vice de procédure n'est pas, non plus, fondé parce que l'exigence du DAO selon laquelle le prestataire doit obligatoirement disposer de produits d'entretien s'apprécie au moment de l'exécution des prestations du candidat retenu.

IX. INCOMPETENCE DU CRD POUR LES MARCHES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE SA COMPETENCE

Pour apprécier les domaines de compétence du CRD, il faut se référer aux textes et articles suivants :

- Articles 11 et 12 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA ;
- Article 31 nouveau code des obligations de l'administration ;
- Article 2 du code des marchés publics ;
- Articles 20 à 24 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

En application de ces dispositions, le CRD s'est déclaré incompétent chaque fois qu'il a été saisi d'une affaire n'entrant pas dans le champ de sa compétence.

Il en a été ainsi par exemple dans les deux affaires suivantes :

1. Société Management et Formation pour le Développement (MFD) contre Institution de Prévoyance Sociale (ex Caisse de Sécurité Sociale) ;
2. Société Entreprise Travaux Modernes Sarl contre GTZ.

Dns la première affaire, le CRD s'est déclaré incompétent parce que la Caisse de Sécurité Sociale a un statut de droit de privé et aucun élément n'établit qu'elle bénéficie du concours financier de l'Etat ou de ses démembrements ou qu'elle agit pour le compte d'une des autorités contractantes visées à l'article 2 du code des marchés publics (décision du CRD n° 18 du 2 février 2011).

Dans la seconde affaire, le CRD s'est déclaré incompétent parce que le marché litigieux est financé sur les ressources de la GTZ, organisme de coopération de la République d'Allemagne, non visé par les dispositions de l'article 2.1 du code des marchés publics, de même que la G.T.Z n'agissait pas en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte d'une autorité contractante (décision du CRD n° 19 du 2 février 2011).

**DECISION N° 018/11/ARMP/CRD DU 02 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MANAGEMENT
ET FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT CONTESTANT LE REJET DE
SON OFFRE LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES
RELATIF A L'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION DE LA BRANCHE
ASSURANCE MATERNITE LANCEE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre-mémoire en date du 04 janvier 2011 de la société Management et Formation pour le Développement (MFD) ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, MM. Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 04 janvier 2011, enregistrée le lendemain sous le numéro 006/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, l'Administrateur général de la société Management et Formation pour le Développement (MFD) a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre pour défaut de pièces administratives.

Considérant que le présent recours est dirigé contre une personne morale de droit privé ; qu'à cet égard, il convient avant tout examen au fond de vérifier si cette personne figure au nombre de celles dont les marchés sont soumis aux dispositions du Code des Marchés publics et, par conséquent, à la compétence du Comité de Règlement des Différends.

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 31 du Code des Obligations de l'Administration, le CRD a compétence pour se prononcer sur les recours non juridictionnels introduits par toute personne qui a participé à une procédure de passation de marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 nouveau du Code des Marchés publics, les dispositions du présent code s'appliquent :

1. aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :
 - a) l'Etat, et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ;
 - b) les collectivités locales, y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des Collectivités locales ;
 - c) les établissements publics ;
 - d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;
 - e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;
 - f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.
2. aux marchés passés par une personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte d'une autorité contractante.

Considérant que la loi n° 91-33 du 26 juin 1991 a transformé l'Etablissement public « *Caisse de Sécurité sociale* » en une Institution de Prévoyance sociale ;

Qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi, la Caisse de Sécurité sociale est, en application de l'article 3 de la loi n° 75-50 du 03 avril 1975, une Institution de Prévoyance Sociale de droit privé ;

Qu'à ce titre, elle est composée, conformément à l'article 4, d'employeurs et de travailleurs tels que définis par le Code du Travail et le Code de la Marine marchande ; que ses ressources sont, aux termes de l'article 6 de son statut, constituées des cotisations versées par les membres adhérents, des produits des placements financiers, des titres de participation, des immeubles de rapport, des produits tirés de l'exploitation de ses structures sanitaires, des emprunts, subventions dons et legs et de toutes autres ressources dont la nature n'est pas contraire aux objectifs de la Caisse ;

Considérant le statut de droit privé de la Caisse et l'absence d'éléments établissant qu'elle bénéficie du concours financier de l'Etat et/ou de ses démembrements ou qu'elle agit pour le compte d'une des autorités contractantes visées à l'article 2 du Code des Marchés publics, il convient, dès lors, de dire que le présent recours n'entre pas dans les compétences du CRD ; en conséquence,

DECIDE :

- 1) Se déclare incompétent ;
- 2) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Management et Formation pour le Développement (MFD), à la Caisse de Sécurité sociale ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

**DECISION N° 019/11/ARMP/CRD DU 02 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ENTREPRISE
TRAVAUX MODERNES CONTESTANT L'ATTRIBUTION DU MARCHE DE
FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE MATERIELS DE RESEAUX
ELECTRIQUES DANS SOIXANTE SIX (66) VILLAGES, LANCE PAR LA
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ).**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du 04 janvier 2011 de la société Entreprise Travaux Modernes Sarl, enregistrée le 06 janvier 2011 sous le numéro 008/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, MM. Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Ndiace DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et les moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire du 04 janvier 2011, la société Entreprise Travaux Modernes Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'attribution du marché de fourniture, transport et pose de matériels de réseaux électriques dans soixante six (66) villages.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le CRD a été saisi d'une lettre du 04 janvier 2011 de la société Entreprise Travaux Modernes Sarl, enregistrée le 06 janvier 2011 sous le numéro 008/11, contestant l'attribution du marché sus nommé à la suite de la notification du rejet de son offre ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'avis d'appel d'offres (AAO) du marché susvisé, la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) est chargée des opérations suivantes :

1. la vente du dossier d'appel d'offres (DAO) ;
2. la réception des offres et l'ouverture des plis ;
3. l'évaluation des soumissions ;

Considérant également que selon les dispositions de la clause 1.1 des Données particulières de l'Appel d'Offres, le financement du marché est assuré par la GTZ ;

Considérant que suite à l'appel d'offres en date du 6 août 2010, la GTZ a servi au requérant une lettre datée du 23 décembre 2010 lui notifiant le rejet de son offre et l'attribution des deux lots dudit marché ;

Considérant que dès le lendemain, le requérant a saisi la GTZ d'un courrier lui demandant les raisons du rejet de son offre ;

Qu'en l'absence de réponse, la société Entreprise Travaux Modernes Sarl a introduit un recours devant le CRD par courrier du 04 janvier 2011 pour dénoncer le rejet de son offre produit dans le cadre dudit marché ;

Considérant que l'article 2 du Code des Marchés publics prévoit que ses dispositions s'appliquent :

3. aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :
 - g) L'Etat et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ;
 - h) Les collectivités locales, y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des Collectivités locales ;
 - i) Les établissements publics ;
 - j) Les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;
 - k) Les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;
 - l) Les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.
4. Aux marchés passés par une personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte d'une autorité contractante.

Considérant qu'il est constant comme résultant du DAO et des autres pièces de la procédure, notamment de l'avis d'appel d'offres, des lettres de demande d'informations complémentaires et de l'avis d'attribution, que le marché litigieux est financé sur les ressources de la GTZ , organisme de coopération de la République d'Allemagne non visé par les dispositions de l'article 2.1 du Code des Marchés publics ;

Considérant également que la GTZ n'a pas agi en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte d'une autorité contractante ;

Qu'en effet, selon l'article 34 du Code des Marchés publics, les attributions de maître d'ouvrage délégué ne peuvent être confiées qu'aux :

- a) personnes morales et organismes mentionnés à l'article 2 du Code des Marchés publics ;
- b) personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou projets financés sur fonds d'aide extérieure ou agrés par arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l'ARMP ;

Qu'il s'en suit que le CRD doit se déclarer incompétent ;

DECIDE

1. Constate que le marché litigieux est financé sur les ressources de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ;
2. Constate que la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) n'est pas visée par les dispositions de l'article 2 du Code des Marchés publics énumérant les autorités contractantes dont les marchés sont soumis aux dispositions dudit Code ;
3. Constate qu'elle n'a pas agi en qualité de maître d'ouvrage délégué ; en conséquence,
4. Dit que le CRD est incompétent pour statuer sur ledit recours ;
5. Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier à la société Entreprise Travaux Modernes Sarl, à la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Ces positions du CRD sont conformes aux dispositions des textes qui fondent sa compétence ; et les règles de compétence étant d'ordre public tout organe investi du pouvoir de trancher des litiges doit d'abord vérifier sa compétence avant d'aborder la recevabilité de l'affaire qui lui est soumise.

X. IRRECEVABILITE DES RECOURS ADRESSES AU CRD AU-DELA DU DELAI DE TROIS (03) JOURS OUVRABLES FIXE PAR LE CODE DES MARCHES PUBLICS

Il résulte des articles 86 et 87 du code de 2007 (88 et 89 du code de 2011) que tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché peut, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux, auquel celle-ci est tenue de répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables ; qu'en l'absence d'une suite favorable à son recours, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de cinq (5) jours susvisé, pour présenter un recours au CRD.

S'appuyant sur ces dispositions, le CRD, pendant la période 2008 à 2013, a déclaré irrecevables, pour cause de forclusion, 207 affaires parmi les 1 155 qui lui avaient été soumises, soit 27%. Parmi celles-ci, nous citons, à titre d'exemple, les six (6) décisions suivantes rendues par le CRD :

1. N°8 du 19 janvier 2011 : Société Matériel Hospitalier (MHO) SA. contre Projet Dalal Diam ;
2. N° 12 du 2 février 2011 : GINGER/SCAT Internationale SA. contre Direction des Routes ;
3. N° 15 du 2 février 2011 : DMT contre COUD ;
4. N° 182 du 14 septembre 2011 : Groupement Ingénieurs (ICA-INCO-HYDROARCH contre AGEROUTE ;
5. N° 15 du 26 février 2009 : Société Sen TECHNOLOGY contre Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
6. N° 26 du 07 mars 2012 : Espace Auto contre SENELEC.

Les trois (3) premières décisions n'ont pas été déférées devant la Cour Suprême et les délais ont été bien décomptés par le CRD.

La quatrième décision a été déférée à la Cour Suprême qui a déclaré la requérante déchue de son recours pour n'avoir pas signifié sa requête à l'ARMP, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi, en application de l'article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour Suprême.

La Cour Suprême, par arrêt n° 47 du 10 décembre 2009, a rejeté le recours en annulation intenté par la société Sen Technology contre la décision n° 15 du 26 février 2009 du CRD, donnant ainsi raison à ce dernier. En effet, l'avis d'attribution du marché concerné ayant été publié le 31 décembre 2008 et la Société Sen Technology n'ayant saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux, que le 30 janvier 2009, elle a donc exercé ledit recours hors du délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ; et en conséquence, le recours devant le CRD, dont le délai d'exercice est tributaire du recours gracieux, lui-même atteint par la tardivité, est bien irrecevable.

Par contre, la Cour Suprême, par arrêt n° 48 du 09 août 2012, a annulé la décision de CRD n° 26 du 07 mars 2012, parce que c'est à tort que le CRD a déclaré irrecevable le recours de la société Espace Auto introduit le 28 février 2012 ; en effet, la réponse défavorable de la SENELEC étant du 22 février 2012, et le délai étant franc, son point de départ est le jeudi 23 février 2012 et son terme le mardi 28 février 2012, compte non tenu des samedi 25 et dimanche 26 février, jours non ouvrables.

Dans les codes de 2007 et 2011, le recours gracieux n'est pas une obligation, mais une simple faculté donnée au candidat à la commande publique.

Si celui-ci veut exercer ce droit, il doit le faire auprès de l'autorité contractante dans un délai de cinq (05) jours ouvrables. Et en l'absence de suite favorable, il dispose de trois (03) jours ouvrables pour saisir le CRD. Mais, il n'est pas possible audit candidat d'introduire un recours devant le CRD, après saisine de l'autorité contractante, avant l'expiration du délai de cinq (05) jours ; en effet, les dispositions susvisées précisent bien que le délai de trois (03) jours ouvrables dont dispose le requérant pour saisir le CRD court :

- soit à partir de la réponse de l'autorité contractante ;
- soit à partir de l'expiration du délai de cinq (05) jours dont dispose cette autorité pour répondre à la réclamation, son silence au-delà de ces cinq (05) jours valant décision implicite de rejet du recours gracieux.

De même que le CRD applique ces dispositions avec pertinence en affirmant que :

- « le requérant qui choisit de saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois (03) jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l'expiration du délai de cinq (05) jours constitutif d'un rejet implicite dudit recours gracieux ».
- « le recours ayant été introduit avant l'expiration du délai de réponse de cinq (05) jours imparti à la personne responsable du marché, il doit être déclaré irrecevable ».

Cette position du CRD est affirmée dans une jurisprudence constante, par exemple :

- Décision n° 90 du 21 août 2012 : Cristabel Diffusion contre MINT-DCEAE ;
- Décision n° 30 du 21 mars 2012 : Fermon Labo Sénégal contre Ministère de l'Enseignement Élémentaire ;
- Décision n° 125 du 17 octobre 2012 : Société ESEF contre PAD.

Le respect des délais, comme nous l'avons vu dans l'arrêt de la Cour Suprême précité n° 48 du 09 août 2012, est contrôlé par ladite juridiction qui a eu à annuler la décision du CRD n° 26 du 7 mars 2012, pour mauvaise computation.

Par ailleurs, le recours en question, conformément aux dispositions susvisées, d'une part n'est ouvert qu'au candidat à la procédure d'attribution d'un marché, et non au tiers et d'autre part, il peut être déclaré irrecevable si le requérant n'invoque pas une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics.

XI. IRRECEVABILITE DES OFFRES ARRIVEES A LA COMMISSION DES MARCHES APRES LES HEURES ET DATE LIMITES DE DEPOT

En vertu de l'article 67.1 du code des marchés publics « à l'expiration des date et heure limitées de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de procéder à l'ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres ».

Se fondant sur cette disposition, les commissions des marchés des autorités contractantes rejettent les soumissions qui sont déposées en retard, de même que le CRD, sur saisine des soumissionnaires dont les plis ont été rejetés, déclare fondées les décisions d'irrecevabilité prises par lesdites commissions, en de pareilles circonstances.

Il en a été ainsi, par exemple, dans l'affaire opposant la société Fibres et Réseaux SARL à l'observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), où le CRD a rendu la décision n° 3 du 12 janvier 2011, en considérant que la décision d'irrecevabilité de l'offre, prise par l'autorité contractante est fondée parce que la requérante n'a pas respecté les dispositions de l'article 67.1 du code des marchés publics, en vertu desquelles la commission des marchés n'est autorisée à ouvrir que les plis déposés au plus tard à la date et l'heure limites de dépôt des offres.

DECISION N° 003 /11/ARMP/CRD DU 12 JANVIER 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE FIBRES ET RESEAUX SARL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE PAR LA COMMISSION DES MARCHES LORS DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPEL D'OFFRES RELATIF A L'ACQUISITION DE LOGICIELS DE BUREAUTIQUE, D'ANALYSE STATISTIQUE, DE GESTION ET DE MESSAGERIE AU PROFIT DE L'OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DES SERVICES FINANCIERS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Fibres et Réseaux Sarl en date du 13 décembre 2011, enregistré le 17 décembre 2010 sous le numéro 859/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les faits, moyens et conclusions des parties,

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd'El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre mémoire en date du 13 décembre 2011, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le numéro 859/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société Fibres et Réseaux Sarl a contesté le rejet de son offre lors de l'ouverture des plis du marché relatif à l'acquisition de logiciels de bureautique, d'analyse statistique, de gestion et de messagerie lancé par l'Observatoire de la Qualité des Services financiers (OQSF) du Ministère de l'Economie et des Finances ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'au terme des articles 86 et 87 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié par le décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010, tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché est habilité à saisir soit la personne responsable dudit marché d'un recours gracieux, soit le CRD ;

Considérant qu'à la suite de l'avis d'appel d'offres du marché susvisé paru dans le journal « Le Soleil » daté du 09 novembre 2010, la commission des marchés du Ministère de l'Economie et des Finances a procédé à l'ouverture des plis programmée le 08 décembre 2010 ;

Que lors de cette séance, l'offre de la société Fibres et Réseaux Sarl a été déclarée irrecevable par la commission des marchés ;

Prenant acte de cette décision, la société Fibres et Réseaux Sarl a saisi directement le CRD d'une requête en date du 13 décembre 2011, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le numéro 859/10 au Secrétariat du CRD, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant qu'en référence à l'article 86 du Code des Marchés publics modifié, ledit recours a été exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'ouverture des plis, ;
Qu'en conséquence, il doit être déclaré recevable.

LES FAITS

L'OQSF a lancé dans le journal « Le Soleil » en date du 09 novembre 2010, un appel d'offres portant sur l'acquisition de logiciels de bureautique, d'analyse statistique, de gestion et de messagerie à son profit.

Selon les dispositions de la clause 8 de l'Avis d'appel à la concurrence, le dépôt des offres est prévu au siège de l'OQSF sise à Sacré Cœur 3 villa n° 75b3 au plus tard le 10 décembre 2010 à 10 heures et l'ouverture des plis fixée le même jour à 11 heures précises au Ministère de l'Economie et des Finances sis à la Rue Carde ;

Bien qu'étant arrivé au Ministère de l'Economie et des Finances avant l'heure programmé pour l'ouverture des plis, le requérant s'est vu refusé le dépôt de son offre par la commission des marchés.

En réaction à cette décision, la société Fibres et Réseaux Sarl a introduit le présent recours devant le CRD.

Par décision n°140/10/ARMP/CRD du 23 décembre 2010, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché susvisé.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa requête, la société Fibres et Réseaux Sarl soutient qu'elle a été informée le 8 décembre 2010 par courrier électronique que l'ouverture des plis du marché sus nommé est confirmée à la date fixée dans l'avis d'appel d'offres à la Salle Birame Ndiaye sise au 5^{ème} étage du siège du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Malheureusement, pour des raisons liées au trafic routier, le requérant soutient qu'il n'a pas pu déposer son offre à l'adresse de l'OQSF à Sacré Cœur, comme indiqué dans l'Avis d'appel d'offres, mais qu'il a pu se rendre au siège du Ministère des Finances à 10 heures 25 minutes ;

Malgré son arrivée avant l'heure prévue pour l'ouverture des plis au Ministère des Finances, la commission des marchés a refusé de prendre possession de son pli tout en rejetant sa demande d'assister à l'ouverture des plis ;

Selon le requérant, en dépit de la non remise de son pli au siège de l'OQSF, son représentant est arrivé au Ministère de l'Economie et des Finances avant le début de la séance d'ouverture des plis, raison pour laquelle la commission a déclaré à tort que son offre était irrecevable ;

Par ailleurs, l'interdiction de participer à l'ouverture des plis qui lui a été signifiée par la commission des marchés est contraire aux dispositions de la clause 26.1 des Instructions aux candidats du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) qui prévoit que l'ouverture des plis est publique.

LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES

La Commission des marchés déclare que conformément aux dispositions de l'Avis d'Appel d'offres du marché sus nommé, quatre offres ont été déposées dans les délais requis au siège de l'OQSF, puis acheminées au siège du Ministère de l'Economie et des Finances pour les modalités de leur ouverture ;

A l'arrivée de la commission des marchés au lieu prévu pour l'ouverture des plis, le requérant a sollicité devant les autres candidats l'autorisation de déposer son offre et participer ainsi à la compétition ;

En réponse, la commission des marchés lui a opposé un refus tout en l'informant du rejet des offres des autres candidats arrivés comme lui, en retard ;

Pour justifier son refus, la commission des marchés soutient qu'elle s'est conformée aux dispositions cumulées de l'avis d'appel d'offres et de l'alinéa 1 de l'article 67 du Code des Marchés publics modifié qui indiquent que seuls les plis reçus au plus tard à la date et à l'heure limite de dépôt des offres peuvent être ouverts ;

Par ailleurs, les dispositions de l'article 67 alinéa 3 du Code des Marchés publics modifié n'autorisent à l'ouverture des plis que la présence des candidats ayant participé à la compétition ;

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :

- 1) le fondement du rejet de l'offre du requérant arrivé avant l'ouverture de la séance de dépouillement nonobstant le non respect par ce dernier des conditions fixées pour le dépôt des offres ;
- 2) l'interprétation à donner au caractère public de la séance d'ouverture des plis ;

AU FOND

- 1) SUR LE FONDEMENT DU REJET DE L'OFFRE DU REQUERANT ARRIVE AVANT L'OUVERTURE DE LA SEANCE DE DEPOUILLEMENT NONOBTANT LE NON RESPECT PAR CE DERNIER DES CONDITIONS FIXEES POUR LE DEPOT DES OFFRES.

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'avis d'appel d'offres du marché sus visé que les plis devront être déposés d'abord au siège de l'OQSF au plus tard le 10 décembre 2010 à 10 heures , faute de quoi, ils ne seront pas acceptés ; que d'autre part, l'ouverture des plis se déroulera le même jour à 11 heures au Ministère de l'Economie et des Finances en présence des représentants des candidats ;

Considérant que selon l'article 67.1 du Code des Marchés public modifié, la commission des marchés n'est autorisée à ouvrir que les plis déposés à l'expiration des date et heure limites de dépôt des offres ;

Considérant également que les raisons avancées par le requérant pour justifier le non respect des conditions fixées pour le dépôt de son offre relèvent uniquement de sa propre responsabilité ;

Qu'en application des dispositions de l'avis d'appel d'offres et conformément à la clause 23.1 des Données particulières de l'appel d'offres fixant les dates et heure limites de remise des offres le 10 décembre 2010 à 10 heures, il revenait au requérant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les modalités de dépôt des offres préalablement fixées et participer ainsi à la compétition;

Considérant que par courrier en date du 8 décembre 2010, les candidats ont été informés d'un additif rappelant l'ouverture des plis aux date et heure indiquées dans le DAO, tout en précisant la salle devant abriter la séance ;

Considérant que cette information ne constitue guère une remise en cause d'une disposition quelconque du DAO pouvant entraîner un report du dépouillement, si l'on se réfère à la clause 8 des Instructions aux candidats qui autorise l'autorité contractante à publier ou communiquer aux candidats tout additif au DAO en laissant, à sa discrétion, la possibilité de reporter la date limite de remise des offres ;

Considérant également qu'il appartient à l'autorité contractante de faire coïncider dans la mesure du possible, d'une part, les lieux prévus pour le dépôt et l'ouverture des plis, d'autre part, l'heure limite de dépôt des offres et le démarrage de l'ouverture des plis afin de minimiser les possibilités de manipulation des offres reçues et favoriser l'égal accès de tous les candidats aux marchés publics ;

Qu'il y a lieu cependant de constater que la société Fibres et Réseaux Sarl n'a pas respecté les prescriptions de l'article 67.1 du Code des Marchés public modifié et que la commission des marchés a valablement prononcé l'irrecevabilité de l'offre du requérant.

2) SUR LE CARACTERE PUBLIC DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS ;

Considérant que le requérant conteste la décision de la commission des marchés l'interdisant à assister à l'ouverture des plis en raison du non respect des prescriptions relatives au dépôt de son offre ;

Considérant qu'il ressort de l'article 67.3 du Code des Marchés publics modifié que les plis sont ouverts en séance publique à la date et à l'heure limites de dépôt des offres indiquées dans le DAO qu'en présence des candidats qui ont soumis des offres ;

Considérant que lors de la séance d'ouverture des offres, il est fait obligation aux candidats ou leur représentant présents de signer un registre attestant de leur présence et subséquemment, à la commission des marchés, de consigner toutes les informations dès la fin de l'opération et de dresser un procès verbal remis à tous les candidats ;

Qu'en vertu de ce principe de transparence mais également de la nécessité de protéger les soumissionnaires qui ont participé à la compétition, les dispositions de l'article 67.3 du Code des Marchés publics modifié ne permettent la participation à l'ouverture des plis, qu'aux candidats ayant un intérêt direct à la procédure de passation ainsi qu'aux représentants des organismes de financement, le cas échéant;

DECIDE :

- 53) Déclare recevable la requête introduite ;
- 54) Constate que le requérant n'a pas déposé son pli aux date et heure indiquées dans le DAO comme l'y conviait les prescriptions de l'article 67.1 du Code des Marchés public modifié ; par conséquent,
- 55) Déclare fondé le motif de rejet de son offre par la commission des marchés ;
- 56) Invite cependant l'autorité contractante à minimiser les possibilités de manipulation des offres reçues et favoriser l'égal accès de tous les candidats aux marchés publics en faisant coïncider, autant que c'est possible, les formalités de dépôt des offres et d'ouverture des plis ;
- 57) Dit qu'en référence aux dispositions de l'article 67.3 du Code des Marchés publics modifié, la présence à l'ouverture des plis n'est pas autorisée aux opérateurs qui n'ont pas soumis une offre ;
- 58) Ordonne la continuation de la procédure de passation ;
- 59) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Fibres et Réseaux Sarl, à l'Observatoire de la Qualité des Servies financiers (OQSF) du
- 60) Ministère de l'Economie et des Finances et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

La disposition de l'article 67.1 du code sénégalais des marchés publics est le pendant de l'article 58.1 du code français des marchés publics qui dispose : « seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ».

Pour la doctrine française, les délais sont impératifs et leur méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure d'attribution du marché et le caractère impératif s'impose quelles que soient les circonstances, tant pour ce qui concerne le délai de réception des offres, que celui séparant l'envoi à la publication de l'avis de pré information et l'envoi de l'appel à la concurrence. C'est pourquoi, les plis, quelque soit leur support, reçus après la date et l'heure limites de dépôt annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ne sont pas ouverts et sont déclarés irrecevables.

La jurisprudence française est constante et bien établie depuis de nombreuses années ; en effet, pour le Conseil d'Etat, tout pli arrivé hors délai, pour quelque raison que ce soit doit être considéré comme irrecevable (CE, 3 novembre 1997, Préfet de la Marne contre Commune de Francheville, n° 148150).

La jurisprudence a déjà pu juger qu'un accident de transporteur ou une grève des services de la Poste n'étaient pas des faits permettant d'accepter la recevabilité d'un pli arrivé en retard ; le fait que le candidat n'y soit pour rien n'entre pas en ligne de compte.

Il n'existe que très peu d'exemples favorables dans la jurisprudence française et ils concernent des cas de figure particuliers (C.E, 17 décembre 1971, Commune de Cayenne, n° 78728).

XII. INTERDICTION AUX CANDIDATS DONT LES PLIS SONT ARRIVES EN RETARD D'ASSISTER A L'OUVERTURE DES PLIS

L'article 67.3 du code des marchés publics dispose : « tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des plis.... ».

S'appuyant sur cette disposition, les commissions des marchés interdisent à tous les candidats dont les plis sont rejetés, pour cause de tardivité, d'assister à l'ouverture des plis. De même que le CRD siégeant en commission des litiges confirme cette position.

Il en a été ainsi, par exemple, dans l'affaire société Fibres et Réseaux SARL contre OQSF du MEF, précité, où le CRD, par la même décision susvisée, a déclaré que la décision d'interdiction d'assister à l'ouverture des plis prise par la Commission des marchés est fondée parce qu'en vertu de l'article 67.3 du code des marchés publics, modifié, la présence à l'ouverture des plis n'est pas autorisée aux opérateurs qui n'ont pas soumis une offre.

En France, l'article 58.1 du Code des marchés publics dispose : « l'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis ».

La doctrine française pense que c'est pour garantir la confidentialité et éviter toute pression que les candidats ne sont pas admis à la séance d'ouverture des plis.

XIII. IRRECEVABILITE DU RECOURS CONTESTANT UNE INSCRIPTION AU PLAN DE PASSATION DES MARCHES

En vertu de l'article 6 du code des marchés publics, les autorités contractantes établissent au début de chaque année un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble des marchés qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée.

En application de cette disposition, l'Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l'Innovation Technologique (ASPIT) a inscrit dans son plan de passation des marchés, une demande de renseignements et de prix ayant pour objet des « travaux de commissariat aux comptes et d'assistance comptable ».

Par lettre datée du 20 septembre 2012, le sieur Papa Konaré SECK, Expert Comptable, Commissaire aux Comptes, a saisi le CRD d'un recours contestant ladite inscription et demandant l'annulation de la demande de renseignements et de prix relative à la nomination du Commissaire aux comptes.

Par décision numéro 114 au 26 septembre 2012, le CRD déclara, avec pertinence, que le recours est irrecevable parce que non seulement le requérant n'a ni la qualité de candidat ni celle de soumissionnaire au sens des articles 20 et 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, mais également le recours ne se rattache à aucun des objets pour lesquels la commission des litiges du CRD est compétente.

**DECISION N° 114/12/ARMP/CRD DU 26 SEPTEMBRE 2012
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE PAPA KONARE SECK, EXPERT
COMPTABLE, CONCERNANT LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE
PRIX RELATIVE AU CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'AGENCE
SENEGALAISE POUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE (ASPIT)**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Papa Konaré SECK daté du 20 septembre 2012, enregistré le même jour, sous le numéro 834, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD);

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 20 septembre 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, Papa Konaré Seck, expert comptable, commissaire aux comptes, a introduit un recours pour contester l’inscription dans le plan de passation des marchés (PPM) de l’ASPIT d’une demande de renseignements et de prix ayant pour objet des « travaux de commissariat aux comptes et d’assistant comptable », les dates de lancement et d’attribution étant prévues les 09 et 18 octobre 2012.

Au soutien de son recours, le requérant expose que l’article 20 du décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ASPIT prévoit qu’elle est soumise à un audit externe exercé par un commissaire aux comptes choisi- pour un mandat correspondant à six (6) exercices et renouvelable sans limitation- par le Conseil de Surveillance dont les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Dans le cadre de l’exercice de ce mandat, avant l’arrivée du terme et sans l’aval du Conseil de Surveillance, la Direction de l’ASPIT avait envisagé de le remplacer en lançant une DRP référencée C_ASPIT_001.

Cette décision a été contestée par une lettre du 26 avril 2012 adressée à la Directrice Générale, tandis que le 29 mai 2012, le Conseil de Surveillance lui a réitéré sa confiance.

Toutefois, cette décision de l’organe délibérant n’a pas empêché une nouvelle inscription de la DRP dans le PPM de l’ASPIT référencée P_ASPIT_2012_2.

Jugeant cette inscription contraire aux textes qui régissent l’ASPIT et l’OHADA, il demande l’annulation de la DRP relative à la nomination du Commissaire aux comptes.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte des articles 20 et 21 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 précité, que, d'une part, le CRD est chargé de recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service publics ;

Que, d'autre part, la Commission Litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation et ayant pour objet de contester :

- les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
- le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;
- la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation ;
- les spécifications techniques retenues ;
- les critères d'évaluation ;

Considérant qu'au moment du recours de Papa Konaré Seck, la procédure de passation de la DRP inscrite dans le PPM et incriminée n'a pas été entamée ;

Qu'il ne peut donc se prévaloir, au moment de son recours, ni de la qualité de candidat ni de celle de soumissionnaire ;

Qu'au surplus, le recours ne se rattache à aucun des objets ci-dessus visés ;

Qu'il y a lieu de déclarer le requérant irrecevable en son recours.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate d'une part, que la procédure de passation de la DRP inscrite dans le PPM de l'ASPIT n'a pas été entamée et d'autre part que le recours ne vise aucun des objets visés à l'article 20 précité; en conséquence,
- 2) Déclare irrecevable ledit recours ;
- 3) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à Papa Konaré Seck, à l'ASPIT ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président
Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd'El Kader NDIAYE

Mamadou DEME

Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

XIV. IRRECEVABILITE DU RECOURS DU CANDIDAT CONTESTANT UNE DECISION DE LA DCMP

Créée au sein du Ministère de l'Economie et des Finances par décret n° 2007-547- du 25 avril 2007, la Direction Centrale des Marchés Publics a pour mission :

- d’assurer le contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics ;
- d’émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et d’accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- d’émettre des avis sur la procédure de passation de convention de délégation ou de contrat de partenariat (article 81.2 du code des marchés publics) ;
- d’assurer, en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ;
- de contribuer, en relation avec l’organe de régulation, à la collecte et à l’analyse des données ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur les marchés publics.

En vertu de l’article 81.4 du code des marchés publics de 2007 (article 83-4 du code de 2011), les avis de la DCMP relatifs à l’attribution des marchés publics peuvent être déférés par l’autorité contractante devant le CRD, si ladite autorité n’accepte pas les recommandations formulées ; ainsi, ledit recours n’étant pas ouvert au candidat, le CRD le déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, s’il émane d’un candidat (décision du CRD n° 14 du 2 février 2011 : Dakar Management and Trading : DMT contre DCMP).

**DECISION N° 014/11/ARMP/CRD DU 02 FEVRIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE DAKAR MANAGEMENT AND
TRADING (DMT) CONTESTANT L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP SUR
L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’EXPLOITATION DES
RESTAURANTS DES ETABISSEMENTS UNIVERSITAIRES LANCE PAR LE
CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DAKAR.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre en date du 09 décembre 2010 de la société Dakar Management and Trading (DMT) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique, et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 05 janvier 2011, enregistrée le 06 janvier 2011 sous le numéro 011/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société Dakar Management and Trading (DMT) a introduit une requête aux fins de contester l'avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur le rapport d'attribution du marché relatif à la sélection par le COUD de prestataires chargés de la gestion et l'exploitation des restaurants universitaires ci-après : CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, Bloc CETAD DE POUT, ISFAR, ENSA, CMRT, UFR SANTE, UNIVERSITE DE ZIGUINCHOR.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que suite à la décision n°130/10/ARMP/CRD du 15 septembre 2010 du CRD ordonnant la relance de l'avis d'appel d'offres susvisé pour entrave au principe de la liberté d'accès aux marchés publics, le COUD a publié les 23 et 24 septembre 2010 un avis rectificatif dans le quotidien « Le Matin » ;

Considérant qu'au lieu de mettre en œuvre la décision du CRD, c'est-à-dire de procéder à la relance dudit marché, l'autorité contractante a préféré publier dans le journal quotidien « Le Matin » des 23 et 24 septembre 2010, un avis rectificatif modifiant les clauses incriminées et accordant un délai de quinze (15) jours aux soumissionnaires pour le dépôt des offres et l'ouverture des plis ;

Considérant que par lettre n°5054/MEF/DCMP/DCV/60 en date du 28 octobre 2010, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) a émis un avis défavorable sur la proposition d'attribution du marché au motif d'une part que le dossier d'appel d'offres modifié n'a pas été soumis à la revue préalable et d'autre part, que le délai de trente jours calendaires prévu pour le dépôt des offres n'a pas été respecté ;

Considérant que suite à cet avis défavorable de l'organe chargé du contrôle a priori, l'autorité contractante a repris la procédure de passation en publiant dans le journal « Le Matin » du 22 novembre 2010, un autre avis d'appel d'offres comme exigé par le Comité de Règlement des Différends (CRD) dans sa décision n°130/10/ARMP/CRD du 15 septembre 2010 ;

Considérant que par lettre en date du 9 décembre 2010 reçue le 10 décembre 2010, le requérant a contesté l'avis de la DCMP au motif que d'une part, l'appel d'offres n'était pas infructueux, d'autre part, la décision d'attribution devait être maintenue malgré le vice de procédure constaté par l'organe chargé du contrôle a priori ;

Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 81.4 du Code des Marchés publics, il appartient à l'autorité contractante et non aux candidats de contester les recommandations formulées par l'organe chargé du contrôle a priori sur une proposition d'attribution et de saisir le CRD dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations ;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant n'a pas qualité pour introduire une réclamation contestant l'avis de la DCMP sur la proposition d'attribution ;

Qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE :

- 1) Déclare irrecevable le candidat Dakar Management and Trading (DMT) en son recours pour défaut de qualité ;
- 2) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société Dakar Management and Trading, à la Direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

XV. IRRECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DES RECOMMANDATIONS DE LA DCMP INTRODUIT HORS DELAI

En vertu de l'article 81.4 du code des marchés publics de 2007 (article 83.4 du code de 2011), pour contester les recommandations de la DCMP, l'autorité contractante doit saisir le CRD dans un délai de trois (03) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations ; il s'agit, comme cela a été précisé par l'article 4-16 du code des marchés publics de 2007, de délais exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Il faut également ajouter que les jours non ouvrés, non plus, ne sont pas comptés, notamment les samedis et les dimanches.

Donc, les recours en contestation introduits après l'expiration dudit délai sont déclarés irrecevables, pour forclusion. Il en a été ainsi, par exemple, pour les deux (02) affaires suivantes :

1. Décision n° 4 du 12 janvier 2011 : Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol du Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement contre la DCMP ;
2. Décision n° 10 du 19 janvier 2011 : Ministère de l'Enseignement Préscolaire de l'Elémentaire, du Moyen Secondaire et des Langues Nationales contre DCMP.

DECISION N° 004/11/ARMP/CRD DU 12 JANVIER 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LA DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DE L'OCCUPATION DU SOL DU MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'ASSAINISSEMENT, DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION PORTANT SUR LE MARCHE D'ACQUISITION DE DEUX VEHICULES 4X4 PICK UP POUR LES BRIGADES ZONALES DE PIKINE GUEDIAWAYE ET RUFISQUE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des obligations de l'administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 0099/MUA/DSCOS du 20 décembre 2010 de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol du Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement, enregistrée le 20 décembre 2010 sous le numéro 862/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Abd'El Kader N'DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends,

De MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci après :

Par courrier n° 0099/MUA/DSCOS du 20 décembre 2010 enregistré le 20 décembre 2010 sous le numéro 862/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol du Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement a introduit une requête demandant au CRD l'autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à l'acquisition de deux véhicules 4X4 Pick Up pour les brigades zonales de Pikine, Guédiawaye et Rufisque.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'à la suite de l'avis appel d'offre lancé dans le journal « Le Soleil » du 13 septembre 2010 par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol (DSCOS), la commission des marchés a soumis le rapport d'évaluation des offres et le procès verbal d'attribution pour avis à la DCMP par lettre n°32/MUA/CAB/CPM du 7 décembre 2010 ;

Considérant qu'après examen, l'organe chargé du contrôle a priori a informé l'autorité contractante par courrier en date du 10 décembre 2010 du rejet du dossier pour les raisons suivantes :

- l'ouverture des plis du marché précité s'est tenue le 13 octobre 2010 alors que la date du 12 octobre 2010 était fixée dans les dispositions de la clause 23.1 des Données particulières de l'appel d'offres ;
- les spécifications techniques du Dossier d'appel d'offres n'ont pas été respectées ;
- les dossiers types exigés par la résolution n°15/09 du 27 mars 2009 du Conseil de Régulation de l'ARMP n'ont pas été utilisés ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 2, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours relatifs aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant à cet égard que selon les dispositions de l'article 81.2 du Code des Marchés publics modifié, l'autorité contractante transmet la proposition d'attribution du marché à la DCMP pour avis ;

Qu'au cas où l'autorité contractante n'accepte pas les recommandations de la DCMP sur la proposition d'attribution du marché, elle peut saisir le CRD dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception desdites recommandations, en référence à l'article 81.4 du Code des Marchés publics ;

Considérant que l'autorité contractante a introduit son recours par lettre en date du 20 décembre 2010 enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, soit quatre (4) jours francs après la réception de l'avis défavorable de la DCMP ;

Que le recours n'étant pas introduit dans les délais prescrits, il doit être déclaré irrecevable.

DECIDE :

- 1) Déclare irrecevable la requête introduite pour tardiveté ;
- 2) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol du Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

**DECISION N° 010/11/ARMP/CRD DU 19 JANVIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, DE L'ELEMENTAIRE, DU MOYEN
SECONDAIRE ET DES LANGUES NATIONALES SOLLICITANT
L'AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DU
MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES
SUITE A L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP A LA PROPOSITION
D'ATTRIBUTION DUDIT MARCHE**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) modifié, notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n°005925/MEPEMSLN/SG/CPM du 09 décembre 2010 du Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement préscolaire, de l'Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales ;

Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, rapporteur présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 09 décembre 2010, enregistrée le 13 décembre 2010 sous le numéro 851/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement préscolaire, de l'Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales a saisi le CRD d'une demande d'autorisation à poursuivre la procédure d'attribution du marché susvisé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de la lettre de saisine du CRD que la DCMP a émis un avis défavorable à l'attribution du marché susvisé au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'inscription dans le plan de passation des marchés de l'autorité contractante de l'année budgétaire concernée, alors que cette formalité est prévue par l'article 6 du Code des Marchés publics, à peine de nullité ;

Considérant que l'autorité contractante, qui a reconnu l'inobservation de la formalité de l'inscription du marché dans le PPM, a invoqué une omission de procéder à l'inscription dudit marché dans le PPM réactualisé et communiqué à la DCMP ;

Que cependant, elle a demandé à la DCMP de reconsidérer sa décision, mais que par lettre n°0059006/MEF/DCMP/59 du 27 octobre 2010, celle-ci a confirmé son premier avis en objectant la nullité de la procédure ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'autorité contractante a exposé que les fonds concernés imputés au projet APSE proviennent d'une subvention de l'Agence française de Développement (AFD) et que la date limite d'engagement desdits fonds est fixée au 31 décembre 2010 ;

Considérant, outre la nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 6 du Code des marchés publics, opportunément soulevée par la DCMP, que les articles 81.4 et 139.3 du code font obligation à l'autorité contractante, pour poursuivre la procédure de passation lorsqu'elle n'accepte pas les avis et recommandations formulées par la DCMP, de saisir le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception des avis ou recommandations émis par la DCMP ;

Considérant que les recommandations de la DCMP ont été transmises par lettre n°0059006/MEF/DCMP/59 du 27 octobre 2010 à l'autorité contractante ; que celle-ci a saisi le CRD le 13 décembre 2010, soit largement au-delà du délai de trois (3) jours prescrit par la réglementation ; qu'en conséquence, sa saisine doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

- 1) Déclare irrecevable la saisine du Ministère de l'Enseignement préscolaire, de l'Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales ;
- 2) Dit que le Directeur Général de l'ARMP est chargé de notifier au Ministère de l'Enseignement préscolaire, de l'Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

XVI. PARTICIPATION DES ENTREPRISES ETRANGERES NON COMMUNAUTAIRES AUX MARCHES PUBLICS

Le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics dispose en son article 52 :

1. « La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit immobilier ou au registre des métiers du Sénégal ou dans l'un desdits Etats.
2. Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent en application d'accords internationaux ou lorsqu'il s'agit de fournitures, travaux ou services, ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales ».

Mais, suite à l'intervention du décret n° 2010-1188 du 13 septembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics, cet alinéa 2 de l'ancien article 52, qui permettait à l'autorité contractante de recourir à des candidatures étrangères en application d'accords internationaux ou lorsque l'objet du marché ne pouvait pas être réalisé par des candidats issus du tissu communautaire, n'a pas été repris par le nouvel article.

Se fondant sur cette modification, la DCMP, chargée du contrôle à priori, donnait de façon systématique, avant l'avènement du code de 2011, un avis défavorable à toutes les demandes des autorités contractantes, relatives à l'ouverture de la compétition à des entreprises étrangères non communautaires ou au projet de dossiers d'appel d'offres ouvert auxdites entreprises.

Mais à chaque fois que le CRD était saisi, il autorisait l'ouverture de la compétition aux entreprises étrangères non communautaires en faisant valoir ce qui suit : « Dit qu'en vertu de l'article 28 du code des obligations de l'administration, la suppression ou l'omission de l'alinéa 2 de l'article 52 ancien ne constitue pas un empêchement au recours aux entreprises étrangères lorsque les fournitures, travaux ou services objet de la commande publique ne peuvent pas être livrés ou réalisés par des entreprises locales ;

Dit qu'il y a lieu d'autoriser la participation d'entreprises étrangères pour le marché concerné qui ne peut être livré ou réalisé par des entreprises locales » (décision du CRD n° 7 du 12 janvier 2011 : Ministère de l'Economie Maritime contre DCMP) ou « autorise l'autorité contractante à poursuivre la procédure ... » (décision du CRD n° 11 du 19 janvier 2011).

**DECISION N° 007/11/ARMP/CRD DU 12 JANVIER 2011
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUITE A L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP SUR LA
DEMANDE D'AUTORISATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME
D'ELARGIR A DES CABINETS NON COMMUNAUTAIRES, L'APPEL D'OFFRES
RESTREINT PORTANT SUR L'ETUDE PRELIMINAIRE POUR L'EXTENSION DU
PLATEAU CONTINENTAL DU SENEGAL DONT LE FINANCEMENT EST
PREVU SUR LE BUDGET NATIONAL.**

**LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) modifié ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n° 980/MEM/DAGE/DAA du 14 décembre 2010 du Ministère de l'Economie Maritime, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le numéro 860/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends ;

Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;

En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, MM. Abd'El Kader N'DIAYE, Mamadou DEME et Ndiace DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar SARR, Conseiller juridique, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

